

**EL ROMANO
LA TIERRA
LAS ARMAS**

*Haroldo R. Gavernet -
Mario A. Mojer*

Capítulo 1

FRANJA MORADA

SUMARIO:

I. Ius y Fas.

II. Iustitia.

III. Iurisprudencia.

IV. Los preceptos fundamentales de Ulpiano.

V. Derecho público y derecho privado.

VI. Del derecho natural, del derecho de gentes, del derecho civil.

VII. Aequitas.

VIII. División de los períodos del derecho romano.

La experiencia acumulada en el dictado de las clases, en las diferentes Facultades y a través de los distintos cursos en que los autores tuvimos ocasión de ejercitar la docencia, nos ha permitido elaborar esta obra.

Intentamos proporcionar a los alumnos, por medio de este texto, un instrumento adecuado a las necesidades que el estudio de la materia impone.

Entendemos que no resulta eficaz encarar la explicación de los temas aquí reunidos como una simple enumeración de datos y hechos históricos, que estimamos impropios de la materia. Antes bien creemos más adecuado ofrecer a los estudiantes elementos que les permitan descubrir la idiosincracia y espíritu, que posibiliten la comprensión de las instituciones jurídicas romanas y el porqué de su evolución y prolongada vigencia.

No es éste un tratado destinado a la profundización erudita de las múltiples e interesantes cuestiones que la materia permite. Se trata simplemente de entregar el producto de nuestro esfuerzo con la intención de allanar el camino a alumnos de los primeros años de la carrera.

Deseamos que encuentren una exposición simple, amena y útil que los lleve a descubrir aquellas virtudes elevadoras de los hombres y los pueblos, escondidas en las instituciones romanas.

No podemos olvidarnos, al presentar este trabajo, de agradecer a quienes con paciencia y generosidad nos transmitieron sus conocimientos y afecto; nuestros maestros, Dres. Alfredo Di Pietro y Carlos Ernesto Ambrosioni.

LOS AUTORES

La Plata, 1 de agosto de 1991.

NOCIONES FUNDAMENTALES

El Derecho Romano. Su trascendencia.

Utilidad de su Estudio. Estado actual de la cuestión

“¿Y qué es lo que nos dice a nosotros, hombres de este mundo actual. . . este derecho que aplicaron los romanos?. En primera instancia podríamos decir que el concepto de IUS creado por el hombre romano, la eficacísima técnica empleada por los magistrados y jurisprudentes, la construcción sutilísima adecuada de sus instituciones en una realidad, en ciertos aspectos siempre igual, y en otros cambiante, otorgan al Derecho Romano el valor de “derecho fuente”, entendido ello en el sentido de un manantial que no se agota, entregando la sustancia nutritiva que sustancializa hoy día la “manera de pensar jurídicamente” Di Pietro Alfredo: “Derecho Romano, necesidad de su enseñanza” en Revista Verbo, Nº 142, Buenos Aires, 1974.

— En Roma, de manera especialísima se destaca la preocupación de un pueblo por el elemento jurídico, el que aparece como factor civilizador fundamental.

En tal sentido se manifiesta la jerarquía y originalidad de las técnicas empleadas por los romanos en la solución de los conflictos.

Sin duda en este pueblo es donde se patentiza con mayor claridad la concordancia de la actividad jurídica con los valores políticos. Sumado a ello el sentimiento religioso y moral, como determinante de las relaciones humanas.

La idea de la autoridad y la libertad, entendidas como conceptos complementarios y no contrapuestos, se halla de modo permanente en el origen de la organización político social y jurídica de los romanos. De modo tal que importa una solución práctica, útil, para resolver problemas aún vigentes.

Se ha reconocido al Derecho Romano su constante adhesión a la realidad y la solidez de su estructura lógica, atribuyéndose a tales razones su persistencia en el tiempo y su superioridad frente a otros ordenamientos jurídicos.

Pero ha de agregarse, a tales razones, las particulares características del agrupamiento social de los romanos. Tuvieron éstos la capacidad para, en base a las diferentes coyunturas históricas, ir superándolas por la creación de principios jurídicos esenciales.

Ello no hubiese sido posible sin la concepción de un Estado que, sobreponiéndose a los lazos de la estirpe, no ignoró la trascendencia de los grupos familiares y gentilicios primitivos.

En nuestros días deviene indudable la necesidad y practicidad del estudio de las instituciones romanas, que proporcionan las categorías jurídicas posibilitantes del entendimiento y comprensión del derecho actual.

Además, la simple observación de las fuentes de la legislación contemporánea, muestra su indudable origen romano. En efecto, la lectura de las notas de Velez Sarsfield basta para advertir la mención como fuentes de las normas del Código Civil al Derecho Romano, ya sea de manera directa como a través de su evolución en el derecho indiano o rescensión en las legislaciones europeas o la doctrina de los diversos autores.

Este derecho, que se ~~plasmara de modo~~ admirable durante los 12 siglos que van desde la fundación de Roma hasta la muerte de Justiniano, no puede considerarse como letra muerta.

No puede olvidarse su carácter de derecho común, objeto de estudio permanente a través del tiempo y aún en las culturas más diversas. Ya señalaba RICO-BONO ("Roma, madre de las leyes", Depalma, Buenos Aires, 1975): "La característica de la historia del Derecho Romano de los 14 siglos después de Justiniano, es una exposición continua, una marcha triunfal, primero en oriente y luego en occidente hacia el reconocimiento cada vez más universal, sin detenciones y sin derrotas". Y agregamos: es incomprensible pensar en juristas que desechen el aprendizaje del Derecho Romano.

El estudio de las instituciones romanas resulta imprescindible a quien pretenda adquirir una real cultura jurídica.

"El Derecho Romano no es una asignatura accesorio. Es esencial y pedagógica, porque la historia y el conocimiento de sus instituciones muchos de ellos vigentes se ven plasmados en el más romántico de los textos como lo es nuestro propio Código Civil" (GOMEZ FLEYTAS, José G., en diario "La Nación", Buenos Aires).

El estudio del Derecho Romano influyó decisivamente en la evolución de la civilización europea, proporcionando a los juristas los elementos que permiten la comprensión de los sistemas jurídicos modernos, otorgando los elementos lógicos para su razonamiento.

La fuerte tradición romanística de los juristas, que autorizara a hablar de la vida ulterior del Derecho Romano, al surgir los Estados nacionales se constituyó en la base o derecho común en que se sustentan los derechos modernos.

Al producirse, durante el siglo XIX, especialmente en Alemania, la profundización de los estudios del derecho justiniano (pandectística) con la adaptación a la realidad de la época, se podrá hablar de "derecho romano actual", generándose también una línea de desarrollo que establecerá las bases de la ciencia jurídica moderna.

El período de codificación del derecho, en especial a través del Código Napoleón, se sustenta en el sistema romano. Así el Código Civil Francés ha seguido las concepciones jurídicas de Pothier, de reconocida ascendencia romanista.

El jurista moderno encontrará en los análisis y soluciones que presentan las fuentes romanas, los medios técnicos y metodológicos para arribar a la adecuada interpretación de las normas legales.

En definitiva, resulta innegable que la tradición jurídica es fundamentalmente romana. Es más: el sistema del "common law", aún con sus distintivas características respecto al derecho continental, trasunta un fondo romanístico que lo torna, en muchos aspectos, más cercano al Derecho Romano.

A modo de síntesis, puede afirmarse —como señala Alvaro D'Ors (Rev. La Ley, 1984 B, Sec. Doctr.) que: "El Derecho Romano nos muestra ante todo que el derecho no puede reducirse a un orden impuesto por la potestad del poder, mediante la forma imperativa de las leyes, sino que es, ante todo, un producto de la "prudentia iuris", es decir de la ciencia propia de especialistas con autoridad en el campo de la resolución de conflictos interpersonales sobre los bienes. De ahí su virtud incomparable para la formación de juristas, de los prudentes de hoy y, en concreto, la conveniencia de colocar la enseñanza del derecho romano privado como introducción. . . al estudio del derecho privado actual".

Ius y Fas

Las expresiones *Ius* y *Fas* han merecido, a través del tiempo, diversas interpretaciones, muchas veces simplistas, que llegan a dificultar la comprensión del problema.

Así se ha pretendido incluso plantear una oposición entre ambos conceptos, cuando en la realidad se encuentran ligados intimamente.

Ejemplo de lo dicho es la opinión que reduce a *Ius* a la categoría de derecho humano y *Fas* a la de derecho divino.

Lo erróneo de tal postura se advierte no bien se señale la estrecha relación que en Roma, como en todos los pueblos de la antigüedad, ha existido entre la religión y el derecho.

El derecho y la religión se desarrollan de modo contemporáneo y paralelo. Aún la más rudimentaria de las organizaciones sociales es concebida respondiendo a un orden superior y trascendente.

El carácter religioso de la organización romana primitiva muestra la interrelación entre lo religioso y lo jurídico.

El monarca, más que un jefe político es autoridad religiosa. De allí su investidura. Su poder, así como el de los pontífices, en materia jurídica, está fundado en su carácter religioso.

Las formas del derecho arcaico denotan su origen ritual, de tal modo que el logro de la finalidad jurídica irá unido a la realización de las solemnidades prescriptas, indicadas por los pontífices, del mismo modo que la ceremonia sagrada se encamina a lograr el favor de los dioses.

Ambos términos —*Ius* y *Fas*— están vinculados al vocabulario religioso más primitivo. *Fas* derivaría de raíces indoeuropeas (*Bha*, *Dha*: brillar, hablar, establecer).

La locución verbal *fas* est tiene el significado de lo que está conforme al orden fundamental. También es la palabra divina expresada por quienes tienen tal facultad: *Abis* pontífices, el *rex*. Puede concluirse que *fas* es lo que sirve para sostener y fundar el orden de las cosas.

De tal modo, el *fas* es el fundamento del *ius*, operando incluso donde el *ius* no lo hace, no pudiendo el *ius* apartarse de lo reglado por el *fas*.

En cuanto al *ius* la doctrina aparece dividida al momento de precisar su acepción. Para algunos sería lo que liga, ata y vincula a las personas entre sí (*ieu - iug*: ligamen, vínculo); de esta posición deriva la que resalta la idea de lo que está unido por estar circunscripto, por tener forma circular, es decir lo establecido por un tribunal o asamblea y que, como consecuencia, une, vincula. Otra opinión afirma que *ius* provendría de *iouis* (designación de *iuppiter*), de donde la fuente de que emana el *ius* es la divinidad.

El estado actual de la investigación ha llevado a la conclusión de que *ius* deriva del *yaus* indo-iranio que a su vez proviene de las formas antiquísimas del vocabulario religioso *yaos* y *yoh* (la primera expresión irania, la segunda védica).

La expresión *yaos da* se refiere a los actos humanos por los que se busca tornar completa, perfecta, una cosa invisible, un estado espiritual o también transformar en ritualmente apto un instrumento de culto. Además comprende el acto ritual que purifica lo profanado. En resumen, se trata de purificar a alguien o a algo, o reparar purificando lo profanado.

El vocablo *yoh* figura combinado con *sam*, con el sentido de bendición, bienestar, salud. Mas que a los actos humanos se refiere al otorgamiento por los dioses de la salud y la bendición que llegan a abarcar hasta los intereses materiales.

De todo ello pueden resumirse en dos los significados de *yaus*: a) el que designa el estado óptimo o máximo que se logra a partir de una situación determinada, ya sea en el aspecto místico o el material; y b) el que expresa el estado normal al que se arriba cuando se restaura o restablece la situación a partir de la enfermedad o la impureza.

El *ius* latino, en su sentido primitivo, conserva en cierta medida el significado de *yaus*. Pero mientras *yaus* se circunscribe a algo o a alguien, *ius* se muestra como la pretensión que alguien puede tener respecto de algo o de alguien con relación a los demás. Se ha producido una alterización.

Lo jurídico siempre importa una relación con el otro, de tal forma que quien posee el *ius* está en la situación óptima, que siempre lo es respecto a la situación de otro u otros.

Así cuando decimos poseer el *dominium ex iure quiritium* estamos diciendo que nuestro derecho de propiedad lo es en la óptima situación con relación a los demás.

A la alterización señalada los romanos la han acompañado con una necesaria laicización, que explica el desprendimiento del derecho y la religión en Roma.

Además de esta idea de la máxima posibilidad que puede alcanzarse respecto de algo o de alguien, también el *ius* se muestra como el restablecimiento, a par-

tir de su vulneración, del derecho que me corresponde a través de la tarea del órgano adecuado.

Así como para alcanzar la óptima posibilidad mística era necesario recurrir a la ceremonia precisa, para adquirir el óptimo jurídico ha de aplicarse el rito, cumplirse la solemnidad respectiva.

Ius es entonces el estado óptimo que se alcanza con relación a otro y al que se llega por el cumplimiento de los ritos necesarios.

"La palabra *IUS* se emplea en varias acepciones: una, cuando se llama *IUS* a lo que siempre es justo y bueno, como es el derecho natural; otra acepción, lo que en cada ciudad es útil para todos o para muchos, como es el derecho civil; y no con menos razón se llama *IUS*, en nuestra ciudad, al derecho honorario. Se dice también que el Pretor aplica el *IUS* incluso cuando decide injustamente, refiriéndose, claro está, no a lo que el Pretor hizo, sino a lo que el Pretor debería hacer. Se llama *IUS*, en otro sentido, al lugar en el que el Pretor aplica el *IUS*, dándose la denominación de lo que se hace al lugar en donde se hace. Podemos determinar tal lugar de esta manera: el lugar donde el Pretor, conforme a la majestad de su imperio y a la costumbre de los antepasados, determina declarar el *IUS* se llama, con razón, *IUS*". (Paulo en D.: 1, 1, 11).

Como se ha visto, las expresiones *fas* y *ius* están interrelacionadas, lo que no implica desconocer la posibilidad de análisis particularizado de cada una.

La vinculación entre ambas está dada en que el *fas* tiene sentido de fundamento o apoyatura, en tanto el *ius* es lo "instituido". El *ius*, entonces, requiere, como toda construcción, basarse o apoyarse.

El fundamento que los romanos daban al *IUS* no es otro que el *FAS*. Es decir que se asienta sobre una concepción de naturaleza "divina", cósmica.

Como se advierte del texto del Digesto del acápito, múltiples son las acepciones en que los romanos utilizaron el vocablo *ius*.

Así, en una primera etapa el cumplir con los ritos determinaba la licitud del acto y definía al *IUS*. Autores latinos usan a menudo *ritus* y *mos*, es decir rito y costumbre. Aparece de este modo la relación entre el rito y las *leges maiorum*, fuente del derecho de la época arcaica.

También se usaba la expresión *ex iure quiritium*, que debe interpretarse como la plenitud de una determinada situación jurídica atribuida por el *IUS*, a la que se llegaba utilizando el rito apropiado y eficaz a la misma.

Además *ius* designa a la solemnidad misma, que indica la situación *iusta* en las relaciones entre particulares.

Otra acepción nos lleva a la designación del lugar donde se administra justicia: así la *in ius* vocatio (convocatoria ante la justicia) que ya aparece en el texto de la ley *decenviral*.

La expresión *in iure* se aplica a los actos ocurridos en presencia del magistrado.

Ius dicere señala la función de establecer el *IUS* propia del magistrado, tarea eminentemente creativa en lo jurídico. Ante la controversia traída por las partes, el Pretor deberá señalar cual resulta la conforme a *IUS* (*iusta*) y cual la contraria (*iniusta*).

Lo importante de esta función se hace patente si recordamos la inexistencia de un ordenamiento jurídico preestablecido a la manera moderna.

Será, a partir del IUS que el magistrado extraerá la regla (*regula*) en base a la cual dirimirá el litigio (*litis*).

Iurisdictio contiene las sucesivas creaciones del magistrado al resolver las disputas jurídicas, y como tal, aparece basada en el *imperium*.

La función pretoria de establecer el IUS se distingue de la del *iudex* (juez) que se limita a mostrarlo.

Iustitia

"La justicia es la constante y firme voluntad de dar siempre a cada uno lo que es suyo".
(Just. Inst. I, 1, pr.).

El concepto de justicia, que se extrae de las Institutas y el Digesto, y que conocemos a través de Ulpiano, reconoce influencia de la filosofía estoica.

Para esta escuela filosófica la idea de virtud debe asumir el carácter de conducta habitual, de tal modo que se tenía por vicioso lo que lo era solo por una vez.

La virtud romana (de *vir* = varón) es lo propio y esencial al hombre, es decir, que conlleva un contenido de practicidad.

Así ha de entenderse que la justicia se diferencia de otras virtudes por su específico carácter del: "DAR A CADA UNO SU DERECHO", por la cual la conducta de cada uno ha de adecuarse a la ley.

Ese observar en las acciones humanas los principios jurídicos ha de concretarse de manera constante y perpetua. De tal modo la justicia pierde su contenido abstracto, de valor ideal y estático, transformándose en una práctica concreta, dinámica y firme que permanentemente ha de dirigir las conductas.

Iurisprudentia

"La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas con la ciencia de lo justo y de lo injusto".
(Just. Inst. I, 1, 1).

Por tal ha de entenderse la tarea propia de los jurisperitos, como la de aquellos que discernían acerca de la prudencia del ius.

Prudencia, para los romanos, es el conocimiento de la realidad, que implica verdadera sabiduría. Solo el conocimiento de la verdad contenida en la realidad permite aplicar adecuadamente a los hechos el derecho.

La labor del jurisprudente es desentrañar de la realidad lo que pertenece a la esencia de cada cosa, administrando la justicia que les es propia.

De allí que se le exija el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto.

Lo opuesto a la justicia, para el hombre antiguo, era lo desmesurado, lo excesivo, que exigía que las cosas fueran repuestas a sus límites. La idea de justicia no negaba la existencia de lo injusto, que también forma parte de la realidad.

No es extraño que fueran los pontífices los primeros jurisperitos, ya que intermediaban entre los dioses y los hombres y, por ende, conocían los ritos y formas restablecedoras del equilibrio entre las cosas divinas y humanas.

Así podemos entender a Ulpiano cuando dice: "... En razón de lo cual se nos puede llamar sacerdotes; en efecto, rendimos culto a la justicia y profesamos el saber de lo bueno y de lo justo, separando lo justo de lo injusto, discerniendo lo lícito de lo ilícito, anhelando hacer buenos a los hombres, no solo por el temor de los castigos, sino también por el estímulo de los premios, dedicados, si no yerro, a una verdadera y no simulada filosofía". (D.: I, 1, 1, 1).

Los Preceptos Fundamentales de Ulpiano

"Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo".
(Just. Inst. I, 1, 3).

a) *Honestae Vivere*

La moderna separación filosófica entre lo propio de la moral y el campo del derecho, no puede aplicarse estrictamente a las concepciones romanas.

Sin duda la interrelación de lo propio de cada uno de ellos es en Roma una patente realidad. Así las "*mores maiorum*" no podrían ser entendidas aplicando una óptica moderna.

Disposiciones como impedimentos matrimoniales, las permanentes referencias a la buena fe, el juramento, la veracidad de los dichos del testigo; la incidencia de virtudes como la austeridad, la severidad de costumbres, cuya violación producía efectos ciertamente jurídicos (*cura mores censoria*) evidencia la incidencia del "vivir honestamente" como principio fundamental del derecho.

Estos preceptos, de contenido moral, no dejan por ello de ser también jurídicos. El IUS sirve para garantizar la pública honestidad y las buenas costumbres y quien las viole, será pasible de la sanción jurídica por ser su proceder contrario al "*honestae vivere*".

b) *Alterum Non Laedere*

Quien se abstiene de la conducta prohibida por las leyes, obedece al precepto de no hacer daño a nadie.

Es justo quien no daña a nadie, absteniéndose de injurias, lesiones, hurtos, etc.

Es decir que el derecho ha de contemplar la protección contra los daños en la persona y los bienes, otorgando los medios que conduzcan primariamente a evitarlos y, producidos, a resarcirlos.

La alteración del justo equilibrio que lesiona los afectos, la persona y sus bienes, es decir, importa una lesión en los derechos, que obliga al restablecimiento del orden agredido.

El precepto "*alterum non laedere*" evidencia la característica que es propia del derecho de evitar las conductas que afectan la integridad de los valores humanos y consecuentemente procuren la paz y la justicia en el Estado.

c) *Suum Cuique Tribuere*

Quien hace lo que las leyes mandan, cumple con el dar a cada uno lo suyo.

Cumplir los contratos, guardar los pactos, reconocer los derechos de los demás, están ínsitos en el dar lo suyo a cada cual.

Este precepto contiene la idea de justicia común a Ulpiano, a Aristóteles, a Platón y a Santo Tomás. Según Villey, en el mundo antiguo y en el medieval el concepto de derecho y de justicia contiene la idea de que existe un orden de justicia natural encaminado a atribuir a cada uno lo suyo, lo que corresponde. La intención de la justicia, entonces, no se agota en el respeto a los derechos de otro sino primordialmente a medir las prerrogativas que a cada cual correspondan, con el objeto de asegurarle de manera efectiva la parte que le es correspondida, la que ha de mantenerse en el justo límite que evite lo excesivo.

Derecho Público y Derecho Privado

"Es derecho público el que respecta al estado de la república, privado el que respecta a la utilidad de los particulares, pues hay cosas de utilidad pública y otras de utilidad privada. El derecho público consiste en el ordenamiento religioso, de los sacerdotes y de los magistrados. El derecho privado es tripartito, pues está compuesto por los preceptos naturales, de gentes y civiles". (Ulpiano en D.: 1, 1, 1, 2).

El concepto de Ulpiano, expresado en el Digesto e Institutas, ha dado origen a diversas interpretaciones, sobre todo entre los juristas modernos.

Así hay quienes consideran que las disposiciones que provienen del derecho público también conciernen a los particulares, ya que han sido dictadas en su interés.

Bajo este punto de vista sería difícil separar lo que atañe a cada uno de estos derechos.

Sin embargo, otros autores precisan la distinción en un texto de Papiniano, quien en D.: 2, 14, 38, define al derecho público como aquel que no puede ser alterado por los pactos de los particulares.

El problema deriva, en algunos doctrinarios, de enfocar la división con pautas modernas, desconociendo los principios de los juristas romanos.

Así, muchas normas de lo que hoy consideramos derecho privado, pertenecían en Roma a la órbita del derecho público.

Si seguimos estrictamente algunas fuentes romanas es posible llegar a establecer que pertenecen al derecho público todas las disposiciones que provienen del Estado. La ley de las XII Tabas, las leyes comiciales, los Senadoconsultos, las constituciones imperiales, etc. Y solo serían de derecho privado aquellas normas que derivan de la jurisprudencia.

Así, para DE FRANCISCI, si consideramos el derecho antiguo, donde no existe contraposición entre Estado e individuo, todo el derecho podría ser considerado como *ius publicum*.

Ya a fines de la república, el *ius publicum* no es lo contrapuesto al *ius privatum*, sino que se lo utiliza para designar todas aquellas manifestaciones con que el *populus* expresaba su voluntad a través de los órganos de la *civitas*.

Del Derecho Natural, del Derecho de Gentes, del Derecho Civil

"El derecho se divide en civil o de gentes, Todos los pueblos regidos por leyes o costumbres tienen un derecho, que en parte les es propio, y en parte es común a todos los hombres; pues el derecho de cada pueblo se ha exclusivamente, es propio de los individuos de la ciudad, y se llama derecho civil; mas el que una razón natural establece entre todos los hombres, y se observa en casi todos los pueblos, se llama derecho de gentes, es decir, de todas las naciones. Los romanos siguen también un derecho en parte aplicable a los solos ciudadanos y en parte a todos los hombres. Cuidaremos de determinarlos en sus respectivos lugares". (Inst. Just.: I, 2, 1).

Por derecho civil se entiende aquel que es propio de la ciudad de Roma y exclusivo para sus ciudadanos. Además de este derecho conocieron los romanos otro, aplicable a las relaciones de éstos con los peregrinos, o de los peregrinos entre sí, surgido como consecuencia de las necesidades sobrevenidas de la expansión de Roma. Tal el derecho de gentes, aplicado por el Pretor Peregrino al resolver los conflictos llevados a su conocimiento.

Es decir que la imposibilidad de aplicar el derecho propio de los ciudadanos a las controversias y relaciones jurídicas entre estos y los extranjeros hizo necesario explicitar aquellas normas comunes a todos los pueblos y aceptadas por igual en las diferentes agrupaciones humanas.

A partir de lo dicho, se evidencia que al evolucionar y expandirse Roma, el arcaico derecho quirritario devino insuficiente para contener a las nuevas relaciones jurídicas. El derecho de gentes aparece entonces resolviendo aquellas situaciones excluidas del derecho civil, en razón de su aplicación restrictiva a los ciudadanos romanos.

En definitiva, los romanos estaban regidos simultáneamente por ambos derechos. Por su calidad de ciudadanos por el derecho civil, y por el derecho de gentes por ser derecho común a todos los pueblos.

... El derecho privado es tripartito, pues está compuesto por los preceptos naturales, de gentes y civiles. Es derecho natural aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es propio del género humano, sino común a todos los animales de la tierra y del mar, también es común a las aves. De ahí deriva la unión del macho y la hembra que nosotros denominamos matrimonio; de ahí la procreación de los hijos y de ahí su educación. Pues vemos que también los otros animales incluso los salvajes, parecen tener conocimiento de este derecho". (D.: I, 1, 1, 3).

El precedente texto, cuya autenticidad es dudosa, nos plantea la idea de un derecho natural como tercera categoría, unida a los dos derechos ya tratados.

Ha de señalarse que la tripartición no es aceptada unánimemente. Así, para algunos autores, la idea de derecho natural aparece confundida con la de derecho de gentes.

A tal conclusión se arriba por la expresión "*naturalis ratio*" (razón natural) empleada por Gayo al definir al derecho de gentes como aquel que la razón natural establece entre los hombres y es observado por igual por todos los pueblos (Gayo, Inst.: I, 1).

Lo cierto es que para los juristas de la época clásica es anterior al Estado y está conformado por leyes físicas, comunes a todos los seres animados.

La filosofía griega y en especial Aristóteles entienden al derecho natural como aquel que está por encima del derecho de los Estados, un derecho ideal al que deben aspirar todos los hombres.

El concepto de justicia natural como aquella cuya fuerza es igual en todas partes, independientemente de las diversas idiosincrasias y opiniones, es distinguida por Aristóteles de la justicia legal que, en su origen, puede ser indiferentemente una u otra pero que al establecérsela es impuesta. Es decir que la justicia natural resulta idéntica en todos los pueblos, en tanto la justicia legal es determinada por cada Estado.

Las concepciones justinianeas, apartándose de la posición aristotélica, e imbuídas del concepto cristiano, no consideran al derecho natural como un derecho ideal, sino como un ordenamiento jurídico establecido por la Divina Providencia, como aquellas leyes que permanecen firmes e inmutables (Just. Inst.: I, 2, 11).

La idea del derecho natural como aquel que la naturaleza ya enseñó a todos los animales motiva confusión toda vez que los animales no pueden ser sujetos de derecho. Ha de entenderse que se refiere a aquel derecho que siguen los hombres cuando se adecuan al instinto natural. Por todo ello, no parece adecuado identificar el *ius naturale* y el *ius gentium*. Instituciones de éste último, como la esclavitud, son sin dudas contrarias al derecho natural. Al definirse en el Digesto este instituto, se señala: "*La esclavitud es una institución del derecho de gentes por la cual uno está sometido, contra la naturaleza, al dominio ajeno*". (Florentino, en D.: I, 5, 4, 1).

De todo lo cual puede concluirse que el derecho natural, derivado de la divinidad, es aplicable a todos los seres animados; es decir que el derecho de gentes y el derecho civil están regidos por el *ius naturale*.

El *ius gentium* regula las relaciones humanas de todos los pueblos.

El derecho civil está concebido para regular las conductas de los ciudadanos.

A modo de ejemplo puede citarse el caso de la unión sexual, constitutiva del grupo familiar. El contubernio, unión de los esclavos, sigue las pautas del derecho natural, y como tal es considerado y reconocido; en cambio, el derecho de gentes regula el matrimonio de ciudadanos y extranjeros, en tanto que las justae nuptiae (justas nupcias) es institución reconocida por el derecho civil.

El derecho civil, impregnado de principios religiosos, es el primero que conocen los romanos; este derecho engendra instituciones con marcado contenido formal, donde el rito es la esencia del acto. Así la mancipatio, la sponsio y las legis actionis.

La expansión romana y la consecuente relación entre romanos y extranjeros, derivará en la necesidad de utilizar instituciones propias del derecho de gentes, receptadas por el Pretor, como la traditio, la compraventa o la permuta.

En la *occupatio* (ocupación) y otras figuras se advierte la superposición del derecho de gentes y el derecho natural, lo que permite entender la definición de Gayo acerca del derecho de gentes, como aquel que la razón natural establece entre todos los hombres y es observado por igual por todos los pueblos (Gayo, Inst.: I, 1).

La comprensión del concepto de equidad debe conectarse con la definición de justicia, atribuida a Ulpiano, de la que ya nos ocupáramos.

Al igual que en Cicerón, al referirnos a la justicia no es posible entenderla solamente como la virtud según la cual se le atribuye a cada uno lo que le corresponde según la ley, sino que ha de ampliarse tal concepción para comprender a la que atribuye lo que conviene según la equidad.

Es decir, que a lo que es debido legalmente ha de agregarse lo que le corresponde según el mérito y la misión propia de cada uno.

En las escolias de las Basílicas se comenta la definición de Ulpiano diciendo que: "la justicia es la distribución del bien a cada uno, equitativamente, según su valor". Esto ha llevado a considerar que, para los romanos, la justicia es una virtud del espíritu que excede la mera conformidad de la conducta al marco de la regulación legal.

Los romanos advirtieron, superada la etapa del ascendrado ritualismo jurídico, la inconveniencia de la rígida aplicación de los principios legales.

El interés general, el adecuado funcionamiento del Estado, exigían en la aplicación del derecho la consideración de las particularidades, dignidades y circunstancias de cada caso.

La equidad será la consideración de estas situaciones al momento de resolver los conflictos.

En tal sentido, en la tarea del Pretor es donde se manifiesta la equidad como pauta determinante en la solución de las cuestiones jurídicas.

En la tarea de interpretación, los juristas romanos vivificaron el derecho, adaptándolo a la realidad social.

El Derecho Romano se ha traducido en una práctica concreta y eficaz que podríamos resumir en el afán de realizar el equilibrio entre las situaciones propias de cada uno.

Ha sido la equidad la más eficaz herramienta para la concreción de dicho objetivo.

División de los Períodos del Derecho Romano

Varios son los criterios para considerar los distintos períodos en que es posible dividir la evolución del Derecho Romano.

Se puede aplicar un criterio histórico, en cuyo caso habrá que establecer el lapso durante el cual se desarrollaron las instituciones jurídicas romanas.

Esto es desde el 753 a. C. con la fundación de Roma hasta el 565 d. C., momento de la muerte del Emperador Justiniano.

Atendiendo a las formas de gobierno que tuvo Roma, los períodos son tres: la MONARQUÍA, desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C.; la etapa republicana, desde el 509 a.C. hasta el año 27 a.C.; y el IMPERIO, desde el 27 a.C. hasta el 565 d.C., período que, a su vez, merece subdividirse en Principado (27 a.C. - 235 d.C.) y Dominado (235 d.C. - 565 d.C.).

Ya en el plano jurídico, el Derecho Romano abarca tres grandes épocas:

a) Derecho Quirritario: también llamado viejo Derecho Civil.

Abarca este período desde el nacimiento de Roma hasta el año 450 a. C., fecha en que aparece la ley de las Doce Tablas.

Se trata aquí de un derecho primitivo, altamente influenciado por los principios religiosos, donde el rito se confunde con las manifestaciones jurídicas.

En esta época, el derecho aparece bajo formas estrictas, gobernado por extremas solemnidades.

Los principios jurídicos se apoyan en el valor justicia, estando la actividad jurídica limitada a constatar la realización del rito adecuado.

b) Derecho Civil: que surge con la sanción de la ley de las Doce Tablas y que se extiende hasta el 212 d. C., en que gobernaba Roma el Emperador Caracalla.

Significa la ley decenviral un importante hito en la evolución de las instituciones jurídicas romanas, ya que dará nacimiento a esta nueva etapa, donde el derecho será escrito y ampliamente conocido por todos. Asimismo esta ley, contribuirá, en gran parte, a atenuar las graves desigualdades sociales.

A partir del 242 a. C., con la creación de la magistratura del Pretor Peregrino, será posible pensar en un nuevo derecho: el DERECHO DE GENTES, también llamado honorario o pretoriano. Este derecho, que coexistirá durante algo más de cuatro siglos con el Derecho Civil, va a ofrecer una nueva visión jurídica: es la interpretación y aplicación de las normas de acuerdo a la equidad.

Gradualmente el Magistrado irá completando, supliendo y mejorando el Derecho Civil con ideas más justas, con soluciones más adecuadas a la realidad.

c) Derecho Romano Helénico (212 d. C. - 565 d. C.): En el 212 d. C. el Emperador Caracalla dicta la conocida Constitución Antoniniana, por la que declara ciudadanos romanos a todos los habitantes de los pueblos del Imperio, terminado así con la dicotomía entre Derecho Civil y Derecho de Gentes.

Denomínase a este período del derecho romano-helénico, por la notable influencia de las ideas griegas, fruto del desplazamiento del poder hacia Oriente y la consecuente división del Imperio en Occidental y Oriental.

Es una época que, en general, marca una decadencia en el Derecho Romano, pero de ella, sin embargo, cabe rescatar una labor de compilación de excelsas características. Se la conoce como el CORPUS IURIS CIVILIS, ordenado por Justiniano a los juristas y que fuera concluido entre los años 528 y 565 d. C.]

Bonfante considera al Derecho Romano a través de 3 períodos:

1) Común de Roma y Derecho Quirritario (754 a. C. - 202 a. C.). Hace culminar esta primera época en el triunfo de Roma sobre Cartago, que marca el fin de la 2a. Guerra Púnica.

Aquí observa el autor el nacimiento de la Ciudad-Estado, que tiene su origen en una comunidad de pastores y agricultores, y como la organización estatal va interviniendo, gradualmente, en la solución de los conflictos, en la formación de las leyes y en la interpretación, por los juristas, de las normas que conforman el sistema jurídico.

Durante este período aparece el Pretor, que contribuirá, con el *ius honorarium*, a la transformación del viejo Derecho Civil.

2) Un segundo período es denominado como Estado Romano Itálico, que va a culminar con la muerte de Alejandro Severo en el 235 d. C.

Significa este período la introducción, por parte del Pretor, de un conjunto de

innovaciones que producirán profundos cambios en el derecho.

La obra de la jurisprudencia y de las escuelas jurídicas va siendo desplazada, gradualmente, por una monopólica actividad estatal, a través de las Constituciones Imperiales.

También en esta época, se observa la importancia del Derecho de Gentes, debido a la ampliación de las relaciones comerciales con los extranjeros.

3) Un tercer período, es denominado por Bonfante, del Dominado (235 d. C. - 565 d. C.).

La división del Imperio en Oriental y Occidental, la tolerancia otorgada a la religión cristiana, la aparición de los derechos provinciales y la decadencia de la labor creativa de la jurisprudencia, son los acontecimientos que marcan los rumbos jurídicos de este lapso.

Además perfilan la época el surgimiento de las escuelas de derecho orientales y la concentración del poder imperial.

Existen intentos de unificación del derecho, como la Ley de Citas (426 d. C.) y los Códigos Hermogeniano, Teodosiano y Gregoriano y otras importantes obras que conducirán a la magna tarea que se iniciará en el 528 d. C. en que la Constitución HAEC QUAE NECESSARIO designa una comisión integrada por 10 juristas y presidida por Juan, para compilar las Constituciones Imperiales.

✓ KASER ofrece dividir el Derecho Romano en 3 períodos:

1) El del Derecho romano antiguo que abarca desde el nacimiento de Roma (753 a. C.) hasta el comienzo de las Guerras Púnicas (siglo III a. C.).

2) Un segundo período: el del derecho clásico, que coincide con el Principado, considerado por este autor como régimen imperial moderado. En este sentido, KASER denomina juristas clásicos a los que consiguen que la jurisprudencia alcance una perfección verdaderamente cimera. A ellos se debe que el Derecho Romano adquiera un elevado grado de perfección y que el pensamiento jurídico perdure aún hoy, a través de los tiempos.

3) Un tercer período, denominado postclásico (235 - 565 d. C.) y que coincide con el Dominado.

En esta época el derecho se aparta por completo de la tradición clásica y se convierte en el derecho vulgar postclásico.

Este derecho, dice KASER, es Derecho Romano, pero tan deformado y adulterado que constituye una fase decadente en el proceso de la cultura jurídica.

Este proceso de vulgarización solo se detiene en el sector oriental del Imperio, gracias a la labor clasicista de las escuelas jurídicas (Berito y Constantinopla) que coronarán su obra en lo que se conoce como el Corpus Iuris Civilis.

Es conocida también la división que realiza el jurista HUGO y que reconoce la existencia de cuatro etapas: a) la de la "infancia": desde los orígenes de Roma hasta la ley de las Doce Tablas; b) la de la "juventud" que comprende hasta Cicerón -mediados del siglo I a. C.; c) la de la "virilidad" que termina con la muerte de Alejandro Severo (235 a. C.) y d) la de la "vejez" hasta la muerte de Justiniano (565 a. C.).

Capítulo 2

SUMARIO:

- I. Historia y leyenda.
- II. El espíritu religioso.
- III. El romano, la tierra, las armas.
- IV. Estirpe y estado.
- V. La organización social: La gens.
- VI. Patricios, plebeyos, clientes.
- VII. La estructura política de la monarquía.
- VIII. EL senado.
- IX. El pueblo: Los comicios.
- X. Los colegios sacerdotales.
- XI. Reformas de Servio Tulio.
- XII. Las fuentes de derecho.

Eneas → here troupur
parbis tres lo qeado de Ilión



Loar → rey del lugar

↓
Alba Longa

Rómulo - Remo

LOS ORIGENES. LA MONARQUIA ①

"Al tener que hacer la interpretación de las leyes antiguas, he creído necesario remontarme primero a los orígenes de Roma, no porque quiera escribir extensos comentarios, sino porque estimo, que en todas las cosas, es perfecto lo que consta de todas sus partes. . . Pues salvo que yerre, estos exordios nos conducen con más agrado a la lectura de la materia propuesta y, cuando allí llegamos, facilitan su mejor comprensión". (Gayo, D. I., 2, 1).

No resulta posible entender las instituciones de un pueblo, sin, al menos, intentar conocer la idiosincracia de los hombres que las han creado; los avatares que en el transcurso de la historia les han sobrevenido, las influencias que han soportado, el carácter de quienes dejaron su impronta personal; en fin, sus valores, defectos, y virtudes. Ello posibilitará seguir más adecuadamente la evolución ocurrida durante los más de trece siglos de vida creativa de su Derecho.

Historia y Leyenda

Decíanse los romanos herederos de Troya. Según la leyenda, el peregrinaje de Eneas; el heroé troyano que partió, caída Ilión, junto con su padre y sus Dioses vencidos terminó en el Lacio, donde fuera acogido por un rey del lugar. (Latino).

De su descendencia salieron los fundadores de Alba Longa, y de allí Rómulo, quien fuera junto a su mellizo Remo, hijo de Rhea Silvia —hija del desplazado soberano de Alba Longa— y del Dios Marte, protegido por la Loba, y fundador de Roma. Este relato, magistral y bellamente contado por Virgilio y aceptado por los romanos en toda su dimensión simbólico - religiosa, no es imposible de compatibilizar con los descubrimientos arqueológicos, lingüísticos e históricos.

No es improbable que marinos foráneos, en tiempos homéricos, se hayan introducido por el Tiber, siendo de origen "troyano"; y, que en la zona del Aventino tomaran contacto con los arcaicos habitantes del lugar. Puede asimismo admitirse que desde Alba Longa llegara Rómulo, enfrentándose primero a Remo

—caudillo de los establecidos en el Aventino— y luego con Tacio, cabeza de un grupo sabino afincado en el Capitolio.

También es aceptable que Rómulo trazó sobre el Palatino los límites de su Ciudad, hecho acaecido —según los romanos— un 21 de abril (día de Parilia, fiesta de los pastores) alrededor del año 753 a. C.

Es decir que en época en que florecían numerosas ciudades en los montes Albanos, se formaba el pueblo que terminaría por imponerse en el Lacio, Italia, y demás tierras que baña el Mediterráneo: Roma, cuyo nombre devendría de la antigua denominación del Tiber (*Rumon*).

Las huellas de esas poblaciones de diferentes estirpes existentes en las colinas aledañas al Tiber aparecen en las excavaciones del Esquilino, el Quirinal y el Foro, donde se mezclan tumbas de inhumación con urnas de incineración. La festividad del *Septimontium*, durante la que se celebran sacrificios sobre las siete colinas (las tres del Palatino, tres del Esquilino y el Celio) hace pensar en una suerte de liga religiosa de las rudimentarias aldeas asentadas en el lugar, sin constituir aún una *Civitas*.

✓ Aparece luego la primitiva *Roma Quadrata*, defendida con taludes de tierra, con su territorio delimitado mediante ritos religiosos, edificada en el Palatino por Rómulo el fundador, tal vez como una necesidad frente a la presencia de pobladores etruscos en la otra ribera del Tiber y las comunidades vecinas del Aventino y el Quirinal.

—La fusión de la comunidad latina del Palatino, que acostumbraba incinerar sus muertos, con la sabina del Quirinal que los enterraba, —es decir los de Rómulo con los de Tito Tatío—, va a conformar el primer engrandecimiento de Roma, y aparece tanto en la tradición local, como resulta atestiguada por los hallazgos arqueológicos. A la unión de las colonias latino-sabinas, producida en el siglo VIII a. C., se sumará luego la influencia etrusca. Restos de una tumba nobiliaria toscana cercana al Esquilino, nombres de ese origen lingüístico como los de las más antiguas colonias, incluso el de la propia Roma y su fundador, junto a otros elementos, así lo atestiguan.

Con la irrupción y dominación de los etruscos devienen nuevos estamentos poblacionales, extensión de la ciudad, desarrollo de sus edificios, nuevos métodos de canalización y fortificación, introducción de otros dioses (Tríada Capitolina: *Juno*, *Minerva* y *Jove*); en fin, numerosos cambios en la cultura y las estructuras religioso-políticas.

Analícemos entonces las bases sobre las que se apoya la idiosincracia romana:

El espíritu religioso

“Si te sometes a los dioses reinarás” dice la última de las Odas romanas de Horacio, aludiendo a la “*religio*”.

Es este (*religio*) un concepto central en el sentimiento romano, a punto que contiene el fundamento del Imperio. Significa prestar atención a aquello que los dioses esperan de los mortales.

El destino, ése designio que se cumple inexorablemente, es comunicado a los hombres por medio de los Oráculos. La obediencia y voluntaria aceptación del “*fatum*” (destino; de “*fari*” hablar, comunicar oralmente) la realización de lo que inspira la “*religio*”, constituye la misión del romano, camino que lo conduce al dominio universal.

El descubrimiento de la existencia de una fuerza superior a la que el hombre ha de subordinarse, va acompañado de la idea de que si se somete contra su voluntad es víctima de esa fuerza; y que, en cambio, si lo hace voluntariamente se eleva a la categoría de cooperador. La cooperación da a su obrar un nuevo sentido, que le aproxima a lo divino. Lo sitúa como mediador y es el móvil de su accionar. Así el general victorioso ofrecía al dios “los triunfos que Jupiter ha logrado por mediación del pueblo de Roma”. De allí el contenido trascendente que la religión ha jugado en la evolución del Estado y la política de los romanos.

Pero no ha de creerse que solamente el culto y los ritos religiosos eran importantes; las señales divinas y las averiguaciones, consultas y toda forma de conocimiento de la voluntad de los dioses revisten una singular significación. Es el deseo de conocer el “*fatum*”, anticipar el futuro y adaptar a él su conducta. Esta actitud trae por un lado la humildad de ser instrumento de quienes rigen el destino; por otro avala el irresistible impulso de ser portadores de una misión histórica, que los conduce hacia una posición única de ser elegidos.

Hay también dos rasgos para señalar sobre los dioses romanos. Su esencia se manifiesta en forma de actos. El concepto religioso de “*numen*” caracteriza a la divinidad como actuante.

Y, por otra parte, aparecen adaptados al elemento temporal. Así fue elevado un templo a “*Fortuna hujus dei*” (la Fortuna de aquel día) referida a una victoria obtenida sobre los cimbrios.

La religión romana está siempre abierta hacia el exterior; es tolerante con ritos y divinidades extranjeras, a los que oficializa por medio de las autoridades religiosas y el Senado. Es el vínculo que une a la familia, forma la gens y la ciudad y modela el alma y el carácter del hombre.

Se ha dicho que, para el romano, su casa es un templo, con su culto y dioses; el hogar, el fuego, las puertas, los límites de sus campos son dioses; los antepasados son seres divinos, sus tumbas altares; cada acción es un rito. El nacimiento, la imposición de la toga, los primeros pasos, están regidos por una fuerza divina “*numen*”. Todo se reduce —tanto para el patricio como para el hombre del

pueblo, para los particulares como para el Estado— a inquirir la voluntad de los dioses, a interrogarlos. Todo se resuelve a través de las entrañas de los animales, el vuelo de los pájaros, los truenos, el rayo; sale de la casa con el pie derecho, usa amuletos, sólo se corta el cabello en plenilunio. . . Su pensamiento está fijo en los dioses:

"El temor a los dioses lo ha hecho señor de la tierra". (Horacio).

La fundamental virtud (de "vir" varón), para un romano, es decir aquello que le es propio y esencial entendido como práctica concreta de conducta, es la "pietas". Consiste en la aceptación y acatamiento de la voluntad de los dioses. De ello depende la grandeza del Estado y la realización personal.

Los dioses romanos aparecen concebidos a la medida de los hombres: para una concepción moderna resultarían, tal vez, más humanos que divinos. No presentan la característica de la perfección y excelsitud. Antes bien participan de los defectos y pasiones propias de los hombres.

Muchas veces, la religiosidad del romano se muestra marcadamente orientada a la búsqueda de supervivencia o el logro de su conveniencia, antes que a su superación personal.

Cierto es que lo precedentemente señalado responde a las características propias de la religiosidad tradicional, con gran influencia etrusca y griega en cuanto a dioses y ritos; sin embargo, el transcurso de los siglos produjo modificaciones en el espíritu y la concepción religiosa. Así, en épocas del Imperio (siglo II d.C.) se sigue cumpliendo con las festividades y ritos religiosos antiguos, al par que van agregándose otros de discímiles características, —especialmente por la influencia de los misterios de los dioses orientales y sectas filosóficas— en los que se busca respuesta a las inquietudes, normas de conducta y liberación del mal y frente a la muerte, aproximándose de tal manera al sentido que hoy damos a la expresión religión. Es como si la filosofía y dogmas orientales preparasen las conciencias para el acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad: el advenimiento del cristianismo.

El Romano, la Tierra, las Armas

Se ha señalado, reiteradamente que la mentalidad del hombre romano responde a la que es común a los campesinos y soldados.

Como campesino sabe de la necesidad de respetar los ciclos de las estaciones que en su suceder condicionan la labranza, la siembra y la cosecha. Sin la adecuación a la naturaleza, sin la espera paciente de su ayuda, no habrá concreción de los logros propuestos.

Su tarea política también se nota impulsada por la defensa de la tierra, de los mercados, del trabajo familiar. Así se denota que el romano participa de las virtudes que se han señalado como características del agricultor: la tenacidad, la

honradez, la previsión, la frugalidad, la independencia, la sencillez, la humildad; la confianza que el conocimiento adquirido por la experiencia vale más que la más alambicada teoría.

Y ocurre que también estas son las características del soldado, que conoce la importancia de la rutina, la disciplina, el bastarse a sí mismo. Que posee como valor el vigor, la constancia, y la habilidad práctica. Ha de trazar campamentos, abrir caminos, construir fortificaciones, vivir en el campo. Debe esperar el imprevisto que modifica sus planes.

Debe tenerse en cuenta la importancia de la agricultura: los escasos datos que se poseen permiten afirmar que los romanos de las primeras épocas bien pronto abandonaron la vida pastoril limitada al uso de algunas gramíneas silvestres. Existen noticias certeras acerca del cultivo de los cereales y las vides (los griegos nombraban a Italia como *Enotria* = país del vino), del culto a *Ceres* y *Mater Tellus* (dioses de la agricultura) de los ritos de la fundación y los evolucionados métodos que utilizaban para delimitar sus campos.

El romano, en definitiva, concibe a la agricultura como elemento básico de toda su labor. Esta palabra (agricultura) resulta clave para comprender la idiosincracia romana, ya que no debe ser tomada como un mero concepto económico. Junto a éste aspecto aparece lo espiritual, como algo no ajeno al trabajo manual. La tarea con la tierra produce un intercambio entre ésta y el hombre, que deja sobre ella algo propio de su humanidad, que le permite considerarla su "proprietaria". Incluso llega a tener trascendencia religiosa en el sentido precedentemente explicado. No ha de olvidarse la idea de "numen", de esas fuerzas divinas impersonalizadas que presiden, como a todo acto, la tarea agrícola.

Así como se siente auxiliar de los dioses en esta tarea de sembrar y cosechar, también el fundar ciudades se muestra como extensión de su inclinación a la tierra. Se advierte en el rito fundacional, la utilización del arado, la demarcación por el surco y el depósito, cual semillas de la nueva ciudad, de los objetos que representaban contenidos ancestrales, que ligan la suerte de la urbe a la de sus dioses.

Por último aparece también, en igual orden de ideas, la fundación del Imperio. Del mismo modo que como agricultor el hombre impera sobre la tierra, mandando sobre ella pero respetando los ciclos naturales, fundando ciudades, cuidando las individualidades pero dirigiéndolas hacia una empresa común, así también encaró la tarea política ordenando a los pueblos en el ideal de la "pax".

Estirpe y Estado

Se distinguen dos formas de sociedad humana: la estirpe y el Estado.

La estirpe se funda en el parentesco, su aglutinante es la sangre. En tanto, el Estado se sobrepone a los grupos naturales, manifestándose su originalidad por ser a través de un ordenamiento jurídico que somete todo caso particular a su exclusiva autoridad, eliminando las instancias intermedias.

En la Mantua etrusca las tribus comprendían estirpes distintas según la sangre.

En Roma, surgida de la fusión de pueblos itálicos, latinos y sabinos, se prescinde de la dualidad de estirpes que concurren a su formación. De modo tal que puede afirmarse que Roma nunca conformó una unión de estirpes ya que el orden estatal se sobrepuso englobando a los lazos naturales propios de la consanguinidad.

Ello se advierte cuando se analizan las subdivisiones de la ciudad en tribus, curias y decurias que van más allá de los límites de la familia y el parentesco, sin coincidir con éstos. Los hijos que en la familia están sometidos a la potestad del Paterfamilias, en los comicios y en la organización militar figuran en igual posición jurídica que sus padres.

Es posible que en la época precívica, en que grupos latinos ambulaban a la búsqueda de un asentamiento, el poder primitivo del Jefe debió reposar en su autoridad personal, carismática.

Es probable que Rómulo fuera uno de éstos, de allí la conexión que se hace de ello con el concepto de "imperium", al que se consideraba como una potestad atribuible al jefe por el hecho de serlo, en virtud de sus cualidades personales (prudencia, valor, iniciativa, piedad) y que no encuentra justificación en el ordenamiento de la "civitas". A partir de allí se sucede, en la antigüedad del Lacio, una nueva etapa en la que el poder se funda en la fuerza de la tradición y en la voluntad de los dioses (leyenda de Eneas).

Como ya se señalara, es a través de ligas de pequeñas aldeas, de "gentes", siendo su jefe el "rex", que nace la civitas.

En esa época en que el "rex" aparece como intérprete de la voluntad de los dioses y jefe militar, es aún posible encontrar empresas bélicas emprendidas por alguna "gens" individualmente (expedición de los Fabios al Cremera). El ejército de entonces está formado por los hombres de las diferentes "gens" acompañados por sus clientes, combatiendo los vecinos uno al lado de otro.

Poco a poco estas formas de carácter gentilicio fueron organizadas en base a las tribus y las curias, encuadrando así a los componentes de la ciudad.

El pueblo se dividía en tribus y en curias. Cada tribu se componía de diez curias, divisiones locales formadas por cierto número de gentes que allí se domiciliaban.

Al principio las tribus eran tres (los Ramnes, los Titios y los Luceres) para luego, en época de Servio Tulio, ser cuatro urbanas (Palatina, Suburana, Esquilina y Celica) y un número variado de rústicas.

La Organización Social: La Gens

Debe señalarse la existencia de controversias acerca de la organización social en el período previo a la fundación de Roma. Al respecto, parte de la doctrina ha afirmado que, antes de la organización de la ciudad - Estado (civitas), existía una familia patriarcal (VICO, SUMNER MAINE) después surgió la gens (agrupa-

miento de familias) y, finalmente la civitas (conjunto de varias gentes). Otra tesis (MEYER) expresa que el organismo primitivo fue la tribu, siendo gens y familia fraccionamientos de aquella, productos de su evolución. La posición que aparece con mayor adhesión es la seguida por BONFANTE, quien opina que la gens precedió a la ciudad como organismo de naturaleza política tendiente a mantener el orden y protegerse contra los enemigos externos.

Gens era un agrupamiento de familias: cuyos componentes, los gentiles, decían descender de un antepasado común, muchas veces legendario, del que recibían el nombre gentilicio. Este nombre (nomen gentilicium) y no necesariamente el parentesco consanguíneo, era el que los vinculaba.

La agrupación poseía carácter político, se asentaba en un territorio (pagus) tenía un jefe (magister gentis) costumbres e instituciones propias, asamblea (concio) y reglas de conducta (decreta gentis).

La gens no es meramente la agrupación de varias familias. Es algo más, es un verdadero *modus vivendi* de los romanos. Así, otorga protección a sus miembros y encauza sus conductas. Ello con la finalidad de amparar la integridad y asegurar la continuidad del grupo.

Por eso, si uno de los miembros de la gens caía en insolvencia, ésta le aseguraba un *vindex* (fiador) para evitar la infamia sobre el deudor.

Si un Paterfamilias se moría sin haber realizado testamento, la gens designaba tutor para los hijos del difunto, preservando de esta forma los intereses económicos del grupo.

También organiza la venganza, cuando uno de sus miembros ha sufrido alguna ofensa.

Vigila las costumbres internas sancionando a aquellos que, con su conducta, pongan en peligro su integridad.

Desde el punto de vista político, va a dirigir la conformación de los estamentos superiores del ejército y, los Pater Gentium, en origen, van a integrar uno de los organismos más representativos de Roma, como era el Senado.

Patricios, Plebeyos, Clientes

No es pacífica la doctrina que pretende examinar el origen de patricios, plebeyos y clientes. Si seguimos a MOMMSEN es posible afirmar que, en un principio, sólo había en Roma patricios y clientes. Los patricios eran quienes integraban las primeras familias romanas, que hasta el momento de surgir el Estado formaban las gentes. El cliente es un apátrida o fugado de su patria, a quien el patricio le ofrece su hospitalidad y su protección, a cambio de su trabajo. Cuando estos clientes se van independizando pasan a ser plebeyos.

En cambio, para AMBROSIONI, patricios eran los grupos de conquistadores que se habían apoderado de las mejores tierras, siendo los plebeyos quienes habían recibido las menos extensas o de menor productividad.

Aún frente a estas controversias, resulta indudable que los patricios, al menos en las primeras épocas, gozaban de ciertos privilegios que los distanciaban socialmente de los demás.

Originariamente, los patricios formaron la nobleza romana: monopolizaron el arma más codiciada del ejército, como era la caballería; ocuparon, con exclusividad, los más importantes cargos religiosos (desde el *rex sacrorum* y los colegios sacerdotales hasta los de *flamines maiores*) y detentaron la cuota más importante del poder político y del económico.)

(Patricios eran aquellos que, en sus antecesores no podían encontrarse rastro alguno de servidumbre o sujeción. No son hombres bajados del cielo, sino únicamente los que podían citar por un padre (*patrem*) a ningún otro que a los ingenuos. (TITO LIVIO; X - 3). En tanto los plebevos —dice CAPITON— son esa parte del pueblo romano (*populus romanus*) que no se halla comprendida en las gentes patricias. (AULIO GELIO; X - 20). Esto prueba que también los plebeyos formaban parte del *populus romanus* pero que no gozaban, por los menos en un principio, de todos los derechos que tenían los patricios.

Respecto a los clientes, es posible que fuesen extranjeros vencidos en guerra y sometidos a una gens por medio de la *deditio*; extranjeros emigrados que se sometían voluntariamente a la protección de una gens por la *applicatio* y los esclavos manumitidos que seguían unidos a su antiguo dueño y a la gens de éste.

Si bien no eran esclavos, su situación dista bastante de la de los hombres libres. Deben obediencia y obras a su patrono, y pueden exigirle a éste asistencia y protección. Tanto es así que en la Ley de las Doce Tablas (VIII - 21) se dispone "QUE EL PATRONO QUE DEFRAUDE A SU CLIENTE, SEA SACRIFICADO A LOS DIOS".

La estructura política de la monarquía

El Rey (Rex)

En la comunidad política romana no existe ningún jefe omnipotente. Para los romanos, el Estado es el resultado de la reunión igualitaria de los hombres libres. No hay casta alguna de origen divino. Para ellos, la concepción de Estado no puede fundarse sobre una teocracia. El Rey no era Dios, como para los egipcios o como para los orientales. El Estado surge de la familia, y toda familia debe tener un *pater*, quien debe regir sus destinos.

La autoridad del *rex* ocupará las esferas religiosas, políticas, militares y judiciales.

El *rex* era el máximo sacerdote romano. Poníase en comunicación con los dioses, los interrogaba y cumplía con sus pedidos. Organizaba y presidía toda forma de culto, en el que lo secundaban quienes integraban los Colegios Sacerdotales. Sus actos no podían oponerse a la voluntad de la divinidad, pues ir contra los deseos de los dioses era atraer la ruina sobre el pueblo.

Su *imperium* posibilitaba que tuviera bajo su mando el ejército, así como la dirección suprema de los asuntos del Estado. Organizaba y administraba la ciudad. Convocaba al Senado y a los Comicios. Ordenaba la guerra, decretaba la paz, concertando las alianzas con los otros pueblos.

Designaba los sacerdotes y los funcionarios que lo secundaban. Su auxiliar más cercano era el Tribuno Celerum (jefe de la caballería). Si abandonaba la ciudad lo reemplazaba el *praefectus urbis* (prefecto urbano).

El monarca juzgaba y castigaba a quienes rehusaban cumplir con sus obligaciones militares; conocía en las causas criminales, reprimiendo los delitos contra la divinidad, la paz y la seguridad del Estado. Para investigar estos delitos contraba con los *quaestores paricidii* (homicidio del pater) y los *Duoviri Perduellionis* (perduellio = alta traición).

Su designación, siguiendo el criterio de que la estructura originaria de poder reposaba en el esquema familiar, permitía que fuera el propio rey quien designara su sucesor, tal como el pater nombraba el suyo. Su elección debía contar con el asentimiento del Senado y los Comicios.

Si el *rex* moría sin haber elegido el nuevo monarca, era el Senado quien lo designaba de entre sus miembros, ejerciendo uno de ellos el cargo de *interrex* durante cinco días y así sucesivamente hasta que el pueblo, reunido en Comicios, eligiera el nuevo *rex*.

Por eso se caracteriza al oficio de *rex* como una magistratura unipersonal (desempeña el cargo una sola persona) vitalicia (solo la muerte terminaba con su reinado) electiva (no hereditaria) e irresponsable (no debía responder por los actos de su gestión).

Se ha dividido a la etapa monárquica en dos períodos: el de los reyes latinosabinos (Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio) y el de los de origen etrusco (Tarquino Prisco o el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio). Es con estos tres últimos que, en realidad, la monarquía asume en Roma sus caracteres más definidos. Los reyes latinosabinos en poco se distinguían de sus conciudadanos, a no ser durante el ejercicio de sus funciones militares o religiosas. La instalación de la monarquía etrusca trajo consigo los emolumentos propios del rey. Así los describe MOMMSEN: "Su traje era semejante al del más grande de los dioses; recorría la ciudad en carro, mientras que todo el mundo iba a pie; tenía un cetro de marfil, con un águila en un extremo, y las mejillas pintadas de encarnado; llevaba, en fin, corona de oro, imitando hojas de encina".

El Senado

Integrado vitaliciamente por los jefes de las gentes y los ancianos (*senes*) representaba a los grupos constitutivos de la *civitas*, y debía ser consultado por el *rex* al tomar decisiones de gravedad e importancia. Era el titular permanente de los *auspicia* y *auctoritas* (capacidad de sancionar o reforzar ritualmente los actos). Por su probidad y experiencia, asesoraba al rey en cuestiones de Estado;

si bien no intervenía directamente en asuntos militares, ni en los que atañen a la justicia, sus actos confirmaban las decisiones políticas del rex o del populus (auctoritas patrum).

Controlaba la designación del rex y aseguraba su continuidad, siendo depositario del poder político. (*Interregnum*).

Es posible que luego el rex seleccionara de entre los pater familias quienes serían senadores, no en calidad de representantes de los grupos, sino como miembros de la ciudad.

X El Pueblo: Los Comicios

Constituyen los comicios la forma más antigua que adoptaron los romanos para tomar las grandes decisiones políticas.

Durante la monarquía, los comicios reciben el nombre de curiados, ya que la organización popular proviene de las curias (de *coviria* = agrupación de varones).

Había en Roma 30 curias, correspondiendo esta división a 10 curias por cada tribu. Se ha dicho que estas tribus eran tres: los Rhamnenses latinos de Rómulo, los Titenses sabinos de Tacio y los Luceres etruscos de Lucumén.

Debe señalarse que, contrariamente a esa tesis hoy desechada, la conformación de las curias no respondía a divisiones étnicas. La primitiva dualidad latino-sabina fue superada por el surgimiento de las tres tribus que agrupaban a las curias, descartando unir las por su origen racial.

Sin embargo, lo que si cabe reiterar es que no es posible concebir la organización política romana ignorando el origen gentilicio que ya fuera puesto de manifiesto al hablar de la organización social (*gens*). Cada *gens*, en número de diez, conformaba una curia.

El comicio (de *com* - *ire* = reunión) era una asamblea que se reunía para considerar temas esenciales del pueblo romano: la designación del rex, el nombramiento de las más altas dignidades sacerdotales, la aprobación de testamentos, y otros actos de trascendental importancia, como las adrogaciones.

Por sobre todo, el comicio se ocupa de aprobar o desaprobar aquellas propuestas que le eran sometidas y que se conocen con el nombre de leyes curiadas.

Lo que conviene aclarar es que tales reuniones no se efectuaban sino había una convocatoria, que requería una previa consulta a los augures, quienes determinaban si los auspicios eran favorables a la reunión del pueblo.

Esta distribución por curias va a ser modificada cuando, durante el reinado del penúltimo rey, Servio Tulio, aparecen los llamados comicios centuriados, que sólo llegan a funcionar plenamente en la posterior etapa republicana.

X Los Colegios Sacerdotales

El culto público, que dependía del Estado, estaba a cargo de cierto número de oficiantes y cofradías religiosas.

El rex era el primero en la jerarquía sacral —*rex sacrorum*— quien presumiblemente en épocas precívicas estaba rodeado de un cuerpo de sacerdotes.

Debe advertirse que, a diferencia de otros pueblos, en la religión romana cada sacerdote, cada colegio, tenía competencia específica particular. No era posible al hombre dirigirse a los dioses sin tener a su lado el consejo de quien conocía el lenguaje adecuado para tal comunicación. Por eso los expertos agrupaban en colegios, convirtiéndose en los depositarios de las ciencias y procedimientos del arte.

Detrás del rey venían los "Flamines mayores", que no constituían colegio, siendo cada uno de ellos autónomo.

Los había de Júpiter (*Flamen Dialis*), de Marte y de Quirino.

Había también doce flamines menores, dedicados a divinidades que fueron cayendo en desuso ya en la época clásica (*Volcanus, Palatua, Voltumnus, Carmentis, Flora, Pomona*). Estos sacerdotes —tanto los mayores como los menores— desempeñaban su oficio careciendo de poder para resolver situaciones que excedieran los rituales corrientes, ya que eran solo los augures quienes inquirían e interpretaban la voluntad de los dioses.

Colegio de los Pontífices: No son bien conocidos sus orígenes, siendo sin duda muy antiguo. Lo integraban cinco miembros, a los cuales se agregaban el *rex sacrorum* y los flamines mayores.

Tomaban ese nombre (*pons/ponti* = puente; *facere* = hacer) por ser los constructores y custodios del puente sobre el Tiber, totalmente construido en madera por razones rituales, al que debían montar y desmontar.

Sabían acerca de medidas y números. Por tal razón estaba a su cargo la confección del calendario, donde se determinaba cuales días eran fastos y cuales no (nefastos); resultando los primeros aquellos con significación religiosa y jurídica, siendo aptos para la celebración del culto y válidos para los procedimientos y actos judiciales.

Fundamentalmente los pontífices tenían ingerencia en las cuestiones atinentes al derecho privado. Eran depositarios de las fórmulas y declaraciones solemnes que debían expresarse en juicio, así como las disposiciones atinentes a los rituales religiosos.

Se expedían acerca del matrimonio, testamentos y adrogaciones y dictaban las normas que regían el culto.

Ya durante la república asume el pontífice máximo las funciones religiosas que fueran del rex; crea a los flamines mayores y a las vestales, sobre quienes ejerce poderes disciplinarios.

Colegio de las vestales: Estaba integrado por seis sacerdotizas consagradas a la diosa Vesta, cuya misión era mantener permanentemente encendido el fuego sagrado. Eran elegidas por el Colegio de los Pontífices cuando tenían entre tres y seis años de edad y quedaban consagradas por treinta años.

Cuidaban el fuego sagrado de la ciudad, que nunca debía extinguirse. Su deber religioso dependía de su virginidad; si faltaba a ella era enterrada viva en una cavidad subterránea.

— Colegio de los Augures: Es también un colegio muy antiguo, que gozaba de independencia en forma paralela con el de los Pontífices. No tenían por función determinar, descifrar el porvenir, sino que debían interpretar si tal o cual proyecto era conforme al Fas (por ejemplo: elegir el lugar de culto, designar un funcionario religioso).

Su método y técnicas desarrollados desentrañando los prodigios (ruidos subterráneos, animal nacido con dos cabezas, rayo caído sobre un templo, etc.) o examinando las entrañas de las víctimas, eran de origen etrusco (Si "Fast et. . ." envía tal signo).

Los oráculos, que devenían de directa inspiración de un dios, estaban bajo el control y dependencia del Estado. Así los libros Sibilinos que se entendían contenían secretos referidos al futuro de Roma, eran guardados celosamente y consultados únicamente en casos de peligro extremo, estando al cuidado de una comisión de dos miembros (*duumviris sacris faciendis*) que luego se aumentarán a diez (*decemviris sacris faciendis*) y después a quince (*quindecimviris sacris faciendis*).

— Colegio de los Feciales: Lo integran veinte sacerdotes. Su función es relativa a las relaciones de Roma con otros pueblos, estando a su cargo la sacralización y ritos para la declaración de paz o guerra y los tratados con otras ciudades. Advertían a los romanos sobre la inviolabilidad de los acuerdos. Las ceremonias de la declaración de guerra aparecen relatadas por TITIO LIVIO (I, 32) y AULIO GELIO (XVI, 4) quienes dan cuenta que una vez que el Fecial había agotado los reclamos al pueblo enemigo, sin obtener la reparación de los agravios que entendía Roma se le habían infligido, cumplido el plazo y declarada la guerra a instancias del Senado, frente al enemigo arrojaba una lanza sobre el territorio de éste y decretaba formalmente el comienzo de las hostilidades, con lo cual la guerra era justa (*iustum bellum*).

Colegio de los Salios: (*Salii* danzantes). Se repartían en dos grupos: de Marte y de Quirino, de doce miembros cada uno. Actuaban en marzo y octubre, y cuando se pasaba de paz a guerra, o de guerra a paz. Su símbolo sagrado era el escudo (*ancile*) caído durante el reinado de Numa Pompilio, el creador de este Colegio, quien mandó construir otros once iguales, confiándolos a la custodia de los sacerdotes salios.

Colegio de los Arvales: Lo integran doce sacerdotes, a quien se conocía como los doce hermanos de los campos (*fratres arvales*). Eran los encargados de pedir los favores de la diosa fecunda (*Dea* la Diana, a fin de que les prodigase buenas cosechas).

Tanto en el culto público como en el privado el sacrificio consistía en la oblación de materia alimenticia (primicias de cereales, vino dulce, animales b ovinos - excepto el caballo de octubre). A los dioses se reservaba el hígado, pulmones, corazón y algunas otras porciones, que se quemaban en el altar. El resto era consumido por el sacrificador y sus compañeros en el culto privado, y por los sacerdotes en las ceremonias públicas.

Reformas de Servio Tulio

Se conoce con el nombre de reforma serviana, o reformas de Servio Tulio a una modificación en la organización político militar que se ha atribuido al seno de los reyes etruscos.

En realidad es durante la república que la totalidad de los individuos libres - patricios, clientes, plebeyos - participarán paulatinamente en la milicia y los comicios.

La leyenda ha señalado que ya Tarquino el Antiguo, para contrapesar la influencia del patriciado que le era hostil, habría intentado la fusión de nuevos elementos dentro del Estado. Un primer intento de añadir tribus a las tres primitivas (Luceres, Tities y Ramnes) habría naufragado ante la oposición fundada en razones religiosas que habrían opuesto los augures.

Su sucesor, Servio Tulio, inició la modificación de las antiguas bases del Estado. Estableció el censo poblacional, debiendo inscribirse en él la totalidad de los paterfamilias, denunciando el número de los libres bajo su potestad, esclavos y bienes de su pertenencia.

Sobre la base de dicho empadronamiento se distribuían las cargas públicas, los deberes militares, el tributo y la participación de las asambleas populares.

La primitiva distribución en tribus es modificada, ya que ahora estas serán circunscripciones territoriales, órganos administrativo - políticos. Así la ciudad es dividida en cuatro tribus urbanas: palatina, suburana, esquilina y collina.

A su vez la comarca es dividida en un número, que fue variando, de tribus rústicas, cuyos nombres derivarán de los antiguos pagos (*pagi*) o de las gentes principales allí establecidas: Aemilia, Claudia, Cornelia, Galeria, Papiria, Voltinia, Veturia, Horatia, etc.

Se admiten en las tribus junto a los miembros de las gentes patricias a los plebeyos; si bien durante un tiempo (al parecer, hasta la censura de Apio Claudio) solo serán integrantes de las tribus (*tribules*) los propietarios de fundos.

El ejército, primitivamente organizado sobre la base de tribus y curias que hizo ensar a los eruditos que se trataba de contingentes pertenecientes a las tribus más que a la civitas, será modificado.

El censo determinaba, según la entidad de los bienes poseídos, la pertenencia a una de cinco clases. La riqueza se considera según la propiedad fundiaria.

Pertenecen a la primera clase los poseedores de 20 yugadas (la yugada equivalía aproximadamente a un cuarto de hectárea = 25,082 áreas) o su equivalente: 100.000 ases; la segunda clase 15 yugadas = 75.000 ases; la tercera 10 yugadas = 50.000 ases; la cuarta 5 yugadas = 25.000 ases; y la quinta 2 yugadas (mínimo de las entregadas por Rómulo al dividir el heredium) = 12.500 ases. Hay que señalar algunas diferencias al considerar la cantidad de ases, según los diferentes autores.

Cada clase estaba compuesta por un número desigual de centurias; la mitad de jóvenes (*juniores*, de 17 a 46 años) y la otra de mayores (*seniores*, de 46 a 60 años).

La primera clase era integrada por 80 centurias; la segunda por 20, al igual que la tercera y cuarta; la quinta por 30. Precedían a la primera clase 18 centurias de caballeros (*equites*), cuyas seis primeras conservaban el carácter patricio (*sex suffragia*) y las restantes conformadas por miembros de las familias más acaudaladas. Además había cierto número de centurias formadas por aquellos que poseían bienes mobiliarios de más de 1500 ases, siempre que fuesen contribuyentes: dos centurias de herreros, dos de sonadores de trompetas y cuernos; y una de personal complementario no armado. Es decir un total de 193 centurias.

Además los *infra clasem*, o sea aquellos cuyo patrimonio no superase los 1500 ases, estaban exentos del pago de impuestos y solo contribuían con sus personas e hijos (*proletarii*).

Como se advierte nace una nueva forma de distribución de las obligaciones militares y de la tributación, como así también un nuevo tipo de asamblea: el comicio centuriado, que recién puede verse funcionando plenamente durante la república.

Las Fuentes de Derecho

Las Mores Maiorum: Las *mores maiorum* (costumbres de los mayores, de los antepasados) resultan ser la fuente primera y única del arcaico Derecho Romano. Esta afirmación, en su simpleza, no expresa adecuadamente la exacta dimensión e importancia de las mismas en el desarrollo posterior del derecho.

Las *mores maiorum* conformaron la estructura de todo el derecho romano primitivo, yendo a plasmar el máximo monumento legislativo de la antigüedad; la ley de las Doce Tabas.

De ninguna manera puede afirmarse que los principios en que se basan las originarias instituciones del derecho romano, provengan de un tácito consenso del pueblo. Así se ha dicho que *mores maiorum* son las formas en que los antiguos solían conducirse. Su interpretación es el resultado de una prolija elaboración por parte de quienes saben adaptar las conductas a las primitivas formas de organización social. En este sentido ya se ha expuesto en forma reiterada el ascendido sentimiento religioso del pueblo romano, que contribuyó a dar vida a las primeras instituciones jurídicas.

Por eso no puede desconocerse que las primitivas pautas que gobernaban las instituciones estuviesen altamente influenciadas por esta concepción.

Las *mores maiorum* son producto de una verdadera relación entre el hombre y los dioses. Relación ésta que reconoce como mediadores a los sacerdotes y que va a ir produciendo una serie de normas que formaron el viejo derecho (*ius quiritium*).

Todo pueblo desarrolla una serie de hábitos, de costumbres, que son aceptadas por la comunidad, aún antes de que oficialmente lo sean por los órganos del Estado.

En el caso de Roma, serán los Pontífices quienes interpretarán y orientarán estas costumbres, imponiendo algunas y desechando otras. Y así lo afirma Pomponio (D. 1, 2, 2 (1)).

"En el comienzo de nuestra ciudad el pueblo se constituyó sin una ley determinada..."

Las Leyes Regias: Algunos autores, ubicándose en posiciones hoy insostenibles, llegaron a afirmar que estas leyes regias, cuya recopilación se atribuye a Sexto Papirio, de quien se dice fuera Pontífice máximo en el último período de la monarquía etrusca, eran las que proponía el rex al comicio curiado.

Esta recopilación de leyes, que es conocida como "*ius papirianum*", debida a su preteso autor, no puede aceptarse sin discusión, por el hecho de que la misma se debería a la obra de Graciano Flacco, pues no se ha comprobado la existencia de ningún Pontífice llamado Sexto Papirio durante el reinado de Tarquino el Soberbio.

En realidad, estamos frente a disposiciones dictadas durante la monarquía y que versaron, predominantemente, sobre temas de índole religiosa, y que bien podrían provenir del Colegio de los Pontífices.

En suma, estas pretendidas leyes regias no son tales ya que, por su origen y su temática, y no habiéndose probado que se sometieron a los comicios, serían meras disposiciones de contenido sacral, sin valor legislativo.

Capítulo 3

FRANJA MORADA

SUMARIO:

- I. Un estado dentro del estado - Conflicto patricio - plebeyo.
- II. Las magistraturas.
- III. Magistraturas ordinarias.
- IV. Magistraturas extraordinarias.
- V. Magistraturas plebeyas.
- VI. El senado republicano.
- VII. Los comicios.

X EL FIN DE LA MONARQUÍA. "RES PUBLICAE"

"... Plugo al pueblo transformar el poder de perpetuo en annuo y vincularle en dos individuos, en lugar de uno, para que no se corrompiera ~~perpetuando~~ uno solo y prolongándose el tiempo de su ejercicio.

Sustituyó asimismo el nombre de reyes con el de cónsules, a fin de que tales magistrados tuvieran entendido que solo debían tener presente en su decisiones los legítimos intereses de sus conciudadanos".

("Gestas romanas"; Lucio Anneo Floro, cap. IX).

La tradición romana gustaba describir el fin de la dominación etrusca en forma de una revuelta popular ocurrida en el 509 a. C., motivada por el aborrecimiento a Tarquino el Soberbio. Este, a quien consideraban arribado al trono sin derecho y ejerciendo el poder injusta e innoblemente, provocaba el rechazo del pueblo romano; que dirigido por Lucio Bruto y Tarquino Colatino, había culminado por expulsarle. Ello como corolario de la afrenta a la matrona Lucrecia, quien deshonrada por un descendiente del rey había terminado por suicidarse.

A partir de estos hechos la monarquía había sido abolida y reemplazada por las magistraturas, órganos de gobierno característicos de la República.

Si bien por la fecha indicada se produce en la península un franco retroceso de la dominación e influencia etrusca, como así la agregación a Roma de gentes nuevas de origen sabino, que habrían contribuido al desplazamiento de la dinastía, (así "Atta Clausus" - pater Claudius, es admitido en el territorio romano en el 504 a. C.; y en ese tiempo también aparecen nombres de familias sabinas como los Valerios, Claudios y Lucrecios, junto a las gentes latinas de Emilios, Horacios, Julios y otros) lo cierto es que parece difícil que las cosas ocurrieran de tal forma.

Llama la atención que justamente quienes aparecen liderando las acciones pertenezcan a la familia real; siendo Bruto hijo de una hermana del Soberbio, y Colatino de la misma gens.

Como también es llamativo que la expresión "rex", aparentemente tan aborrecida haya perdurado en el "rex sacrorum" o "sacrificulus", dignidad ~~sacra~~

tal primera en jerarquía, que precedía a flamines y Pontífice máximo, siendo inviolable y vitalicio, sobreviviendo hasta el Imperio.

Asimismo, desplazado Colatino y muerto Bruto, uno de los Cónsules designados: Publio Valerio, llamado Publícola, gobernó largo tiempo solo, con las características de un verdadero "rex", llegando incluso a construirse una mansión en una altura —especie de fortaleza— que luego ordenó destruir por las suspicacias despertadas por tal actitud.

De entre las múltiples tesis y posturas puede extraerse como muy posible que frente al retroceso etrusco, se produjesen levantamientos e insurrecciones en las poblaciones del Lacio.

En Roma las gentes más antiguas, unidas a otras de integración más reciente (sabinas y aún etruscas) reorganizaron el Estado; produciéndose los cambios de Monarquía a República de modo gradual y progresivo.

Un Estado dentro del Estado - Conflicto patricio-plebeyo

³También luchó el pueblo romano, traspasando los límites del bien y la justicia, con el Senado, de tal manera que, abandonando sus moradas, amenazó sumir a la patria en la soledad y la ruina" (Lucio A. Floro, "Gestas Rom.", cap. XXI).

— La división entre la nobleza y los ciudadanos carentes de derechos políticos había existido desde muy antiguo.

Al comienzo de la República sólo los patricios eran nobles y gozaban de privilegios políticos y religiosos, como la elegibilidad en las Magistraturas superiores y funciones religiosas, ejerciendo su poder opresivamente.

La tradición habla de un gran descontento popular, atribuible en parte a la gran recesión económica devenida en el siglo V a.C., que produjo endudamiento, en especial a los pequeños granjeros. El rigor del "nexum"; las altas tasas de los intereses; el disfrute del "ager publicus" por los patricios —tomada en arrendamiento mediante el pago de mínimos vectigales, muchas veces insatisfechos— resultaban cada vez más intolerables a los plebeyos.

Las guerras sin interrupción y sin progreso para los pequeños granjeros y artesanos; que disminuían sus esfuerzos y trabajo por largos períodos; sus fundos de explotación familiar, con poca o nula participación de esclavos afectados a ella, situados en los confines del territorio y sujetos a la devastación; hacían que los plebeyos se vieran impulsados a endeudarse, lo que les acarreaba luego inhumanas ejecuciones privadas.

— La acumulación de estas circunstancias, que algún autor ha calificado como la cuestión de las deudas, la cuestión agraria (reclamo de tierras) y la cuestión frumentaria (abastecimiento de viveres) provocará que la plebe —elemento indispensable en la integración del ejército— se constituya como cuerpo político.

Adquiere la forma de comunidad de conjurados o "lex sacra" institución conocida en la Italia primitiva. Su objeto era la constitución como cuerpo de ele-

mentos ligados entre sí por un juramento, que lo hacía muy apto para la lucha de clases y la guerra civil. En Roma va a presentar características distintivas por desechar la lucha armada y su continuidad en el tiempo; llegando a constituirse en un estado dentro del Estado.

Al producirse en el 495/494 a.C. una leva, exasperadas las clases —empobrecidas por el rigor de los acreedores— se negaron a salir a campaña. El Cónsul logró persuadirlos suspendiendo los procedimientos judiciales, liberando a aquellos encarcelados por deudas y prometiendo cambios. Sin embargo al tiempo de terminar la campaña, estando el ejército reunido a las puertas de la ciudad, negóse el Senado a aceptar sus reclamos, con postura intransigente. Abandonó la tropa a sus jefes y dejó el campamento con sus armas, conducidos por los Tribunales militares, plebeyos en su mayoría. Se retiró a Crustumeria, entre el Tiber y el Anio, y se instaló en una colina, el Monte Sacro o el Aventino. En la ciudad solamente quedaron los patricios con sus clientes. Esto motivó gestiones de los Senadores, quienes con concesiones y la aceptación de la institución del Tribunado lograron el regreso de la Plebe. Tal la versión de las fuentes antiguas; de las que también resultarían tres las veces que los plebeyos se retiraron de la ciudad, amenazando fundar una nueva. Sólo de la última existen indicios históricamente válidos.

Después de un largo proceso, iniciado con el reconocimiento de la institución de los Tribunales y los Concilia Plebis, posiblemente mediante sagrado juramento individual de los ciudadanos a Ceres —diosa plebeya— y Jove (Júpiter), va a llegarse gradualmente a la integración de la "civitas".

Durante éste irá gradualmente lográndose la equiparación de ambas clases, al acceder los plebeyos a las magistraturas antiguamente reservadas a los patricios (que culmina al llegar Tiberio Coruncanio a Pontífice máximo); lograr la capacidad para contraer nupcias ("connubium"); conseguir la abolición del "nexum" y la primera ley escrita (Ley de las XII Tablas); y el asiento igualitario en el Senado.

Las Magistraturas

Sus Caracteres

Hacia el 509 a.C. una nueva conformación política puede observarse en la vida romana. Destituido Tarquino el Soberbio, la estructura socio-política sufre profundas transformaciones. Aparecen nuevas magistraturas, se modificarán los comicios y será distinto el Senado. En esto tienen mucho que ver los conflictos que se acaban de examinar.

En realidad la aparición de las magistraturas republicanas se produce gradualmente. Los magistrados van a reemplazar al rey en sus poderes absolutos. Estamos aquí frente a una redistribución del poder, que ya no ejercerá un solo funcionario, sino que se divide entre varios magistrados.

Los nuevos funcionarios ejercerán el poder en forma colegiada, temporal, honoraria, responsable y electiva.

Colegiadas ya que las magistraturas aparecen integradas por dos o más funcionarios, que ocupaban simultáneamente el mismo cargo.

Temporales, pues a diferencia del rex (vitalicio) las magistraturas republicanas tenían prefijado el lapso de duración. Generalmente eran anuales.

Honorarias, ya que los magistrados no percibían suma alguna por el desempeño de sus tareas, entendiéndose que la retribución era el honor de las funciones ejercidas.

Responsables, pues podían ser sometidos a exámenes de responsabilidad a fin de dar cuenta de aquellos hechos que hubiesen sido contrarios a un buen desempeño.

Electivas, atento a que, si bien era el mismo magistrado quien proponía su sucesor, el comicio era el que aprobaba o desechaba la designación. Por lo general esta propuesta se elevaba a la Asamblea popular cuando promediaba el mandato del magistrado.

Clasificación de las Magistraturas

Es posible hoy clasificar las magistraturas respondiendo a diversos criterios. Algunas de estas clasificaciones no son romanas sino que enfocan el problema siguiendo pautas modernas.

Para DE FRANCISCI, la división más importante es la que corresponde a las magistraturas cum imperio y las sine imperio.

El *imperium* es la potestad que ejerce el magistrado sobre el pueblo y que le permite tener poder soberano, unitario y absoluto.

Otra clasificación es la que distingue entre magistraturas ordinarias y extraordinarias. Mientras aquellas corresponden a tiempos de normalidad y, generalmente, anuales.

Las extraordinarias fueron creadas para afrontar circunstancias excepcionales. Son Ordinarias el consulado, la pretura, la cuestura, el edilato curul y la censura.

Las Extraordinarias: la dictadura, el decenvirato legibus scribundis, el triunvirato rei pública constituendae y el tribunado militum consulari potestate.

También es posible distinguir entre magistraturas mayores y menores. Se funda esta división en el hecho de poseer el funcionario los auspicios mayores o menores.

Magistraturas mayores eran, entre las ordinarias, el consulado, la censura y la pretura. Y entre las extraordinarias: la dictadura, el decenvirato, el triunvirato y el tribunado militar con potestad consular.

Son Menores todas las demás. La trascendencia de la clasificación radica en que la elección de los magistrados mayores era propuesta a los comicios centuriados, en tanto la de los menores lo era ante los comicios tribados.

No ha de confundirse la distinción precedente a la referida a magistraturas Curules y No Curules, según tuvieran o no los magistrados derecho a la *sella curulis* (silla curul). Poseían tal prerrogativa, además de los magistrados mayores, el edil curul que se distingue así del edil plebeyo.

Además de las señaladas, cabe distinguir entre Magistraturas Patricias y Magistraturas Plebeyas, nacidas a consecuencia de las luchas protagonizadas por ambos sectores. Sin olvidar el paulatino ascenso de los plebeyos a aquellas magistraturas antaño reservadas exclusivamente a los patricios. Fueron magistrados plebeyos el tribuno de la plebe y el edil plebeyo.

Análisis de las diversas Magistraturas:

Magistraturas Ordinarias

Los Cónsules

En cuanto al origen de esta magistratura no existe acuerdo entre los autores para establecer en que momento aparecen los cónsules.

Aparentemente estos magistrados ya existían en la época monárquica como auxiliares del rex en sus funciones militares, y con el correr de los tiempos fueron ampliando la esfera de sus atribuciones, desplazando cada vez más al monarca hasta que éste fue desprovisto de sus poderes, conservando solo el que atañe al culto y convirtiéndose así en el *rex sacrorum*.

Lo que si se sabe es que en épocas remotas, se los denominaba pretores máximos (entre otros: Tito Livio 7, 3, 4).

La duplicación de las legiones hizo necesaria la dirección separada de cada una de ellas, lo que determinó la existencia de dos magistrados con iguales funciones y atribuciones, posible origen del carácter colegiado. Sobre el punto hay quienes llegan a sostener que, en realidad originariamente los cónsules eran tres: dos dedicados a las tareas militares y un tercero que se ocupaba de solucionar los conflictos entre los particulares. (*Colega Minor*, después *Pretor*).

Lo cierto es que, a posteriori, la colegiación debe entenderse desempeñada alternativamente por cada uno de los cónsules, utilizándose turnos mensuales en los cuales uno estaba en actividad y otro en receso, poseyendo el último *intercessio* (veto) sobre las decisiones del primero. En casos de suma importancia o gravedad, podían los turnos ser diarios (tiempo de guerra).

Como ya dijéramos esta magistratura mayor gozaba de *Imperium*. De él se derivan las siguientes facultades:

- los Auspicia: como poder de inquirir la voluntad de los dioses.
- el Mando Militar: posible origen —como se señalara— de la magistratura.
- la Jurisdicción Civil y Penal: que se modificará con la aparición de los pretores. Ello sin olvidar las funciones delegadas a los cuestores para la investigación en los casos de parricidio, sacrilegio y perduello (alta traición) como ya se viera en la época monárquica.



d) *Ius Edicendi*: derecho de dirigirse al pueblo mediante órdenes, disposiciones, etc.

e) *Ius Agendi Cum Populo*: derecho de convocar y presidir los comicios y presentar ante ellos proyectos.

f) *Ius Agendi Cum Patribus*: derecho de convocar y presidir el Senado.

g) *Ius Referendi*: derecho de presentar los temas a tratar por el Senado.

Esta magistratura era anual (prorrogable por circunstancias especiales de orden militar) y colegiada (integrada por dos colegas); para el caso de fallecimiento de uno de los cónsules quedaba a criterio del restante proponer la designación de un nuevo colega para terminar el mandato (*Consul Suffectus*). En caso de vacancia total sin designación de sucesores actuaba el *interrex*.

También este magistrado poseía la facultad de proponer la designación de los nuevos cónsules, pretores, ediles, censores y cuestores. Para ello convocaba y presidía los comicios centuriados o tribados, según el caso. De la primitiva amplitud de funciones, fueron perdiendo los cónsules las facultades del censo, la jurisdicción civil y limitaciones en la órbita territorial, al atribuirse las provincias a otros magistrados.

Siendo originariamente el Consulado una magistratura patricia, la *Lex Licinia* (367 a.C.) permite el acceso a los plebeyos. Recién en el 342 a.C. se permitirá la designación de dos plebeyos en forma simultánea, es decir ambos cónsules. Este hecho se concretará en el 172 a.C.

Los Pretores

Tal vez, a los efectos de nuestro estudio, sea ésta la magistratura que reviste mayor interés, dadas las tareas que desempeñaban estos funcionarios.

El pretor aparece, aproximadamente, en el 367 a.C. como magistrado único con carácter de colega menor de los cónsules (*colega minor*) quienes delegaron en él parte de sus funciones.

Posteriormente fue necesario instituir un nuevo pretor que por desempeñar su tarea para los peregrinos va a recibir la denominación de pretor peregrino (242 a.C.) en tanto aquel que las ejercía respecto de los ciudadanos es conocido como pretor urbano.

Posteriormente su número fue aumentando, llegando a ser ocho en tiempos de Sila y dieciséis en épocas de Julio César.

Los pretores actuaban individualmente, no en forma colegiada, teniendo cada uno competencia propia asignada por sorteo.

Como ya se señalara el pretor, magistrado mayor, goza del *imperium*; incluso llegó a ejercerlo, a falta de los cónsules, en las cuestiones militares.

Además el *imperium* le permitía convocar los comicios y al Senado (*imperium militiae, ius agendi cum populus et cum patribus*).

Por el contrario, los cónsules, a partir del nacimiento de la pretura no poseen la jurisdicción civil, pudiendo solo ejercitar su *intercessio* ante los actos singulares del pretor.

La función específica del pretor fue la de solucionar los conflictos que se suscitaban entre los particulares (*iurisdictio*).

Cuando la relación conflictiva se planteaba entre ciudadanos romanos el señalado para intervenir era el Pretor Urbano, quien debía aplicar estrictamente el derecho civil.

En cambio, cuando el pleito se generaba entre ciudadanos romanos y peregrinos, o entre estos últimos, el llamado a dirimir la controversia era el Pretor Peregrino, quien basándose en la equidad, resolvía el diferendo de acuerdo a reglas que él mismo creaba.

El pretor iba en auxilio de los particulares modificando, en ocasiones, mejorando o completando el derecho civil, cuando las circunstancias del caso así lo imponían.

De esta forma remediaba injustas situaciones no contempladas equitativamente por el derecho civil, o no previstas por éste.

La obra de este magistrado se traduce, principalmente, en su Edicto, fuente de derecho que trazó nuevos rumbos en la tarea de administrar justicia.

El ingreso de los plebeyos a esta magistratura se producirá en el año 337 a.C.

Los Censores

La tarea del censo, creado por el sexto rey romano Servio Tulio, va a ser transferida luego, en la etapa republicana, primero a los cónsules y por éstos delegada a una nueva magistratura: la CENSURA. Se considera que tales funciones se desmembraron a partir del año 443 a.C.

Eran magistrados mayores, ordinarios, no permanentes que carecían de *imperium*, no obstante lo cual van a llegar a poseer amplio poder político.

Se elegían en los comicios centuriados a propuesta de los cónsules.

En un principio duraban el tiempo que va de un censo a otro (5 años). La ley Aemilia (435 a.C.) la fijó en los 18 primeros meses del lustro, que podía reducirse si se terminaba la tarea, pero no podía prorrogarse aún cuando el censo quedase inconcluso.

Si bien la labor de confección del censo poseía trascendencia en el plano político, militar y tributario —cabe señalar que durante el mismo debía anotarse a los ciudadanos a fin de determinar su número y aptitud contributiva en base a la cual se distribuiría la carga militar, la conformación de los comicios por centuria, el orden de votación en los mismos, etc.

Es con las nuevas funciones que se le suman durante la República que su importancia llegará al punto más alto.

A aquella misión de fijar la situación patrimonial y personal de los individuos, se agregó la custodia de las costumbres (*cura mores*) y la confección de la lista de candidatos al Senado (*lectio senatus*).

La Cura Mores llevaba al censor, en preservación de las instituciones de la República, a controlar el honor y dignidad de los ciudadanos, sancionando las conductas contrarias a los valores y virtudes propias de los romanos. Así resolvía sin apelación sobre los derechos políticos y honoríficos de los ciudadanos, imponiendo la infamia censoria.

Aquellos por el censor considerados indignos, eran excluidos de las centurias y privados del IUS HONORUM (que permitía el acceso a las magistraturas) el IUS SUFFRAGII (participación en las asambleas del pueblo) y del rango militar.

La Lectio Senatus es consecuencia de la lex OVINIA (312 a.C.) que los facultaba a confeccionar la lista de ciudadanos en condición de ser elegidos senadores. Estos habían perdido su condición de vitalicios, al hacerse la lista cada cuatro años.

En el año 351 a.C. aparece el primer censor plebeyo.

Los Cuestores

Ya en el período monárquico existían funcionarios, llamados cuestores, que auxiliaban al rex en ejercicio de la represión criminal (*cuestores parricidii*).

Durante la República (509 a.C.) aparecen como magistrados republicanos con carácter de meros auxiliares de los cónsules, designados por éstos previa interrogación a los comicios centuriados o tribados.

Duraban un año siendo inicialmente dos, para elevarse a cuatro al disponerse que dos acompañarían a los cónsules en las funciones de la ciudad y dos en las campañas militares (420 a.C.). Es en ese momento en el que los plebeyos logran el acceso a la cuestura, hasta entonces reservada a los patricios. Su número seguiría incrementándose llegando a ser 40 en época de César.

Se trata de una magistratura menor, ordinaria, que carece de imperium y de potestad coercitiva, cuya importancia se vio incrementada por el mayor desarrollo de los negocios públicos.

Sus funciones aparecen dirigidas hacia dos ámbitos: el de la administración financiera y el atinente a la instrucción de procesos capitales. La custodia del erario público se amplía luego hacia la administración y vigilancia de las tareas portuarias, los acueductos y el erario militar.

Los Ediles

El edilato comprende dos magistraturas: la de los Ediles Plebeyos y la de los Ediles Curules. Los primeros nacen al mismo tiempo que los Tribunos de la plebe (494 a.C.) como sus auxiliares, encargados de ejecutar sus resoluciones y custo-

diar el templo de Ceres. En el 367 a.C. nacen los ediles curules como magistratura patricia, ingresando en ella, luego de tres años, los plebeyos.

Se la llamó curul porque a estos magistrados les estaba permitido el uso de la silla jurisdiccional o curul (*Sella Curulis*) privilegio de los *populi romani*.

Los plebeyos eran elegidos en los *concilia plebis* y los curules en los *comicios tribados*.

Estos magistrados de rango intermedio entre pretor y cuestor, se desempeñaban en la ciudad durante un año, careciendo de imperium.

Sus atribuciones estaban orientadas hacia el control urbano:

a) Cura Urbis: cuidado de la ciudad (ornato, vigilancia nocturna, habitabilidad de los edificios, orden y moralidad públicos, socorro contra incendios).

b) Cura Annonae: policía de mercados (control de precios; vigilancia sobre las condiciones en que se vendían objetos, esclavos y animales; distribución de trigo entre los pobres = *frumentarios*).

c) Cura Ludorum: control y contrataciones en los espectáculos públicos.

d) Edictos de los Ediles: publicaban reglamentaciones relativas al comercio y a la tranquilidad pública.

Magistraturas Extraordinarias

a) El Dictador

Uno de los objetivos primordiales de la caída de los reyes había sido evitar la concentración del poder en una sola persona. Sin embargo, durante la república, se hace necesario, en circunstancias excepcionales, que se suspendan todas las garantías de libertad ciudadanas y que exista, en estos casos, una magistratura no colegiada: la dictadura.

Si la situación revestía características de extrema gravedad (entre otras causas: conmoción interna o peligro de guerra) los dos cónsules debían resignar sus poderes delegándolos en el dictador.

La magnitud del poder que se otorgaba al dictador (también llamado PRAETOR MAXIMUS o MAGISTER POPULI, al igual que el rex) era de gran amplitud.

No obstante se hace necesario señalar sus dos aspectos esenciales: No era un cargo vitalicio, siendo su duración aún más breve que la de los magistrados ordinarios (sólo permanecía en funciones mientras subsistiesen las causas excepcionales y hasta un plazo máximo de seis meses. Salvo que, antes de cumplirse este lapso; expirase el mandato de quien lo había designado, cesando con él).

Por otra parte, no podía nombrar su sucesor.

Durante la vigencia de la dictadura, todos los magistrados le quedaban subordinados.

El dictador no era elegido por el pueblo, sino que eran los cónsules quienes lo designaban. Incumbía también su designación, excepcionalmente, al Tribuno Militar con potestad consular.

En la práctica, sus poderes no eran absolutos: se limitaba a la ejecución de aquellas medidas más urgentes relacionadas con los conflictos internos o externos que, en ocasiones, acuciaban a Roma. Durante su mandato, se suspendía la *provocatio ad populum* y la *intercessio*.

En sus funciones, al igual que el rex, era asistido por un jefe de caballería (*Magister Equitum*).

No obstante, resultando esta magistratura contraria a los principios republicanos, es que, durante las Guerras Púnicas (264 a 146 a.C.) la elección se efectuaba por el pueblo reunido en comicios.

En el 356 a.C. había llegado a ella el primer plebeyo (MARCIO RUTILIO).

En el 43 a.C. es abolida definitivamente (Syla y Julio César habían intentado perpetuarse en ella).

b) El Prefecto Urbano (*Praefectus Urbi*)

Esta magistratura, que naciera durante la monarquía para auxiliar al rex, continuó en la etapa republicana con las mismas funciones.

El *Praefectus Urbi*, magistrado extraordinario y unipersonal, era designado por los cónsules para reemplazarlos si ambos salían de Roma.

Suplía la autoridad de los cónsules en la custodia de la ciudad, evitando, de esa manera, que quedara sin jefe inmediato, especialmente en lo que se refiere a la tarea de administrar justicia. Esta última función desaparece con la creación de la pretura.

c) Los Decemviratos Legislativos (*Decemviratus Legibus Scribundis*)

En el año 445 a.C., ante insistentes presiones de los plebeyos en pos de la redacción de un cuerpo escrito de leyes, se crea esta magistratura extraordinaria, designándose 10 magistrados patricios (*decemviri*).

A fin de posibilitar tal cometido y hasta tanto se contara con la explicitación escrita del derecho, se suspendieron todas las magistraturas ordinarias.

Así, estos magistrados llegaron a adquirir un poder absoluto.

Su duración, inicialmente, fue de un año, habiéndose a su término redactado las primeras diez tablas.

La obra fue considerada inconclusa, razón por la cual se designaron 10 nuevos decemviri por un año más de los cuales 2 habrían sido plebeyos.

De este modo se redactaron las 2 últimas de las 12 tablas que componen la excelsa ley.

Dirigidos por Apio Claudio pretendieron perpetuarse en el poder, siendo derrocados, restableciéndose las magistraturas ordinarias en el año 449 a.C.

d) El Tribunado Militar con Potestad Consular

Los graves conflictos que generaron las demandas de los plebeyos, para lograr su integración en la civitas, produjeron su acceso al *cursus honorum*.

Tal como ocurriera con las exigencias de derecho escrito y que se concretaran en la Ley de las Doce Tablas, gradualmente posibilita que éstos logren sus propósitos. Ello no obstante los patricios ofrecieron cierta resistencia al acceso directo a las magistraturas por parte de los plebeyos.

Así al pretender la plebe ingresar al Consulado (445 a.C.) los patricios, a manera de solución otorgan, en casos excepcionales, el poder consular a los Tribunos Militares, cargo éste al que tenían acceso los plebeyos.

El nombramiento de estos TRIBUNOS MILITARES CON POTESTAD CONSULAR era efectuado por los comicios a propuesta de los cónsules.

Su número era variable, generalmente seis, formando colegio. Tenían funciones similares a las de los Cónsules, a los que reemplazaban en el mando de los ejércitos, pudiendo elegir a sus auxiliares en las legiones ordinarias.

No obstante, no tenían posibilidad de designar sucesor ni adquirir el rango consular, cuando dejaban su cargo.

Carecían, además, del privilegio de usar la toga púrpura y otros atributos propios de los cónsules.

e) El Interrex

Durante la etapa monárquica, en caso de vacancia del rex sin haber éste designado sucesor, el Senado asumía el *imperium* y nombraba de entre sus miembros un interrex.

Con el advenimiento del régimen republicano, el interrex adquiere el carácter de un verdadero magistrado extraordinario, actuando en caso de acefalía consular.

En tal supuesto, el poder era ejercido por un Senador sorteado, quien se desempeñaba durante 5 días. A su término sucedíale otro y así hasta la elección de los nuevos Cónsules.

Su función era presidir la reunión de los comicios, convocados para cubrir la vacancia.

Magistraturas Plebeyas

a) El Tribunado de la Plebe

"EN AQUELLOS TIEMPOS, habiéndose separado la plebe de los patricios, cerca del año decimoséptimo después de la expulsión de los reyes, la plebe creó para sí unos tribunos en el Monte Sacro (Aventino) que fuesen magistrados plebeyos. Denominados TRIBUNOS porque, en otro tiempo, el pueblo estaba dividido en tres partes y se nombraba uno por cada una, o también porque eran nombrados por sufragio de las tribus". (D. I, 2, 20).

Explicando los inicios de esta magistratura, decía Lucio Anneo Floro, en sus "Gestas Romanas": "Oríginose la primera contienda por la tiranía de los usureros, los cuales se ensañaron con sus deudores, azotándolos como esclavos. El pueblo armado se retiró al Monte Sagrado, y no sin repugnancia regresó una vez que con-

siguió que se nombraran tribunos y movido por la autoridad del sabio y elocuente

Menenio Agripa.

Diversas fueron las circunstancias que llevaron a esta situación histórica.

La división entre la nobleza y los ciudadanos carentes de derechos políticos, había existido desde antiguo.

Al comienzo de la República, solo los patricios eran nobles y gozaban de privilegios políticos y religiosos, ejerciendo opresivamente su poder.

La tradición habla de que, en esa época, se produce un gran descontento popular: la recesión económica que asoló a Roma en el siglo V a.C.; un ascendrado rigor del *Nexum*; altas tasas de interés; disfrute del *ager publicus* por los patricios, etc.

El descontento adquiere así la forma de comunidad de conjurados o *Lex Sacrata*. Su objeto era constituirse como cuerpo de elementos ligados entre sí por juramentos.

Ante una leva, se produce la negativa de la plebe a salir a compañía. Así, en el año 495 a.C., el ejército en las puertas de Roma, se retira al monte Sacro (*Aventino*).

A consecuencia del juramento que unía a la plebe, los Tribunos fueron declarados "*sacrosanti*". Cualquiera que atentara contra ellos era anatematizado y destituido de toda garantía jurídica y humana, siendo sus bienes confiscados en favor de Ceres o Tellus, cuyo santuario era lugar de reunión de los plebeyos, los *Terra filii* (hijos de la tierra).

Si bien la *lex Sacrata* es una institución difundida en Italia, adquiere en Roma características peculiares. A la manera itálica posee el tipo militar pues aún persiguiendo fines políticos fue empuñando las armas, que produjo la *Secessio Plebis* (secesión plebeya), creándose los tribunos dentro del modelo militar.

Peró como propiamente romano aparece un ritual de juramento de extrema sobriedad, con un carácter de permanencia que tiende a consolidarse, incorporándose al Estado. En lugar de acción violenta se da un desarrollo orgánico que se expresa en un juramento conjunto de la comunidad, no limitado a la plebe, e invocando a Júpiter capitolino (divinidad de la Civitas) al lado de Ceres (dios de la plebe).

La creación del Tribunado vino a dar importancia a la organización política de la plebe, que en origen tuviera marcado carácter religioso.

Una teoría afirma que los Tribunos no eran sino los jefes de las cuatro tribus urbanas y habrían sido designados por elección de las mismas tribus. De ser así, el Tribunado sería más reciente que lo que tradicionalmente se señala (495 a.C.) no pudiendo haber nacido por efecto de las primeras secesiones plebeyas (494 - 471 a.C.) sino coincidiendo con los comicios tribados (472 a.C.) y la tercera secesión.

Sea cualquiera de ellos el origen, para lograr el retorno a la civitas junto a disposiciones que remediaban la miseria de los deudores, se estableció una ley la que se hizo jurar guardarla a todos los miembros de la ciudad individualmente y de... al templo de Ceres, bajo custodia de los ediles. Por ella se instituyó

a dos Tribunos plebeyos. Sus poderes cesaban fuera de la ciudad, donde solo tenía fuerza el mando militar de los Cónsules o los Dictadores.

Su autoridad habría estado fundada sobre la fuerza militar de la plebe y sobre el temor religioso, e impuesta a la civitas patricia.

Más tarde, al tener éxito la actuación de los Tribunos, el primitivo carácter militar desapareció y se manifestó la tendencia a insertarse en el Estado ciudadano. Así, la situación de los Tribunos debió quedar fijada legalmente en la tercera de las leyes *Valeriae Horatiae* (449 a.C.). La definición de los poderes del Tribuno y de sus funciones debió ser gradual. Su número inicial posiblemente fue de dos, para luego ser cuatro (*lex Publilia* - 471 a.C.) y llegar, según Tito Livio y Dionisio, a diez en el 437 a.C.

El Tribuno no es un rector de la civitas, no tiene Imperium ni auspicia, ni soberanía positiva, ni título ni insignia de magistrado; no puede, al inicio, ni tratar con el Senado ni con el pueblo, ni convocar a los comicios.

Su función esencial es proteger a la plebe, individualmente o como clase, contra eventuales arbitrariedades de los magistrados patricios. Para el ejercicio de este *auxilium* se valían de la *intercessio*, del derecho de veto con el que puede detener e impedir las órdenes, los decretos, las levas del Cónsul, las decisiones del Senado, las propuestas de ley, las elecciones, y las convocatorias a comicios para cualquier fin; así como todo acto de los poderes públicos, hasta el extremo de poder detener toda la maquinaria del Estado. Esta actividad la ejerce por petición del ciudadano o por su propia iniciativa.

Como garantía del *ius auxilii*, mediante la *intercessio*, poseían una *Summa Coercens Potestas*, en virtud de la cual podían multar, detener y, según algunos, infligir penas capitales incluso a los magistrados. Esta coercitio (que amplía los efectos de la *intercessio* aún más que el caso del Cónsul con su colega) tiene raíz en el carácter sacrosanto atribuido a los Tribunos por la primera *lex Sacrata* y por la misma *Valeriae Horatiae*.

A más de esta función negativa, el Tribuno ejercía la facultad de convocar a los *Concilia Plebis*. En ellos se elegían, a propuesta de los mismos Tribunos, a sus sucesores. En la época más antigua, en caso de no designarse a todos, acaso los elegidos completaban el número por el sistema de la *Cooptatio*, lo que habría ocurrido hasta un Plebiscito Trebonio (348 a.C.). El poder del Tribuno, durante la época histórica, solo se ejercía dentro de la ciudad, de modo que no podía alejarse de ella. Las puertas de su casa debían estar siempre abiertas a los ciudadanos que quisieran recurrir a él, día y noche; de tal modo la línea del *Pomerium* se convirtió en el límite de su *intercessio*.

Los rasgos de origen revolucionario nunca fueron borrados, ni aún a fines de la República, siendo el órgano que guió la elevación de la plebe, la llevó a la conquista de la Magistratura e igualdad con el patriciado. En suma, fue adecuada protección jurídica de los débiles y garantía de su libertad.

b) Los Ediles Plebeyos

Para algunos autores, antes que el Tribunado existieron los Ediles de la Plebe, que en número de dos servían en el templo de Ceres (diosa de las cosechas) como custodios del mismo.

De ser así la plebe aparecería como una corporación con fines de culto bajo la dirección de los Ediles, quienes habrían tenido poderes de fiscalización sobre los miembros del grupo.

Ello corroboraría el origen religioso de la organización plebeya.

Más tarde, cuando los plebeyos se van insertando en la estructura política estos Ediles van a desempeñar diversas funciones, transformándose en auxiliares de los Tribunos Plebeyos.

Gozaban, al igual que los Tribunos Plebeyos, del carácter de inviolabilidad (*sacrosancti*).

Estos magistrados custodiaban las instituciones plebeyas y, por ende, los derechos de estos ciudadanos, pudiendo llegar a promover, ante los Concilia Plebis, procesos para imponer multas y asumiendo, ocasionalmente, la defensa de los plebeyos frente a tributos abusivos.

Su elección correspondía a los *Concilia Plebis*.

El Senado Republicano

En los comienzos de la República, el Senado no difería mayormente del de la época monárquica.

Sin embargo, durante este período, se transformará en el órgano preeminente en la dirección de los asuntos políticos de la civitas.

Inicialmente, su composición era exclusivamente patricia. Recién a mediados del siglo IV a.C. se producirá la admisión de los plebeyos al Senado.

A los Senadores de origen patricio se les seguirá denominando *Patres*, término usado para aquellos que representaban a las antiguas gentes y, por tanto, no aplicable a los plebeyos, a quienes se llamará *Pedarii* o *Conscripti*. Esta última expresión se asignaba a quienes fueran elegidos para desempeñar cargos públicos.

La ley OVINIA (312 a.C.) posibilitó la inclusión, en las listas senatoriales, de todos los ciudadanos que hubiesen desempeñado magistraturas patricias. En tanto, por el plebiscito ATINIO (de fecha dudosa, posiblemente del 102 a.C.) accedieron quienes habían sido Tribunos de la Plebe. Con esta reforma llegó a constituirse el Senado patricio-plebeyo. No obstante, al ingresar los plebeyos al Senado, no adquieren total igualdad con los patricios, que continúan siendo el grupo predominante.

El número de Senadores fue variando de 300 a 900, llegando a 1.200 en épocas de Julio César.

Su elección correspondía originariamente a los Cónsules y, a partir de la ley OVINIA, a los Censores.

Para ser elegido Senador se debían reunir determinadas condiciones: ser ciudadano romano ingenuo, tener no menos de 27 años, poseer bienes suficientes como para pertenecer a la centuria de los caballeros y no haber ejercido profesión deshonesta.

La convocatoria del Senado debía efectuarse por un Magistrado que gozara del *Ius Agendi Cum Patribus* (Magistrados "*cum imperium*") un Cónsul, Dictador, Pretor o Interrex, según las circunstancias, quien también lo presidía.

La sesión se iniciaba con ceremonias religiosas, luego de las cuales el magistrado que la presidía exponía los puntos sobre los que versaría la deliberación, consultándose el parecer de los Senadores.

Se interrogaba primero a los ex-Censores, el más anciano de los cuales era llamado *Princeps Senatus*; luego a los ex-Cónsules, a los ex-Pretores, ex-Ediles Curules y ex-Ediles Plebeyos, ex-Tribunos plebeyos y ex-Cuestores. Por último a los ciudadanos que hubiesen llegado al Senado por méritos particulares.

Las decisiones eran alcanzadas por mayoría de votos, generando lo que se conoce como *Senatus Consultum* (Senadoconsultos) que, con el tiempo, llegarán a ser fuente de derecho.

La anualidad de los Magistrados, la falta de aptitud de los Comicios para elaborar una adecuada legislación que contemplase los distintos intereses, unidos a la experiencia que como ex-magistrados tenían los Senadores, hará que este organismo, a partir del siglo III a.C., detente una verdadera conducción del Estado.

En razón de ello puede afirmarse que los Magistrados eran meros ejecutores de las resoluciones senatoriales, ya que debían consultar los asuntos importantes al Senado y aceptar su decisión.

Facultades del Senado

a) Auctoritas Patrum

La expresión *Auctoritas* (de *Aug* = aumentar) aparece en Roma unida a la función tutelar. Así el tutor poseía la *auctoritas*, que permitía sumar su voluntad a la del pupilo completando de tal modo su capacidad.

De forma equivalente, el Senado ejercía la *Auctoritas Patrum* sobre las deliberaciones y las decisiones comiciales, sin la cual éstas no alcanzaban valor legal.

En tal sentido, la *lex Publilia Philonis* (339 a.C.) transformó en previo el requisito de la *Auctoritas*.

En tales casos el Senado consideraba la propuesta del Magistrado antes que los Comicios.

En el 287 a.C., con la *lex HORTENSIA*, se exime a los plebiscitos de la exigencia de la *Auctoritas Patrum*. Ello significa el inicio de la desaparición de este instituto.

No obstante, el carácter fiscalizador de la actividad legislativa que la *Auctoritas* otorgaba al Senado, no se pierde, puesto que el Senado se arroga el derecho

de interpretar las leyes, anularlas por vicios de forma y dispensar a los particulares de su observancia.

En definitiva, la *Auctoritas Patrum*, políticamente, se tradujo en el poder del Senado para controlar el adecuado equilibrio de las decisiones de los Comicios con relación a los intereses de la Civitas.

b) Interregnum

Esta institución, ya existente en la etapa monárquica, permanece vigente durante toda la República, extendiéndose incluso durante el período posterior.

Mediante ella, el Senado reasumía el imperium en caso de vacancia en los cargos de magistrados superiores.

Si bien no puede afirmarse en forma terminante, esta función estaba reservada sólo a los Senadores patricios (*Patres*) quienes la ejercían sucesivamente, por períodos de cinco días, hasta la designación del nuevo Cónsul.

c) Función Consultiva

De hecho, la dirección de los principales asuntos de gobierno estaba en manos del Senado; éste fue acrecentando su prestigio y autoridad a lo largo del período republicano.

Los Magistrados sometían a consulta de este cuerpo toda decisión que excediera los límites ordinarios de su cargo, aceptando su respuesta.

Aún cuando carecía de medios directos de coerción, poseían modos de ejercitar su autoridad. Así se le reconoció: El ordenamiento del culto y del derecho sacro; la administración de la hacienda pública, la gestión de las relaciones exteriores (recibir y enviar embajadores, firmar tratados de alianza, organizar los países conquistados); el control de los asuntos militares (designación de los jefes, ordenar levadas, otorgamiento de premios y castigos).

Además, como medidas extraordinarias derivadas de situaciones de extrema gravedad, pueden citarse el *Senatus Consultum Ultimum* y el *Senatus Consultum Iustitium*. Por el primero se investía a los Cónsules de poderes de excepción para salvaguardar al Estado, cayendo toda garantía de los ciudadanos.

Por el segundo, el Dictador suspendía las Magistraturas ordinarias y procedimientos, proclamando el "tumultus".

Los Comicios

"... Si se vota por clases, los comicios son CURIATA, por curias; si se vota según el censo y la edad, son CENTURIATA, por centurias; en fin, se les llaman TRIBUTA, por tribus, cuando se vota según el domicilio..."
(Aulio Gelio; NOCHES ATICAS; XV-27).

a) Comicios Curiados

Estaban exclusivamente conformados por los patricios y sus clientes. Surgidos durante la monarquía verán reducidas sus funciones durante la república. En este período solo conservaron el derecho a investir de imperium a los magistrados elegidos por los comicios centuriados (*lex curiata de imperio*) y dar posesión de sus cargos a los sacerdotes.

Sus antiguas funciones fueron absorbidas por los comicios centuriados o suprimidas.

En el siglo III a.C., la representación de las curias es otorgada a 3 augures y 30 lictores, perdiendo estos comicios toda importancia y reduciéndose la *lex curiata de imperio* a un mero formalismo.

b) Comicios Centuriados

Estos comicios, cuya organización se atribuye a Servio Tulio, lograrán su funcionamiento pleno en la República.

En esta etapa contrapesaron los poderes del Senado y de los magistrados. Su convocatoria solo podía efectuarse a través de un magistrado que gozara de imperium.

La competencia de estos comicios se extendía a diversos ámbitos. De esta manera tenían incumbencia legislativa (resoluciones generales por las que se concedía la ciudadanía; creación de magistraturas y sacerdocios determinando su competencia; aprobar normas obligatorias para los ciudadanos o liberarlos de su cumplimiento) electoral (elección de Cónsules, Pretores y Censores) judicial (la *provocatio ad populum* surgida de la *lex Valeriae de Provoctionem* por la que podía recurrirse de las sentencias que impusieran la pena capital) e internacional (decidían sobre la guerra y la paz y los tratados con otros pueblos).

c) Comicios Tribados

Esta forma comicial es la última en aparecer dentro de la evolución de las instituciones romanas.

De modo análogo a los *Concilia Plebis* y a partir de las reformas de Appio Claudio (siglo III a.C.) surge esta asamblea popular, organizada sobre la base de la distribución territorial. Los ciudadanos eran divididos según su ubicación dentro de una determinada circunscripción del territorio (cada circunscripción recibía el nombre de tribu, sin saberse, a ciencia cierta, si la denominación de esta estructura guardaba relación con las antiguas tribus).

Al inicio, estas tribus eran 20, de las cuales 4 eran urbanas, y las restantes rústicas. El número de las últimas fue aumentando hasta llegar a 35. Posteriormente los ciudadanos eran incorporados a algunas de las ya existentes, perdiéndose entonces el carácter de división territorial, puesto que se transformó en una simple división personal.

En esta forma comicial, participaba la ciudadanía sin distinciones, lo que venía a diferenciarla de los *Concilia Plebis*. No obstante, al menos en las tribus urbanas, prevalecían los plebeyos.

La unidad de voto, para alcanzar la decisión era la tribu. Los ciudadanos sufragaban dentro de cada tribu, con lo cual el número de los comprendidos en ella no modificaba la decisión final.

Se advierte entonces el peso de las tribus rústicas, superiores en número a las urbanas y con una densidad de población mucho menor.

En ellas estaba concentrado el elemento más conservador (dueños de los inmuebles rurales) que hacía valer su influencia al momento de tomarse las decisiones comiciales.

Recién con la admisión de nuevos ciudadanos se modificará la composición de las tribus rústicas.

Los comicios tribados, que coexistieron con los centuriados, terminaron por prevalecer sobre ellos.

Puede afirmarse que gozaron de facultades legislativas, electorales y judiciales.

Respecto a las facultades legislativas no existió una delimitación concreta entre ambos tipos de comicios. A partir de la ley Hortensia, reemplazarán a los comicios centuriados, salvo en aquellas leyes relativas a la guerra (*lex de Bello Indicendo*) a la paz y tratados internacionales; así también la ley que investía de poder a los Censores (*lex de Censoria Potestate*) que continuaron siendo exclusivas de los comicios centuriados.

Las funciones electorales estaban originariamente limitadas a la elección de los magistrados inferiores. Posteriormente estuvo a su cargo la de los Tribunos y Ediles plebeyos, hasta entonces privativa de los *Concilia Plebis*. Por último, en materia judicial, podía recurrirse ante los comicios tribados la aplicación de multas que excedían los límites establecidos por algunas leyes (*lex Aeterna Tarpeya* 454 a.C.; *Menenia Sextia* 452 a.C. y *Julia Papiria* 450 a.C.).

La convocatoria a estos comicios debía efectuarla un Magistrado *populi romani* (*cum imperium*) participando en ellos todo el pueblo de Roma (patricios y plebeyos).

Las resoluciones de estos comicios no requerían la confirmación senatorial, que se había exigido hasta la ley Hortensia.

d) *Concilia Plebis*

Esta Asamblea, que reunía exclusivamente a los plebeyos, debió nacer simultáneamente al Tribunado, incumbiéndole, al principio, solo aquellas materias que interesaban a esta clase.

Su convocatoria debía efectuarse por los Tribunos de la Plebe o por los Ediles Plebeyos.

Sus resoluciones recibían el nombre de plebiscitos (*plebis scita*).

Estas decisiones tenían, para los plebeyos, validez general y obligatoriedad.

análoga a las leyes, a las que irán equiparándose a través de las leyes *Valeria Horacia*, *Publilia* y *Hortensia*.

En esta Asamblea, además, se elegían los Tribunos y los Ediles Plebeyos. A propósito de ellas, dice Aulio Gelio:

"Cuando no se conozca a todos los ciudadanos, sino únicamente a parte del pueblo, no hay Comicios, sino solamente Consejo (*Concilium*). Los Tribunos, por ejemplo, no convocan a los patricios y nada pueden someterles. . .".
(*NOCHES ATICAS*; XV 27).

e) *Convocatoria y Desarrollo de las Asambleas Populares*

Las diferentes clases de Asambleas populares eran convocadas en Roma por los magistrados, quienes hacían conocer los asuntos que se iban a considerar. Tal convocatoria era efectuada oralmente, utilizando pregoneros, adoptándose con el tiempo la forma escrita (edictos).

La reunión se efectuaba al aire libre. Los comicios curiados se realizaban en un espacio cerrado, al lado del Foro, y dentro de los muros de la ciudad (*comitium*).

En el campo de Marte, fuera de la ciudad, se reunían los comicios centuriados, ya que el ejército no podía reunirse en la ciudad.

Los comicios tribados y los *concilia plebis* lo hacían en el Campidoglio, para luego trasladarse al campo de Marte cuando tenían por objeto la elección de magistrados, y en el Foro cuando dictaban leyes.

La convocatoria debía hacerse con 3 semanas de anticipación (*Trinundinum*) lo que facilitaba el conocimiento y permitía la discusión de los temas sujetos a tratamiento.

En la víspera se realizaban ceremonias religiosas (auspicios) con el objeto de lograr que el cometido fuese favorecido por los dioses.

Quien presidía la Asamblea debía explicar el asunto sobre el que iba a deliberarse, indicando a los ciudadanos que, a los efectos de votar, se ubicaran en curias, centurias o tribus, según el caso.

La Asamblea concluía con la declaración oral del Magistrado dando a conocer el resultado de la votación (*renuntiatio*).

FRANJA MORADA

Capítulo 4

SUMARIO:

- I. La Ley de las Doce Tablas.
- II. Las Fuentes Republicanas.



LAS FUENTES DE DERECHO

La Ley de las Doce Tabas

Según la Tradición, el nacimiento de la primera ley romana escrita, sería consecuencia de las insistentes demandas plebeyas.

Así los historiadores romanos ubican el reclamo de un derecho escrito junto a otras aspiraciones, como las exigencias planteadas por la plebe en la secesión al Monte Sacro.

Siguiendo este desarrollo tradicional, en el año 462 a.C., un Tribuno de la plebe (TERENTILLO ARSA) propuso el nombramiento de cinco magistrados a efectos de la redacción de un cuerpo legal (Magistrados *Legibus de Imperio Consularis Scribundis*). Aún cuando no prosperara este intento, en el 454 a. C. habría sido enviada una delegación a las colonias griegas del sur de la península itálica (Magna Grecia) con el objeto de investigar las leyes griegas. Transcurrido un tiempo, el Cónsul Appio Claudio, habría inducido a los Padres a admitir la redacción de la ley.

En el 451 a. C., surge una nueva magistratura: el decenvirato legislativo (*Decemviri Legibus Scribundis*).

Esta magistratura extraordinaria suspende el ejercicio de las restantes, tanto patricias como plebeyas.

Estos magistrados, que pretendieron arrogarse el poder absoluto, son derrocados en el 449 a. C., restableciéndose las magistraturas.

Según TITO LIVIO y otros historiadores romanos, habrían sido los Cónsules Lucio Valerio y Marco Horacio quienes publicitaron las Tablas.

Siguiendo estas mismas fuentes, al ocurrir el incendio de la ciudad atribuido a los galos, las Tablas originarias habrían desaparecido, para ser encontradas más tarde.

Otra opinión cree que tal desaparición nunca se produjo, y que las Tablas se rehicieron en base a transmisión oral.

CICERON afirmaba que los escolares de su época las sabían de memoria, recitándolas íntegramente.

Sobre el particular, no puede desconocerse la crítica a que han sido sometidas estas versiones tradicionales. Así se han marcado discordancias, contradicciones e inexactitudes.

Una posición, hoy preponderante, que tiene especialmente en cuenta los "fastos", afirma que no ha de dudarse de la existencia del primer decemvirato, resultando dudosa la del segundo.

Por otra parte, sin desconocerse la incidencia del conflicto patricio-plebeyo, no puede ignorarse que el propio desarrollo de Roma exigía la redacción escrita del derecho consuetudinario existente. En tal sentido, no todo el contenido de la ley ha de tenerse por legislación nueva. Antes bien la mayoría de las instituciones que en ella aparecen debieron nacer mucho antes; incluso es probable que otras se hayan agregado con posterioridad a la obra decenviral.

También se discute sobre si esta ley fue votada o no en los comicios centuriados, y sobre su carácter privado o estatal. Parécenos no obstante más acertada la opinión que afirma que se trata de una *Lex Data* (dada por el Magistrado) sin perjuicio de que lo fuera por los Decemviros o por los Cónsules que les sucedieron.

Lo que no puede discutirse es, sin duda, que a mediados del siglo V a.C., el Decemvirato redactó la compilación, que se conoce con el nombre de Ley de las Doce Tabas, la que, unida a la interpretatio posterior configura el Derecho Civil Romano.

De las fuentes jurídicas que nos han llegado, la Ley de las Doce Tabas nos muestra las características notables del primitivo Derecho Romano, donde ya se exterioriza el especial sentido jurídico de los romanos, en su afán de resolver prácticamente los conflictos.

Las actuales reconstrucciones de la ley, seguramente están lejos del texto originario. Es probable que las fuentes estén basadas en la obra de GNEO FLAVIO (escriba de Appio Claudio) y luego en la del jurista SEXTO AELIO PETUS CATUS, autor de la Tripartita.

Es muy probable que estas obras sirvieran como fuentes, para que juristas posteriores pudieran estudiar e interpretar el Derecho Romano primitivo.

También debe señalarse la labor cumplida por los juristas modernos, quienes han intentado reconstruir el texto originario. Tales como SCHOELL, DIRKSEN, BRUNS, GIRARD y RICCOBONO. Sin olvidar, en el medioevo, la obra de JACOBUS GODOFREDO (*Fontes Quattuor iuris civilis*, 1653).

Contenido de las Tablas

Según las reconstrucciones antedichas, es posible que las materias contenidas en las Tablas abarcasen instituciones de muy diversa índole.

Así las Tablas I, II y III se refieren al sistema procesal romano.

En la Tabla Primera se indican las formas de citación ante el Magistrado (*in ius vocatio*). Se establece que ha de intimárselo, ante testigos, a concurrir. En caso

de evasivas, negación o huída autoriza al demandante a llevarlo por la fuerza.

Si la edad o la enfermedad eran obstáculo que impide la concurrencia, quien cita ha de suministrar el medio de transporte.

Además se hace referencia a que quien sea garante (*vindex*) ha de ser de igual posición social y tener la misma solvencia económica que el garantido.

Se prevee la posibilidad de que una transacción finiquete el negocio, tornando ocioso el proceso. Si ella no se produjera, los litigantes expondrán sus peticiones al Magistrado antes del mediodía, ya que la puesta de sol daría fin a todo acto de procedimiento. Pasado el mediodía otorgaba el pleito a la parte presente.

Cuando el pleito no había podido terminarse en la jornada, las partes aseguraban volver a presentarse ante el Magistrado, mediante una promesa llamada "*vadimonium*".

La Tabla Segunda comienza con la indicación de cual ha de ser el valor del *Sacramentum*. Se refiere a una acción procesal cuyo origen se remonta, posiblemente, a la época en que los pleitos se sustanciaban ante el Colegio de los Pontífices. Seguramente entonces debió ser una ordalía, sometándose a la decisión de los dioses el resultado del pleito. A tal fin debió realizarse un sacrificio que, según la entidad del pleito debía ser de una cabeza de ganado menor o mayor. Posteriormente hubo de abandonarse el efectivo sacrificio, sustituyéndose el animal por una suma de dinero equivalente, que se incorporaba a las arcas pontificales. Al desplazarse las funciones jurisdiccionales a los magistrados, la suma de dinero correspondió al erario público. Finalmente, el *Sacramentum* fue entregado a quien había vencido en el pleito. Debe destacarse que, cuando estaba en juego la libertad de una persona, el *sacramentum* era por la suma menor (50 ases) para que todos pudieran defender su condición de libres.

En esta Tabla también se hace referencia a los motivos que justificaban el aplazamiento del proceso. Si alguien debía citar testigos tenía que hacerlo con anticipación suficiente, en alta voz y en la puerta del domicilio del testigo.

Por último, se prescribe que es posible la transacción, incluso en los casos de *Furtum* (figura delictiva que comprendía varias de las actuales como casos de hurto, robo y estafa). En este sentido debe destacarse el carácter privado de estos delitos, que permiten el resarcimiento a través de una compensación pecuniaria o la entrega de aquel o aquello que había causado el daño (abandono noxal del filius, esclavo o animal).

La Tabla Tercera está dedicada exclusivamente al procedimiento ejecutivo denominado *Manus Iniectio*.

Por el mismo, quien resultaba condenado a pagar una suma de dinero o confesaba judicialmente su deuda, tenía 30 días para cumplir.

Si no lo hacía, el acreedor podía conducir al deudor ante el Magistrado. Si a requerimiento del Magistrado nadie respondía como *vindex*, era autorizado el acreedor a llevar al incumpliente a su propia casa. Allí podía retenerlo, con la obligación de presentarlo por tres veces consecutivas en el mercado, haciendo así 60 días.

Durante este lapso, el acreedor podía mantenerlo encadenado, obligándose a suministrarle una libra diaria de harina.

Una vez en el mercado, se exhibía al deudor y se publicitaba el monto de la deuda, en pos de que apareciese un vindex u otros acreedores. Si ello no sucedía se le imponía pena capital (*capitis deminutio*) facultándose al acreedor a venderlo como esclavo al otro lado del Tiber.

En caso de ser varios los acreedores, la ley permitía dividir al deudor entre ellos. Debe interpretarse que lo repartido es la capacidad laborativa del deudor, lo que resulta equivalente a la división del precio alcanzado si se optaba por su venta en el transtiber.

En la Tabla Cuarta, se trata acerca de las potestades del paterfamilias, en especial, a la patria potestas (que ejercía el pater sobre sus hijos legítimos, legitimados y adoptivos no emancipados).

Esta tabla contempla el nacimiento deforme o monstruoso, disponiendo su muerte inmediata.

Algunos autores han creído encontrar en esta regla una paralelismo con análogas disposiciones espartanas. Lo cierto es que no poseen referencias históricas ciertas al respecto, que permitan conocer la extensión y forma en que se habría ejercido, en la práctica, este derecho.

Esta Tabla, además, se refiere a la amplitud de los poderes del pater sobre sus hijos. En esta materia cabe recordar el papel fundamental del paterfamilias, quien como autoridad absoluta de su grupo ejercía el derecho de gobernarlo. Así podía corregirlos, sancionarlos o venderlos, e incluso ordenar su muerte.

Todo ello configuraba para el pater la *Vitae Necisque Potestas* (potestad de vida y muerte) sobre los integrantes de la familia.

Sin embargo este poder no puede entenderse como una facultad ilimitada e irresponsable, sino como derivado de aquella que lo autorizaba a imponer castigos sin recurrir a los órganos del Estado.

Al efecto, debían respetarse las *Mores Maiorum* (costumbres de los antepasados) pudiendo oírse a familiares y allegados (*Consilium Propinquorum*).

También contempla esta Tabla que el pater que ha entregado a su hijo por tres veces, alejándolo así de la familia, perdiera sobre éste su patria potestad. Esta disposición fue aprovechada para la emancipación y la adoptio (adopción de un alieni iuris).

Finalmente se establece que el plazo máximo de gestación alcanza a diez meses. Tal disposición adquiere relevancia en los casos de hijos póstumos nacidos con posterioridad a la disolución del matrimonio y sus derechos hereditarios (D. 38, 16, 3 (11); AULIO GELIO: "Noches Aticas", III, 16).

La Tabla Quinta aborda los temas de las tutelas y las herencias.

Se trata allí de la tutela perpetua de las mujeres (*Tutela Mulierum*). La reconstrucción efectuado cobra importancia con la referencia contenida en las Institutas de GAYO (I, 145 y 157).

Dispónese que las sacerdotisas dedicadas al culto de Vesta (vestales) estaban exceptuadas, por la dignidad de su rango, de esta tutela.

Refiérese además al supuesto de adquisición de la propiedad, por medio de la usucapción, de las *Res Mancipi* (cosas que, por su relación con la agricultura, tenían especial significación para los romanos). Las que pertenecían a las mujeres, bajo tutela, no podían usucapirse, a menos que se hubiesen entregado con la autorización del tutor (GAYO, Inst. II, 47).

Al referirse a las herencias, establece la ley el respeto a las cláusulas testamentarias, otorgando al testador un derecho ilimitado para disponer de sus bienes y designar tutores (*Uti Legassit Suae Rei Ita Ius Esto* = Así como dispusiera de sus cosas, tal será el ius. GAYO, Inst. II, 224).

También se dispone el orden sucesorio para el caso de quien muere sin haber hecho testamento (sucesión intestada o *Ab-Intestato*).

Del párrafo 9 del libro III de las Institutas de Gayo, resulta que, en la Ley de las Doce Tablas, el primer llamado a la herencia corresponde a los *Sui Heredes* (herederos suyos) es decir a aquellos que al momento de la muerte del pater se encontraban bajo su directa potestad. En defecto de estos, se entregaba la herencia a los agnados (vínculo fundado en la participación en un mismo culto familiar, que se transmitía por vía masculina). La ley no convocaba simultáneamente a la totalidad de los agnados, sino a los de grado más próximo (GAYO, Inst. III, 11).

Si no concurrían los agnados, son llamados a la herencia los gentiles, es decir aquellos que pertenecían a la misma *Gens* que el difunto.

De igual manera, siguiendo el mismo orden que para las herencias, se designaba a los tutores y curadores.

La herencia del esclavo liberado (*liberto*) era conferida a su ex dueño (*patrono*) para el caso de que muriese intestado o sin herederos suyos.

Dispónese también sobre la división de las herencias, estableciendo la ley una acción (*Actio Familiae Eriscundae*) que permitía a los herederos reclamar la participación de ella.

Por último se contempla el caso del esclavo que ha sido liberado bajo condición de entregar una suma de dinero al heredero. Si éste último lo enajenase, el esclavo adquiere la libertad si satisface la referida suma al comprador.

En la Tabla Sexta, se analiza, entre otros, el tema del *Nexum* y del *Mancipium*.

La fórmula de la ley expresaba que lo que fuera declarado verbalmente al hacerse el *nexum* y la *mancipatio* debía considerarse como *ius*.

Aunque el significado del *nexum* puede dar lugar a varias interpretaciones, parece valedera aquella que se inclina por señalar que se trata del vínculo, la atadura jurídica que liga al deudor y que permite que el acreedor vaya contra la persona, como en la *manus iniectio*. Será luego la *lex Poetelia Papiria* (236 a. C.) la que suprima este tipo de vínculo y lo traslade de la persona a los bienes del deudor.

El *nexum* se constituía a través del rito *per Aest et Libram* (por el cobre y la balanza).

Distinta al *nexum* es la *mancipatio*, por la que se transmitía el dominio o se constituía una servidumbre rústica.

La *mancipatio* también era un negocio *Per Aes Et Libram* (por el cobre y la balanza). Este procedimiento se cumplía ante cinco testigos ciudadanos romanos púberes y uno de la misma condición que sostenía la balanza (*libripens*).

Allí el que recibía la cosa declaraba solemnemente sus derechos sobre ella. Este procedimiento se usó a diversos fines, ya que además de medio para transmitir el *Dominium Ex Iure Quiritium* sobre las cosas *mancipi* (propiedad conforme al Derecho Civil sobre dichas cosas) sirvió para establecer el poder sobre personas libres (*in causa Mancipi, coemptio*) emancipar hijos, adoptar (*adoptio*) y testar (testamento *per aes et libram*).

La ley establece aquí la pena del duplo a quien negara las declaraciones hechas en el *nexum* o en el *mancipium*.

Otro modo de adquirir la propiedad, contemplado en esta tabla, es la adquisición del dominio por medio de la posesión (*usucapio*). Se establece que el plazo para la *usucapio* de los fundos debía ser de dos años y de un año para el resto de las cosas y los derechos.

Otro caso de adquisición de derechos por el transcurso del tiempo, se menciona en la ley como el *usus*. El *usus* significa el sometimiento de la mujer casada a la potestad de su marido o del pater de éste, y consiguiente incorporación a su familia, por la convivencia continuada durante un año (*manus*).

Pero en la misma tabla se establece que para evitar esta sujeción debía la mujer ausentarse por tres noches consecutivas en cada año. (*Tri nocti usurpatio*).

En cuanto a las cosas del enemigo (*hostes*) no podía producirse la *usucapio* ni a la inversa.

Otra disposición está referida al caso de la presentación de los litigantes, con la cosa en discusión, ante el Magistrado (*manum consertum*). Se facultaba a éste a otorgar la posesión provisional (*vindiciae*) a quien considerase más conveniente.

Cuando lo que estaba en discusión era la libertad, el Magistrado debía estar a favor de ella.

La Ley de las Doce Tabas impedía sacar las vigas hurtadas que se hubiesen usado empotrándolas en una casa o los palos utilizados como sostén de las viñas. Es decir que el propietario no podía reivindicarlos, ni exigir la demolición de los edificios, ni perjudicar los cultivos. Si gozaba, en cambio, de una acción (*actio de tigno iuncto*) contra quien la había utilizado, por el doble del valor del *tignum* (viga). Los jurisconsultos entendieron que, dentro de la expresión viga se comprendía todo tipo de materiales de edificación o necesarios para la explotación de las vides (D. 47, 3, 1 y 50, 16, 62). En caso de desprendimiento o separación de los materiales el propietario, mientras permanezcan en tal situación, podía accionar mediante la acción reivindicatoria. Asimismo, dice la ley, que el comprador no adquiere las cosas vendidas y entregadas hasta que no haya pagado el precio al vendedor, o garantido a éste de alguna forma; tal como la prenda o el expromisor. (Just. Inst. II, 1, 41).

Por último, se confirma lo atinente a la *in iure cessio*, como modo de transmisión de la propiedad del Derecho Civil, al igual que la *mancipatio*. La *in iure cessio* era un procedimiento desarrollado ante el Magistrado, del que participaban el transmitente que efectuaba la cesión, el adquirente a quien se cede la cosa, y el Magistrado que efectuaba la *addictio*.

La Tabla Séptima establece que, entre los edificios contiguos, debe dejarse un espacio para circulación (*ambitus*).

Asimismo impone condiciones referidas a las plantaciones y excavaciones efectuadas en un fundo, en inmediaciones del lindero.

En un párrafo del Digesto, extraído de Gayo, se refiere que en esta materia, los principios aplicables parecen haberse originado en una ley que Sólon promulgara en Atenas, que disponía: "... Si alguien fijara un seto cavando junto a un fundo ajeno, no traspase el lindero; si una cerca deje un pie; si un edificio dos pies; si cavare un foso o un hoyo deje tanto espacio como profundidad; si un pozo, un paso; plante el olivo o la higuera a nueve pies de lo ajeno; los demás árboles a cinco pies. . ." (D. 10, 1, 13). De este fragmento se ha deducido la posible inclusión, en este lugar, de la *actio finium regundorum* (acción de deslinde) si bien se desconoce con certeza su régimen originario.

Además se establece que, entre los campos ha de existir un espacio para acceso y circulación de carretas, arados y aperos de labor. Tal espacio, que no podía ser adquirido por *usucapio*, debía ser de cinco pies.

En caso de desacuerdo sobre los límites debía nombrarse, por el Magistrado, tres árbitros ("... Y puesto que las Doce Tabas no autorizan "la prescripción dentro de una zona de cinco pies a partir de los límites "... y para fijar los límites como mandan las Doce Tabas, seremos tres los árbitros. . . CICERON: "De Legibus" I, 20).

También se determina el ancho del camino o calle (*via*) en las servidumbres rústicas y que debía ser de 8 pies en las rectas y de 16 en las curvas. (D. 8, 3, 8).

Si el camino señalado en la servidumbre fuere impracticable, se puede hacer pasar los animales por donde se quiera. (CICERON: "Pro Caecina XIX", 54).

Además se establece el derecho que tiene el propietario a pedir se lo indemnice por los daños que sufra su propiedad como consecuencia de trabajos artificiales para las aguas pluviales (D. 43, 8, 5). Esta disposición sería el antecedente de la *actio aquae pluviae arcendae*, acción de contención de aguas pluviales (D. 39, 3, 1, 10).

Las ramas de los árboles, según la ley, debían ser cortadas por debajo de los 15 pies, cuando estén pendientes sobre la propiedad vecina. Esto, según el Digesto para evitar que moleste al predio vecino la sombra del árbol (D. 43, 27, 1, 8).

Termina la tabla estableciendo el derecho del propietario a recoger los frutos de sus árboles que hayan caído en el fundo vecino (D. 43, 28, 1 y 50, 16, 236, 1).

La Tabla Octava trata sobre los delitos. En Roma se distinguía entre delitos públicos (*crimina*) y delitos privados (*delicta o maleficium*). Los delitos públicos comprendían a aquellos que implicaban un grave daño para el Estado. Así el *perduellio* (traición a la patria) el sacrilegio (afrenta a los dioses) el parricidio (ho-

micidio de un paterfamilias) cuyo juzgamiento en la época monárquica era efectuado por el rex.-

Los delitos privados, en cambio, estaban reservados a la autoridad de los paterfamilias o patergentium. Estos delitos privados son los que aparecen en los textos como fuentes de las obligaciones.

Al comienzo de esta Tabla, la ley castiga con pena capital a quien difamare por medio de libelos y otras formas ultrajantes. Así dice CICERON: "... Nuestras leyes de las Doce Tablas, tan parcas en imponer la pena capital, castigaron con esta pena al autor y al recitador de versos que atrajera sobre otro la infamia. Esta disposición fue sabia, porque debemos tener sometida nuestra vida a los fallos legítimos de los jueces y de los magistrados, mas no al ingenio de los poetas, y no debemos oricar cargos sino allí donde la contestación es lícita y podamos defendernos judicialmente" (De República IV, 10, 12).

Se refiere también a diferentes casos del delito de iniuria, relacionados con el daño físico a un ser humano.

La pena del Talión se aplicaba en caso de *membrum ruptum* (miembro roto) siempre que no se llegase a un acuerdo compositivo, mediante una suma de dinero.

Por *membrum ruptum* se entiende la separación o mutilación de un brazo, un ojo, u otra parte del cuerpo.

En cambio, la fractura de un hueso (*os fractum*) traía aparejada la pena pecuniaria que la ley fijaba en 300 ases, cuando la víctima era un hombre libre, y de 50 ases si se tratase de un esclavo.

La iniuria hecha a otro, aparece penada en 35 ases. En este caso se entiende por iniuria a un insulto o bofetada u otra forma de agresión verbal o física, sin mayor trascendencia. En Aulio Gelio se muestra esta sanción como inadecuada por su lenidad. Tal el caso que refiere este autor cuando menciona a Lucio Veracio "... hombre desalmado y extraordinariamente malévolo, su mayor placer consistía en aplicar la palma de la mano; y en cuanto el amo aplicaba una bofetada, el esclavo, según lo dispuesto por la ley, entregaba 25 ases. ..." (Noches Aticas, XX, 1).

A continuación la Tabla contenía diversos supuestos de reparación de daños. Puede considerárselos antecedentes de lo que luego sería la llamada *ley Aquila* (un plebiscito del 286 a. C.) que trataba el *Damnum iniuria datum* (daño injustamente causado) (D. 9, 2, 1).

Uno de los casos es el referido a la *actio de pauperies*. Por esta acción se imponía al dueño del animal cuadrúpedo que hubiere causado daño en cosas ajenas, a pagar el perjuicio o a entregar el animal (D. 9, 1, 1).

Concede también la *actio de pastu pecoris*, para la reparación del daño ocasionado por animales que pastaban en terreno ajeno, imponiendo también el pago del daño o la entrega del animal (D. 19, 5, 14, 3). Del mismo modo que se castigaba al difamador, que injuriaba a través de la *occensatio* (cántico) también se reprimía a quien causaba perjuicio en las cosechas mediante encantamientos, hechizos o prácticas mágicas (*malum carmen*).

Quien por la noche, y furtivamente, siegue las mieses o las de como pasto a los animales, si fuese púber era condenado a muerte y sacrificado a Ceres. Si era impúber era azotado con varas, a voluntad del Magistrado y condenado a reparar el daño por el duplo.

Al que hubiere incendiado una casa o una cosecha, en forma intencional, sea atado, azotado y arrojado al fuego. Si lo fuera por descuido será condenado a resarcir el daño; sino poseyere bienes para ello, será castigado moderadamente.

Si se hubiese cortado injustamente los árboles de otro, se otorgaba al perjudicado una acción (*actio arboribus succisis*) que permitía reclamar 25 ases por cada árbol cortado.

La ley permite matar al ladrón sorprendido en la noche, siempre que ello se haga constar a gritos. Si es sorprendido de día solo puede matarse si se resiste con armas, con tal de que se haga constar asimismo a gritos (D. 9, 2, 4, 1).

La ley contempla también una serie de supuestos del delito que los romanos denominan *furtum*. Ha de entenderse por tal el apoderamiento fraudulento de una cosa, con el ánimo de lucro, ya sea de la misma cosa o de su uso o posesión, lo que, como indica PAULO (D. 47, 2, 1, 3) está prohibido por la ley natural.

Ha de entenderse que el apoderamiento (*contrectatio*) implica una diversidad de situaciones, ya que el mismo se refiere a la sustracción de la cosa, su cambio de lugar, su retención contra la voluntad del dueño, la posesión y uso indebidos.

La sustracción de la cosa, para que encuadre dentro del concepto de *furtum*, debe realizarse con intención dolosa (dolo malo) (Gayo, Inst. III, 197).

En cuanto a la cosa, ha de entenderse que la misma ha de ser mueble; si se tratase de un inmueble estaríamos frente a la *invasio*, supuesto de *rapina*. La ley dispone que el *furtum manifestum* sea castigado con pena capital. Si se trataba de un hombre libre y púber se le azotaba con varas y se le adjudicaba a la víctima; si era esclavo se le azotaba y se le precipitaba por la roca, dándole muerte; si era impúber se le azotaba, a voluntad del Magistrado (AULIO GELIO: "Noches Aticas", XI, 28).

Se entiende por *furtum manifestum* a aquel en que el delincuente es aprehendido en el momento de cometerlo (*in fraganti*) habiéndose extendido la figura para el caso de encontrarse a quien produce el *furtum* en el lugar donde lo cometiera e incluso cuando se le sorprendía transportando la cosa.

Dispone la ley la posibilidad de imponer la pena del *furtum manifestum*, cuando el perjudicado realizase una investigación solemne, denominada *persequitio lance et licio*. A tal fin debía penetrar en el lugar donde presumía que se encontraba la cosa objeto de *furtum*, vestido solo con un *licium* (vestidura ligera, usada por los antiguos romanos) y llevando en su mano un platillo (*lanx*). No se conoce a ciencia cierta el sentido de este ritual, presumiéndose que intervenían en el contenido de tipo religioso.

Otros casos de *furtum* son los llamados *furtum conceptum* y *furtum oblatum*. El *furtum conceptum* se caracteriza por el hallazgo de la cosa, frente a testigos, en casa de un tercero, otorgándose acción contra éste último, aunque no fuere quien la hubiera sustraído.

El *furtum oblatum* se producía cuando alguien llevaba el objeto del *furtum* a la casa de otro con la intención de que ella fuese encontrada allí y no en la suya. Quien la había recibido poseía una acción contra quien se la dio, aunque éste no fuera el autor del *furtum*.

Para ambos casos (*furtum conceptum* y *furtum oblatum*) la Ley de las Doce Tabas establecía la pena del triple del valor de la cosa (Gayo, Inst. III, 191).

Si se trataba del *furtum nec manifestum* (no manifiesto) la pena era del duplo (Gayo, Inst. III, 190).

Respecto a las cosas que han sido objeto de *furtum*; quien las posea, aún de buena fe, no podía usucapirlas (Gayo, Inst. II, 45).

Se reprime el cobro de intereses elevados entendiéndose por tales los que excedan el doce por ciento anual, penándose con el cuadruplo al usurero.

Contra el depositario infiel, que se apropiaba indebidamente de la cosa, la ley otorga una acción por el doble.

También se instituye una acción destinada a remover a aquel tutor que resultara sospechoso de mala administración de la tutela (*crimen o accusatio suspecti tutoris*). Esta acción podrá ser intentada por cualquiera, mereciendo el calificativo de *quasi pública*, ya que no se permite la acusación por parte del pupilo.

Asimismo, contra el tutor que hubiese distraído los bienes del pupilo, la ley concede una acción cuya pena es el doble del valor de las cosas sustraídas. (*Actio rationibus distrahendi*).

El patrono que defraudare a su cliente, era declarado *sacer* (excecrable).

A quien debidamente citado para declarar como testigo, se negare a hacerlo, la ley le impone la tacha de infamia, incapacitándolo para dar testimonio; incluso se ha considerado que es indigno de que se de testimonio por él. Igual pena alcanza al *libripens* (AULIO GELIO: "Noches Aticas", XV, 13 y D. 28, 1, 26).

Contra quien diese falso testimonio, la ley disponía se le diera muerte, precipitándolo de la roca Tarpeya (AULIO GELIO: "Noches Aticas" XX, 1).

Sobre la base de textos de Festus y Plinius, algunos autores, en sus intentos de reconstrucción, incluyen en esta Tabla disposiciones que imponen la pena capital contra quien cometiera homicidio en la persona de un hombre libre. La misma pena impone la ley a quien, utilizando encantamientos o venenos, haya sometido a otro.

Igual pena, al parecer, era impuesta a los grupos de agitadores urbanos nocturnos.

La Tabla termina con disposiciones referidas a los miembros de un mismo Colegio o Asociación (*sodales, cōfrades*) a quienes permite establecer pactos o reglamentos libremente, siempre que no infrinjan la ley pública (D. 47, 22, 4).

La Tabla Novena posee disposiciones de derecho público y penas contra Magistrados, funcionarios y ciudadanos que cometan traición.

La Tabla prohíbe que se dicten leyes sobre los particulares, pues resultarían injustas por constituir privilegios. (CICERON, De Legibus, III, 19).

También se dispone que únicamente los comicios centuriados podían imponer penas o sentencias capitales a los ciudadanos (CICERON, De Legibus, III, 19).

Se impone la pena de muerte a aquel juez o árbitro que, nombrado de acuerdo a la ley, se deja corromper por dinero (AULIO GELIO, Noches Aticas, XX, 1).

También se refiere a que las causas que merezcan pena capital no podían ser juzgadas por los Cónsules. A tal fin se nombraron funcionarios llamados *Quaestores Parricidii* (D. 1, 2, 23).

Además, contra las sentencias que imponían pena capital, podían los ciudadanos recurrir ante el comicio centuriado (*Ius Provocatio Ad Populum*) (CICERON, De República, II, 31).

Quien hubiere incitado al enemigo o entregado a éste un ciudadano, sufra pena capital (D. 48, 4, 3).

La Tabla Decima trae una serie de disposiciones relativas a los ritos funerarios. En ella se advierte el cuidado de las costumbres austeras, evitando el excesivo ornato y las manifestaciones exteriores, contrarias a la severidad y gravedad, virtudes éstas propias del espíritu romano. Así, entre otras disposiciones, se prohíbe enterrar o quemar los muertos en el recinto de la ciudad, embalsamar los cuerpos de los esclavos; los banquetes funerarios; hacer muchos funerales y túmulos por un solo muerto, etc.

Además no podían colocarse los sepulcros a menos de 60 pies del edificio ajeno, salvo que lo consintiera el propietario.

Por otra parte, no podían adquirirse por usucapión los sepulcros. (CICERON, De Legibus, II, 24).

La Tabla Undecima establece la prohibición de matrimonio entre patricios y plebeyos.

Uno de los requisitos matrimoniales, era el *Ius Connubium*, derecho que otorgaba capacidad especial para contraer justas nupcias (*Iustae Nuptiae*), que es el matrimonio conforme al Derecho Civil.

En esta Tabla se disponía que los patricios y plebeyos no gozaban, entre sí, de tal aptitud. Lo injusto de esta prohibición hace que Cicerón califique como inocua a esta Tabla, que fue posteriormente derogada por un plebiscito, que se conoce como *lex Canuleia* (445 a.C.) (CICERON, De República, II, 37).

En la Tabla Duodecima se introduce la *Pignoris Catio*, acción de la ley ejecutiva que permitía al acreedor, en determinados casos, tomar posesión de ciertas cosas.

En la Instituta de Gayo (IV, 28) se describen dos supuestos en los cuales procedía la *pignoris catio* para la Ley de las Doce Tabas: tal el caso de la compra de un animal para ser utilizado en un sacrificio y cuyo precio no hubiese sido pagado. La explicación del supuesto puede hallarse en el hecho que las víctimas de los sacrificios debían ser aceptadas por los pontífices, motivo por el cual podía diferirse el pago hasta el momento de la aceptación.

El otro caso contemplado por la ley se configuraba cuando alguien, con el objeto de obtener el dinero necesario para realizar una ofrenda, alquilaba un jumento. Si el alquiler no era satisfecho, podía el dueño del animal, recurrir a la *pignoris catio*.

Posteriormente la costumbre y otras disposiciones legales introdujeron otros supuestos de aplicación. La *pignoris capio* significa que la acción se dirige contra la cosa y no contra la persona, como en la *manus iniectio*.

Se ha discutido acerca del carácter judicial o extrajudicial de esta acción. Si bien por sus características, al permitir la apropiación directa de la cosa podría afirmarse su carácter extrajudicial, podía en algunos casos recurrirse ante el magistrado cuestionando la validez del procedimiento. Es decir que lo extrajudicial era la aprehensión de la cosa del deudor, lo que no lo convertía en propietario al acreedor sino en poseedor con derecho a retenerla hasta que la deuda fuere saldada.

También esta Tabla dispone acerca de las acciones noxales, derivadas de furtum cometido por un esclavo. Si el dueño sabía del furtum cometido por el esclavo, existía contra él la acción a nombre del esclavo no quedando obligado en su propio nombre (D. 9, 4, 2, 1).

Se establece también que para el caso que alguien se hiciese dar falsamente la posesión interina, percibiendo los frutos durante su transcurso, el Magistrado debía nombrar tres árbitros, de cuya sentencia resultaría condenar a restituir el doble de los frutos. En cuanto a quien consagrar cosas litigiosas, es decir comprometidas en pleito, la ley le impone pena del duplo de su valor. Finalmente contiene esta última Tabla una disposición que establece que las leyes dictadas en último término derogan las anteriores.

Las Fuentes Republicanas

a) La Lex

Según Gayo (Inst. I, 3) Lex es lo que el pueblo ordena y establece. Este concepto adquiere jerarquía en la época republicana y comienzos del imperio, para ir perdiendo luego por obra de las constituciones imperiales que, en el bajo imperio, serán denominadas *Leges* por oposición a las respuestas de los jurisperitos (*Iura*).

Capitón, citado por Aulio Gelio (Noches Aticas, X, 20) define a la *lex* como un decreto general del pueblo, dado por éste a propuesta de un Magistrado.

Tanto Gayo como Capitón se refieren a la *lex rogata*. Además de esta especie se distingue la *Lex Data*, es decir la dada por el Magistrado sin intervención del *populus*, aunque autorizado por éste.

Tales los casos de aquellas por la que se constituían y organizaban provincias o colonias.

Normalmente el Magistrado la daba de acuerdo con una Comisión nombrada por el Senado. En caso de que ella no se hubiese conformado, era costumbre someter la regulación a la anuencia del Senado.

Para la *Lex Rogata*, el Magistrado proponente, quién debía gozar del *Ius Agendi Cum Populus* (Cónsul, Dictador, Decenviro, Tribuno Militar con Potestad Consular) daba a publicidad su proyecto a través de la *Promulgatio*. Se efectuaba el mismo fijándolo en el Foro durante 3 días de mercado. Durante ese lapso era discutido en reuniones desprovistas de formalidad (*Contiones*). En tal ocasión podían sugerirse modificaciones a la propuesta original, las que podían o no ser aceptadas por el proponente.

Antes de la consideración del proyecto por el Comicio, se realizaban los auspicios, a fin de que los dioses fueran propicios.

Incluso, en ciertas épocas, se requería del Senado la *Auctoritas Patrum*. Efectuábase luego la *rogatio* al *populus* reunido en los comicios curiados, centuriados o tribados. La misma consistía en la interrogación para que se aprobara o se rechazara el proyecto. Quienes optaban por la aprobación usaban la expresión *Uti Rogas* (como lo pides, conforme a tu propuesta). Caso contrario, la fórmula empleada era *Antiquo*, con lo que se quería decir que se optaba por no modificar el estado anterior, lo que implicaba el rechazo de la propuesta.

Una vez aceptada la ley, en determinada época, se requería del Senado la *Auctoritas Patrum*, para luego ser depositada en el Templo de Saturno por los Cuestores.

En la *lex*, pueden distinguirse diferentes partes.

El *Index* anunciaba, suscitantemente, el contenido de la ley. En la *Praescriptio*, se asentaba el nombre del Magistrado rogante, el lugar de reunión del comicio, el nombre de la centuria que había votado en primer término (es decir que gozaba de *praerogatio*) y nombre del ciudadano que votó en primer lugar.

La *Rogatio* era la propia ley, tal como había sido sometida a la aprobación del *populus*.

Y la *Sanctio*, que contenía las disposiciones encaminadas a tornarla eficaz.

Como se desprende de lo dicho, las leyes eran cosas santas (*Res Sanctae*). Siguiendo a Ulpiano (D. 1, 2) las leyes pueden ser clasificadas en *Perfectae*, *Minusquam Perfectae* e *Imperfectae*.

Perfectae (perfectas) son aquellas en cuya *sanctio* está prevista la nulidad de los actos realizados en contra de sus disposiciones, a manera de pena.

Minusquam Perfectae (menos que perfectas) que castigan a los transgresores sin invalidar los actos opuestos a la ley.

Imperfectae (imperfectas) resultan ser aquellas que no prevén sanción para actos contrarios a la misma.

Después, con el imperio, una Constitución de los Emperadores Teodosio II y Valentiniano III establecerá que los actos efectuados en contra de la disposición legal serán tenidos por inútiles y no hechos, con lo cual todas las leyes podrán ser consideradas perfectas (Cód. I, 14, 5). El nombre de la ley, generalmente, adopta el gentilicio de sus autores, en nominativo femenino, al que se le agrega, en algunos casos, el tema sobre el que versa la ley.

Si llevaba dos nombres se debía a que había sido propuesta por un Cónsul,

agregándose el nombre de su colega. Así la *Lex Poetelia Papiria de Nexis* propuesta por el Cónsul Poetelio, conjuntamente con su colega Papirio, por la que se abolió el *nexum* (326 a.C.).

Cuando tenían un solo nombre, la propuesta había emanado de algún Magistrado extraordinario (por ej. un Dictador). Así, la *lex Hortensia*, rogada por el Dictador Quintus Hortensius.

b) Plebiscito

El Plebiscito, al decir de Gayo (Inst. I, 3) es lo que el pueblo ordena y establece, aclarando que ha de entenderse por *Plebs* (plebe) todos los ciudadanos excluidos los patricios, por oposición al concepto de *populus* (pueblo) que comprendía tanto a patricios como a plebeyos.

Es decir que los plebiscitos eran las decisiones surgidas de los *concilia plebis*, a propuesta de un Tribuno.

Esta situación, por la cual los patricios no participaban en el dictado de los plebiscitos, hará que éstos no se consideren obligados por ellos. Así Gayo (Inst. I, 3) sostiene: "... es por esto que los patricios decían no estar obligados por los plebiscitos, ya que su autoridad no intervenía en ellos...". Tal circunstancia se vio modificada por la aparición de la *lex Hortensia* (236 a.C.) que estableció que los plebiscitos obligaban a la totalidad del *populus*, asimilándoselos, de esta manera, a las leyes.

Ya, anteriormente, habían existido las leyes *Valeria Horatia* (448 a.C.) y *Publilia* (338 a.C.) que debieron relacionarse con la *auctoritas patrum*, suprimida de manera definitiva por la *lex Hortensia*.

De tal modo, algunos plebiscitos recibían la denominación de ley, como el caso de la *lex Aquilia* (286 a.C.).

Cierto es que, los plebiscitos tienen por materia, principalmente, la regulación del derecho privado, reglando en gran medida sus instituciones.

Los plebiscitos aparecen denominados por un solo nombre, que corresponde al del Tribuno proponente sin incluir a sus colegas, atento el número de los integrantes de esta Magistratura colegiada.

c) Edicto

El edicto es una fuente de derecho basada en el *Ius Edicendi*, prerrogativa de la que gozaban los *Magistrados populi romani*, es decir aquellos provistos de *imperium* (Cónsul, Dictador, Pretor, Ediles Curules y Gobernadores de provincias).

El más importante de los Edictos provenía del Pretor, tanto del *Urbano* como del *Peregrino*.

El conjunto de las disposiciones contenidas en los Edictos va a recibir, posteriormente, el nombre de *Ius Honorarium* o *Ius Praetorium* (derecho honorario o pretoriano).

El *imperium* le permitía al Magistrado dirigirse al pueblo ejerciendo la potestad de mando y decisión que le era inherente.

La acción de *Edicere*, consistía en comunicar, en forma oral, la orden del Magistrado, que una vez transcrita era expuesta públicamente para el conocimiento general.

Cuando, luego, fue normal hacerlo directamente por escrito se conservaron las formas primitivas.

Mediante el *Ius Honorarium*, el Pretor declaraba los principios jurídicos en base a los cuales debían dirimirse los conflictos entre particulares. Estos principios jurídicos llegaban al pueblo a través del Edicto.

Además existe en el Edicto una labor creadora por parte del Magistrado. En muchos casos, no estaba prevista en el *Ius Civile* la solución de determinadas situaciones jurídicas que merecían la tutela jurisdiccional. Van a ser estas materias consideradas en los Edictos.

Es decir, que por la vía del Edicto de los Magistrados es que se producirá la importante mutación de las arcaicas y vetustas formas del Derecho Quiritario.

Se ha admitido que, fundado en su *imperium*, el Magistrado, por medio de Denegaciones, concediendo Interdictos, imponiendo *Stipulationes* y *Missiones In Possessionem*, creó una nueva forma procesal.

Este sistema, al que se conoce como procedimiento formulario, será legislado a través de la *lex Aebutia*, en la segunda mitad del siglo II a. C.

Clases de Edictos

Edicto Perpetuo: Al inicio de su magistratura anual, el Pretor publicitaba su Edicto, el que se exponía en tablas ubicadas en el Foro. Su vigencia se extendía a lo largo de su gestión.

Contenía una especie de a que casos y bajo cuales circunstancias otorgaría su tutela jurídica; es decir, explicitaba las fórmulas de las acciones, de los decretos, de los interdictos y disponía sobre el ejercicio de la jurisdicción.

Edicto Traslaticio: Si bien el Pretor no estaba obligado a adquirir como propio el de su predecesor, era frecuente otorgarle nueva vigencia, haciéndole los agregados o las modificaciones que estimare convenientes. Es este el Edicto *traslatitium* o *vetus*.

Edicto Repentino: Cuando se planteaban casos concretos, no previstos en el Edicto Perpetuo, la solución surgía por el dictado de un nuevo Edicto, denominado *Edictum Repentinum*.

d) Respuesta de los prudentes

"... El Derecho Civil permaneció escondido por muchos siglos entre las cosas sagradas y las ceremonias de los dioses inmortales, solamente conocido por los pontífices (VALERIO MAXIMO: 2, 5, 2).

En un primer momento —época monárquica— las cuestiones inherentes a la interpretación del derecho estaban a cargo del Colegio de los Pontífices, quienes incluso asesoraban al rex en las cuestiones judiciales.

Los pontífices eran quienes custodiaban las formulas solemnes. Reservaban para sí no solo la exclusividad en el conocimiento del ius, sino además, el calendario.

Esta última circunstancia permitía saber en cuales días era posible realizar los actos judiciales (*Dies Fasti*) y en los que estaban vedadas tales actividades (*Dies Nefasti*).

Este Colegio, a ese momento, era privativo de los patricios. En consecuencia, y no obstante la aparición de la ley decenviral a instancias de los plebeyos, continuaba tal monopolio, hasta el siglo III a. C. cuando, según la tradición, CNEO FLAVIO, escriba del pontífice Appio Claudio Caecus, hizo conocer las fórmulas judiciales (*Liber Actionum*) y el calendario. Al parecer, su tarea se limitó a una transcripción, careciendo de creatividad. No obstante, al permitir conocer públicamente lo antes reservado a los pontífices, hizo que su obra poseyera notoriedad. Esta fue conocida como *Ius Flavianum*.

Al llegar el plebeyo TIBERIO CORUNCANIO al Pontificado Máximo (254 a. C.) comenzará a enseñar públicamente el derecho profano, rompiendo así la tradición de reserva exclusiva.

Permitese, de esta manera, que los principios del derecho queden abiertos al estudio, desarrollándose así una verdadera ciencia jurisprudencial que permite la aparición de la jurisprudencia laica.

A comienzos del siglo IV a. C., la tarea de Cneo Flavio será completada por SEXTO AELIO PETO (El Astuto) quien publicará las fórmulas realizadas por los pontífices y los primeros jurisconsultos (*Ius Aelianum*).

También se atribuye a Sexto Aelio Peto una importante obra denominada *Triperitita*, por constar de tres partes. La primera comprende un comentario y texto de la Ley de las Doce Tablas. La segunda, la interpretación realizada por pontífices y jurisconsultos sobre la ley de las Doce Tablas (*Interpretatio*). Y, finalmente, las nuevas fórmulas de las acciones de la ley (*Legis Actio*), ya incluidas en el *Ius Aelianum*.

La introducción del proceso formulario, trajo para la labor pretoriana una serie de situaciones que la tornaron compleja. Por ello, el Magistrado, que con frecuencia desconocía los tecnicismos propios de la aplicación del ius, se vio obligado a recurrir a expertos. A estos entendidos se los denominaba *Iurisprudentes* o *Iurisconsultis*, es decir aquellos que eran consultados en virtud de su prudencia en la aplicación del derecho.

Ha de entenderse por prudencia la adecuación a la naturaleza de los hechos.

Estos expertos orientaban a las partes y a los Magistrados sobre la solución adecuada a las particularidades del caso concreto.

Sin embargo, la opinión de los jurisperdentes no era vinculante, es decir, no obligaba a los Magistrados. No obstante, por el prestigio de los jurisconsultos, era difícil que el Pretor se apartara del criterio de los mismos.

La actividad de los IURISPRUDENTES se manifestó, entonces, a través de una casuística especialmente rica, que permite extraer líneas generales de situaciones particulares.

Además de los consejos del *Prudens* para la resolución de los pleitos (*Respon-dere*) se ocupaban de redactar las cláusulas para instrumentar los negocios ju-

rídicos (*Cavere, prever*) y dirigir a los litigantes y a sus defensores (*Oratores*) en el desarrollo del juicio (*Agere, obrar*).

La jurisprudencia, en esta época, no puede considerarse con seguridad como una autentica fuente de derecho.

Sin embargo, la enjundia de sus representantes configurará la *Interpretatio Prudentium*, conformada por la opinión concordante de los juristas de mayor importancia, que fuera adoptada por los jueces (*Sententiae Receptae*).

No puede omitirse la enseñanza del derecho (*Instruere*) y exposición de temas jurídicos a cargo de los jurisperdentes quienes, además, de manera indirecta ejercieron eventualmente su influencia actuando como Magistrados y jueces.

De tal manera han quedado sentadas las bases para lo que luego será el período más significativo de la jurisprudencia romana, que alcanzará su esplendor en la denominada época clásica.



FRANJA MORADA

Capítulo 5

SUMARIO:

- I. La concepción romana de imperium.
- II. El fin de la República.
- III. Una nueva etapa : El imperio.
- IV. Características del principado.
- V. La decadencia : El bajo imperio.
- VI. Características del dominado.

EL IMPERIO

La Concepción Romana de Imperium

La idea de Imperium no se compadece en los romanos con la moderna de imperialismo (ver "el hombre, la tierra y las armas"); así no puede ser asimilada a los imperialismos inglés o francés del siglo pasado o la actual concepción marxista.

Es que como en la tarea agrícola, como en la fundación de ciudades, presenta un componente espiritual.

Como enseña A. Di Pietro, Roma descubre un mundo que ofrece el triste espectáculo similar a un jardín abandonado y desordenado, con continuas guerras de supremacía, sin ideas, ni orden, ni cosa común. Asume entonces, cual jardinero, la tarea de "desmalezar, podar", organizar, para que entre los pueblos fructifique la pax.

Imperium es el poder de mando que, en la tarea del agricultor, debe ser bien aplicado respetando la naturaleza para obtener frutos generosos. En la ciudad, el poder de mando se visualiza en el Imperator, el general, que conocedor de las tropas, de la estrategia y el arte de la guerra ha de saber ordenar aquello que conduzca al ejército a la victoria, con la ayuda de los dioses a los que representa.

Por fin, en la empresa política, el imperio consiste en ordenar las ciudades, las "gentes", respetando sus individualidades, conjugadas en el ideal común de la pax.

Esta expresión significa "estar afirmado", pisar sobre terreno firme; consiste en lograr un orden que —ponderando características propias, instituciones, cultos, modos de vida— lleve a los pueblos a un diálogo que los persuada que tal es el más conveniente de los estados políticos.

Si se repara en las grandes distancias de un confín al otro del imperio, en las dificultades en las comunicaciones propias de la época, en la conformación de las fuerzas militares (250.000 hombres y otro tanto de tropas auxiliares-siglo II), en la diversidad de razas, costumbres y lenguas, religiones e idiosincrasias, resulta claro que no pudo ser sólo mediante la fuerza que hubo de reunirse, y mantenerse unido, a tal conglomerado.

El respeto al orden natural que imponía las virtudes de la *Pietas* y de la *Humanitas*, es decir, el acatamiento a los dioses y la moderación con los vencidos, debieron resultar decisivos. De allí también su enfrentamiento con los pueblos cuya belicosidad e idea de dominación con sumisión, atentaban contra el ideal de la paz y la concordia entre las gentes.

Así para Roma el *Imperium* se muestra como la misión de administrar, proteger y tutelar al mundo y las naciones, para que produzcan lo óptimo que le sea posible.

El fin de la República

Roma, que en sus orígenes había formado parte de la confederación latina, luego de varias rencillas menores reingresa en la misma, gracias al Pacto Cassianum, (493 a.C.).

Esta alianza hará que el latino no sea extranjero en Roma ni el romano lo sea en el Lacio. Gozan del *Ius Connubii* (que permite contraer matrimonio conforme al Derecho Civil); del *Ius Commercii* (que faculta para realizar los actos y negocios del mismo derecho); y el *Ius Migrandi* (que por el solo hecho de fijar su domicilio en Roma convierte al latino en ciudadano romano).

En tanto, los habitantes de las Colonias solo gozan del *Ius Commercii*, lo que implica lógicas diferencias de trato, causa de serios conflictos con la urbe.

Con el Pacto Cassianum comienza una etapa de incesante expansión, que hará desaparecer primero a la Liga Latina (338 a.C.), y luego la Liga Hernica (306 a.C.), con lo que el Lacio será totalmente romano.

A partir de lo cual, mediante múltiples alianzas, se consolidará su poderío sobre los pueblos habitantes en el resto de la península itálica. Estos acuerdos, concretados pacífica o violentamente, que someten a las diferentes comunidades poseen la apariencia de pactos federativos. Admiten diversas formas de predominio, pero siempre reconociendo a Roma su autoridad, que asegura su hegemonía en tales territorios.

Con el tiempo a la península itálica se agregaran Cartago, Córcega, Cerdeña, la península Ibérica, la Galia meridional, el Peloponeso, Macedonia, Corinto, Rodas, Egipto. . . quedando así el Mediterráneo en su totalidad bajo la égida romana, al punto de llamarle "*Mare Nostrum*".

El descomunal esfuerzo militar que significó, como así las dificultades inherentes a tal amplitud territorial, obligó a la modificación de las estructuras políticas internas. Los territorios adquiridos generalmente se transforman en provincias, cuyo frente estará un jefe militar con el cargo de Gobernador.

Por otra parte, a la manera de las Metrópolis, se crean magistraturas especiales, a cargo de quienes —habiendo completado en Roma su mandato— se les prorrogaba en las provincias con la denominación de procónsules, propretors, etc.

Como ya se señalara, los tratados ("*Foedera*") celebrados por los diferentes pueblos poseían disímiles características no obstante lo cual poseen rasgos comunes. Así en todos se reconoce la "*Maiestatem populi romani*", se renuncia a toda política exterior que no responda a las líneas marcadas por Roma y se asume el compromiso de ayudar a ésta frente a cualquier ataque exterior.

Para consolidar su posición era menester lograr la romanización de los pueblos incorporados, obteniendo de dicha manera un mayor control. A tal fin se crearon las Colonias.

La nueva situación generaba al poder central obstáculos prácticamente insalvables. Era difícil dominar la corrupción de los funcionarios provinciales, la recaudación en provecho propio de impuestos a expensas del Estado, etc. La riqueza se concentraba mayormente en miembros de la clase senatorial y el orden ecuestre, que obtenían tierras a bajos precios y efectuaban toda suerte de negocios usurarios.

En el mercado interno no era posible sostener los grandes cultivos de cereales; los campesinos habían cambiado el ganado por la lanza. Se tiende a reemplazar hombres libres por esclavos, a pesar de las graves consecuencias sociales y políticas que tal actitud implica. Los trabajadores rurales que no integraban el ejército se concentraron en Roma provocando, junto a la gran cantidad de esclavos por cautividad de guerra, (que significaban mano de obra a bajo costo), el problema de la desocupación.

En tales momentos de grandes tensiones es que irrumpe en la escena política Tiberio Sempronio Graco (134 a.C.), iniciando desde su elección como Tribuno un período de sistemática oposición al Senado, apoyado por un grupo que bregaba por una suerte de retorno a la monarquía.

Tiberio Graco pretendía que las grandes extensiones rurales del Estado, concedidas a poderosos terratenientes, fuesen entregadas a los desposeídos. Tal proyecto encontró fuerte resistencia en sectores aristocráticos. No obstante el sobreveniente asesinato de T. Graco, sus continuadores lograrán la aprobación.

Otro factor de conflicto resulta la presión de los pueblos itálicos sobre el gobierno central, en pos de conseguir la ciudadanía romana. Sumábase, agravando la situación, la *Lex Licinia Mucia* (90 a.C.) que abolía el *Ius Migrandi*.

Escipión Emiliano (el segundo "Emiliano", vencedor de Cartago) y Cayo Graco (hermano de Tiberio), representaban a los rebeldes.

En el 121 a.C., los terratenientes harán abolir las leyes agrarias de los Graco y relegar los proyectos de ciudadanía para los itálicos; hechos generadores de la "guerra de los aliados" o "guerra italiana", que terminará con el triunfo de los alzados contra el poder central.

Una nueva etapa: El Imperio

Antes de analizar la figura de Octavio Augusto, con que se inaugura el Imperio, es ineludible —aún someramente— referirse a quienes tendrán mucho que ver en la conformación de esta nueva forma política: Mario, Sila, Pompeyo y César.

Cayo Mario había sido Tribuno y brillante militar en la lucha contra los invasores celtas. Hijo de un jornalero, llegó al Consulado y en el 100 a.C. es elegido por sexta vez para esa Magistratura. En esa época se enfrenta y triunfa sobre los partidarios de su colega Lucio Saturnino, defensor de la política de los Graco.

Es este general quien prepara la revolución de César, introduciendo un concepto nuevo en la estructura de las milicias. Convoca a los proletarios urbanos, al ejército, asegurándoles una significativa retribución, convirtiéndose las legiones en un cuerpo profesional. A consecuencia de ello se consolida la idea de que el ejército se debe a sus generales, pudiendo oponerse validamente al gobierno de Roma.

Luego de las luchas y conflictos suscitados por la lucha de los itálicos en pos de la consecución de la ciudadanía romana, surgirá la figura de Lucio Cornelio Sila. Este general de origen aristocrático, luego de sitiar Roma, la gobernará por 17 años hasta el 70 a.C. Durante su gobierno el poder se concentrará en el Senado. Se abolirán los privilegios de los caballeros y reinstaurarán los comicios centuriados. Como dictador restó autoridad a los cónsules los pretores y el Tribunado.

A Sila le sucederán Craso y Pompeyo, quienes llegan al Consulado en el 70 a.C.

Cneo Pompeyo había participado con notable éxito en las campañas de Sicilia y Africa, y por sus brillantes condiciones militares fue apodado "El Grande". Su gobierno tuvo por característica el desmantelamiento de lo logrado por Sila. Su elección contó con el apoyo de los capitalistas, quienes influyeron para disminuir los atributos del Senado, recuperando los Tribunos y Caballeros la amplitud de sus poderes. Con motivo de una campaña para lograr el exterminio de los piratas de Cilicia, el Senado otorgó a Pompeyo ilimitados poderes, que virtualmente lo transformaron en un monarca. Con ello la república inicia una lenta agonía.

Cayo Julio Cesar, figura indiscutida de la historia romana, es señalado por muchos autores como verdadero iniciador del Imperio. Esta destacada personalidad política y militar es considerada como líder del grupo continuador de la línea política de los Graco. Pretor en Roma, Propretor en España, va luego a establecer un pacto con Craso y Pompeyo, con quienes integrará el primer triunvirato.

Sus excelentes campañas militares en Galia y Germania, serán la ferrea consolidación de su figura. A la muerte de Craso, concluida la misión de César en Galia, el enfrentamiento entre este y Pompeyo será inevitable.

Por su extraordinaria habilidad César obtendrá el triunfo en la batalla de Farsalia, donde Pompeyo intentaba cercarlo. Luego en Tapso y Munda nuevos exi-

tos militares coronarán su campaña, aniquilando definitivamente a los partidarios de Pompeyo.

La derrota de Pompeyo es también la del Senado. César se convierte en Dictador, concentrando los amplios poderes de tal magistratura. En el 48 a.C., por la *potestad tribunicia* que se le otorga, en investido con las atribuciones de un Tribuno. En la misma época adquiere la *Praefectura Morum* (vigilancia de las costumbres) y el derecho a designar a todos los magistrados provinciales y la mitad de los de Roma. De tal modo, Senado, Comicios y Tribunado se limitaban a la convalidación formal de las disposiciones ya impuestas por César.

La dimensión de su poder se evidencia en el hecho que llegó a pensarse que sus atribuciones eran hereditarias, como cuando dispone por testamento la adopción de su sobrino Octavio y su designación como heredero.

La modificación de la estructura política preocupa hondamente a los senadores de la aristocracia, quienes realizan una conjura para asesinarlo, lo que se produce en el 44 a.C.

Con la desaparición de César sobreviene un período anárquico que conduce a la constitución de un segundo triunvirato, formado por Antonio, Lépido y Octavio.

La subsiguiente lucha entre Antonio y Octavio traerá la derrota del primero y el afianzamiento del último, con quien se inaugura el Principado.

Características del Principado

El Senado confiere a Octavio, en el año 27 a.C., el título de Augusto, por el que será conocido. Tal designación significa el carácter sagrado, ya que puede ser traducido como "aquel que es sagrado por designación divina". comienza así la primera etapa del Imperio: el Principado.

Puede explicarse las características de esta nueva estructura política con el relato que ofrece Dion Cassio. Según éste, en una reunión de Augusto con sus amigos, se habría discutido acerca del tipo de organización política que convenía adoptar. Agrippa abogaba ante Octavio en favor de la República; Mecenas, por la Monarquía. Después de escucharlos Augusto, que habría compartido la sugerencia de Agrippa, sin embargo, se inclinó, en los hechos, por la idea de Mecenas.

Sin perjuicio de la veracidad del relato, en el aspecto formal, exterior, el gobierno de Augusto adoptará las características de la república, pero, por su conformación interna y real, será monárquico.

Sostiene De Francisci, que el Principado es un régimen esencialmente monárquico, introducido mediante la creación de un nuevo órgano injertado sobre la construcción republicana, conservada formalmente.

Se preserva la estructura republicana, pero por lo ilimitado de los poderes concedidos a Augusto, estamos ante una monarquía.

A ello se ha llegado porque, frente a la grave emergencia que vive Roma, se torna inevitable otorgar poder unipersonal a quien se considera capaz para guiar y conducir la reorganización del Estado.

Inaugurase así esta primera etapa del Imperio a la que se denominará Principado, en atención al título de *Princeps* dispensado a Octavio Augusto: príncipe por lo de *Princeps Senatus* (primero del Senado) a lo que al unirse el praenomen de *Imperator* (señor, dominador, jefe).

El aumento gradual de las facultades del príncipe y consiguiente disminución de la autoridad de los restantes órganos será característica de esta etapa. Las magistraturas mayores (Consulado, Pretura) al par que los Comicios se transforman en meros símbolos vacíos de poder.

El Senado, contrariamente, experimenta una notable ampliación de su competencia. De allí que Mommsen haya propuesto la tesis de que este período es el de una *Diarquia*, en el sentido de que la autoridad descansa en el Emperador y, en el Senado. Esta posición resulta desmentida por la realidad. Es que la máxima autoridad descansa en el Emperador. Las facultades reservadas al Senado solo pueden ejercerselas bajo el control del *Princeps*, quien tiene exclusivamente el derecho de convocarlo. Además el propio Senado es quien inviste a Augusto con la amplitud de poderes. Entre ellos la potestad tribunicia dada vitaliciamente, por la que puede convocar a los Comicios y al Senado y vetar las decisiones de los magistrados. Por el *Imperium Proconsulare*, el Emperador detenta el poder sobre el ejército y las provincias sin requerir para ello consulta previa al Senado.

Las provincias son divididas en las del pueblo romano, cuya administración se reserva al Senado, y las del César a cargo del Emperador. Se cree que la división obedeció a la necesidad de encomendar, por 10 años, a Augusto el gobierno de aquellas provincias tenidas por peligrosas por no haber sido totalmente pacificadas. En la realidad el Senado no tenía ingerencia en las provincias del César, pero si el Emperador en aquellas pertenecientes al Senado.

Otras facultades se concedieron a Augusto, quien progresivamente llegaría a ejercer el poder absoluto. Así la *Cura Legum Et Morum*, que le permitió renovar las leyes y vigilar las costumbres, y la *Cura Et Tutela Rei Publicae Universae*, otorgada como la facultad de que no podía existir ley que se opusiese a las decisiones del Emperador. También asumió la función de *Pontifex Maximus*, que le daba el poder para ocuparse de lo relativo a la religión, el culto y las ceremonias.

La Decadencia: El Bajo Imperio

Hecho importante, por su significación en la evolución política posterior, fue la constitución Antoniniana, dada en el 212 d.C. por el Emperador Caracalla, que otorgaba el derecho de ciudadanía y con él el Derecho Civil romano a los pueblos del Imperio; suprimiendo diferencias entre los italianos y los otros habi-

tantes del mismo, desmantelando los cimientos del viejo Estado-Ciudad, haciendo desaparecer la preponderancia de los romano-italicos y denunciando las diferencias entre el derecho imperial y los derechos locales.

Existen tendencias coincidentes a dar por terminado el Principado con Alejandro Severo. Tanto él como Septimio Severo fueron los dos últimos emperadores que procuraron la legalidad para el Imperio, terminar con la soberbia militar y restablecer la autoridad del Senado y las buenas relaciones con las provincias, tal como lo habían realizado los antoninos.

Son muchas las causas que conllevan a las graves alternativas que vive Roma en ese tiempo.

En el frente interno, la situación es caótica. Desde el 235 al 285 d. C., hubo 26 emperadores y solo uno de ellos murió de muerte natural. Las tropas eran quienes proclamaban o deponían a los emperadores, llegando a su eliminación física, a veces, por motivos no demasiado trascendentes.

En el plano externo, debe señalarse el renacimiento del poderío de los persas, que provoca el ataque permanente contra las provincias romanas de Oriente, así como también la constante presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras del Rin y del Danubio.

Otra de las causas a que se atribuye la decadencia imperial, puede encontrarse en las importantes modificaciones que había sufrido, durante el Principado, la conformación del ejército. En el reclutamiento se prefería a la población rural; hombres más duros y sin ningún tipo de instrucción que aspiraban a tener los mismos privilegios que los del medio urbano.

Además, en esta época, el pueblo soporta una fuerte presión tributaria, con la consiguiente y sensible disminución de sus ingresos. La producción agrícola no había aumentado como para justificar mayores tributos, por no haber evolucionado adecuadamente las técnicas de explotación. Se hace evidente la paralización del comercio y la industria, fruto de las constantes guerras e invasiones.

El Senado luchó por conservar su supremacía. Lo logra con severas dificultades durante Tiberio, Calígula, Nerón, los Flavios y Trajano. Con Adriano, archiconocido por su estilo centralista, la lucha antisenatorial se hace notoria.

Los emperadores fueron quitando importancia a las atribuciones del Senado: en lo que se refiere a las provincias senatoriales, creando funcionarios que invalidaban al Senado; en la labor legislativa: ignorándolo y apoyándose en el *Consilium Principis*.

Además, sumase, el aumento del poder militar, luego de los acontecimientos que terminan con el asesinato de Alejandro Severo. Maximino será quien inaugurará el período de la anarquía militar. Así, al ser designado Caro como Emperador, no le preocupó lograr el aval del Senado para el desempeño de sus funciones.

De este modo va a comenzar el Dominado o Bajo Imperio, que tiene como iniciador a Diocleciano, quien es proclamado Emperador por sus tropas, en el 284 d.C. El será quien, durante algún tiempo, devuelva el orden al Estado.

Para ese momento no puede hablarse de un Estado Constitucional, empleando términos políticos modernos. Solo el ejército gobierna junto al Emperador; la nueva estructura militar provoca decisivos cambios en el aparato estatal.

El estancamiento en el crecimiento demográfico, obliga a Roma a buscar soldados entre los bárbaros, transfiriéndoles técnicas bélicas y armamentos. Los mejores hombres son reclutados entre los germanos, retribuyéndoseles con una buena paga y excelentes recompensas, lo que convierte al ejército en un cuerpo profesional, mercenario.

Las milicias de Diocleciano van a ocuparse, primordialmente, de atacar a los invasores. Esto hace que las tropas estuviesen siempre listas para marchar sobre las fronteras.

Va creándose una nueva clase, la de los militares, ahora totalmente desvinculada de la aristocracia senatorial. Los altos cargos del gobierno serán ocupados por los integrantes de esta nueva clase, quienes descalifican a los civiles.

Ante tal situación, y para asumir cierta independencia, Diocleciano decide encarar una total reestructuración del Estado, que se conoce en el nombre de Tetrarquía.

El poder se dividió entre cuatro Magistrados: Dos Augustos (Diocleciano y Maximiano) y dos Césares (Constancio Cloro y Galerio).

Con esta reforma también se intenta desplazar el centro político del Imperio; (Diocleciano instala su cuartel general en Nicomedia, Maximiano en Milán, Galerio en Sirmio y Constancio Cloro en Treveris) a la vez que asegurar una sucesión pacífica.

Con la tetrarquía, Diocleciano pone en marcha un sistema que divide al Imperio, sin afectar la integridad del Estado.

El máximo poder debía compartirse entre los dos Augustos. Pero, en los hechos, la autoridad de Diocleciano fue siempre preeminente. Hasta en los atributos divinos con que se investía a los Augustos se podían observar estas diferencias. Diocleciano recibió el de *Jovius* (por Júpiter) mucho más trascendente que el otorgado a Maximiano (*Herculius*, por Hércules).

Administrativamente, el Imperio se divide en 4 Prefecturas (Galia, Italia, Iliria y Oriente) 17 diócesis y 101 provincias. Cada una de las Prefecturas queda a cargo de un Augusto o un César. Al frente de la diócesis había un vicario y, en cada provincia un gobernador.

Diocleciano concentra bajo su control toda la actividad legislativa y administrativa del Estado. En estas tareas es asistido por un *Consilium*, cuyos integrantes eran elegidos por el mismo Emperador.

Durante su gobierno existió una marcada tendencia hacia las persecuciones religiosas. Llega a imponerse la pena de muerte para aquellos que no rindiesen culto a las divinidades del Estado (304 d.C.).

La creación de la nueva estructura política, junto a la militar, genera un mayor gasto fiscal, que es enfrentado mediante un autoritarismo casi absoluto, sobre todo en lo que hace a la recaudación tributaria.

Esto genera una nueva forma de gobierno, inspirada en una marcada influencia

de formas despóticas orientales, lo cual producirá graves tensiones que van a culminar en el naufragio del sistema, y dará como resultado la guerra entre Augustos y Césares.

Cuando Diocleciano organizó la tetrarquía dispuso, a fin de no perpetuar a los Augustos, que luego de un tiempo abdicasen en favor de los Césares y designasen a sus sucesores. Esto se produce en el 305 d.C., cuando Constancio Cloro y Galerio se convierten en Augustos y designan como Césares a Severo y a Maximino Daza. Pero los relevos no son aceptados por quienes alegan mayores derechos para ocupar tales cargos. Tal el caso de Majencio (hijo de Maximiano) y de Constantino (hijo natural de Constancio Cloro). Estas actitudes van a dar como resultado una serie de luchas y una gran confusión. En un momento determinado habrá 6 Augustos: Severo, Maximino Daza, Constantino, Majencio, Maximiano y Flavio Licinio, éste último designado por Galerio.

Constantino derrota a Maximiano en Marsella, Galerio muere en el 311 d.C. y así va triunfando sobre los demás aspirantes al poder. En la batalla del puente Milvio elimina a Majencio y organiza un gobierno concertado con Flavio Licinio.

Después de arduas luchas contra Licinio, logra derrotarlo y queda como único Emperador (323 d.C.).

A fin de concluir con el difícil problema religioso Constantino había dictado, junto a Licinio, el Edicto de Milán (313 d.C.) por el que se disponía la tolerancia de cultos y el cese de las persecuciones a los cristianos.

Aunque en ese entonces Constantino hace pública profesión de fe cristiana, esto podría no ser tomado más que como una hábil estratagema política.

Por eso es que aunque hay autores que expresan que, con Constantino, el Cristianismo fue religión oficial, a nuestro juicio, ello está lejos de la verdad.

En su Corte se rodeó de filósofos y eruditos paganos y, raramente, asistía a las ceremonias cristianas. Además nunca promovió directamente el culto cristiano, ni instaba a sus subditos a abrazar la nueva religión. Su lenguaje era demasiado ambiguo cuando debía opinar sobre cuestiones religiosas.

Como contrapartida debe señalarse que no solo toleraba al Cristianismo, sino que, además, lo protegía, concediéndole exenciones impositivas y persiguiendo sectas heréticas.

A pesar de las dudas que concita la actitud de Constantino respecto del Cristianismo, lo cierto es que la tradición nos ha acercado su visión de la cruz que observó en el cielo, en la víspera de la batalla de Puente Milvio, donde vencería a Majencio.

En esa cruz, según relata Eusebio, estaba el mensaje: *In Hoc Signo Vinces* (con este signo vencerás) que motivó a Constantino a aliarse con los cristianos. Luego, cerca de su muerte, se convertirá.

Puede pensarse que Constantino, deseando unidad y pacificación, vio la conveniencia de utilizar al Cristianismo aprovechando su ferreo dogma, sus valores trascendentes y la disciplina de sus seguidores.

Constantino modifica las bases que había elaborado Diocleciano. Abandona la tetarquía y divide a Occidente en 3 prefecturas, mientras que Oriente queda a cargo, colegialmente, de dos prefectos.

Reorganiza el *Consistorium*, colocándolo bajo la dirección del *Quaestor Sacra Palatii*. Este organismo preparaba las leyes y entendía sobre los recursos.

En este período se nota, cabalmente, la influencia y progresiva preponderancia de la cultura greco-oriental sobre la latina. Constantino traslada la capital del Imperio a la ciudad que llevaría su nombre: Constantinopla, edificada sobre la antigua Bizancio.

De esta forma, el vencedor de Milvio será quien inicie el desplazamiento del centro de poder hacia Oriente.

Comienza a advertirse un acomodamiento de la legislación, que contempla costumbres e instituciones greco-orientales.

La influencia del Cristianismo irá haciéndose sentir, como dijéramos, a partir de la tolerancia del edicto de Milán. Con Constancio será la cristiana religión del Estado, para ceder en época de Juliano, Joviano y Valentiniano y afirmarse con Graciano y Teodosio; haciéndose sentir en el derecho las cualidades propias de la ética cristiana.

Características del Dominado

Ahora, a diferencia de la época de Augusto, el poder del Emperador es absoluto. Según la práctica impuesta por Domiciano, el Emperador es *Dominus Et Deus* (soberano y dios). Todos los funcionarios civiles y militares están subordinados a él. En suma, está presente la idea de que el Emperador es un enviado de dios para gobernar a los hombres. En la divinidad está el origen y la causa de sus poderes.

Como consecuencia del origen de esta particular estructura, toda norma tendrá que provenir del Emperador, por la vía de la Constitución Imperial.

En cuanto al régimen dentro del que debía funcionar la sucesión de los gobernantes, Diocleciano había dispuesto la tetarquía (los Césares sustituirían a los Augustos). En cambio Constantino unifica el poder y lo hace hereditario, nombrando Césares a sus hijos.

Las principales magistraturas (Tribunado, Cuestura, Pretura) se transformaron, en el Dominado, en simples recuerdos del pasado. Solamente el Consulado aún conservaba algo de su viejo prestigio. Había dos Cónsules: uno para Oriente y otro para Occidente.

Una modificación a la forma de distribución del poder puede encontrarse en el Bajo Imperio, cuando Teodosio, en el 395 d. C. divide a éste en dos sectores,

el Imperio Occidental para Arcadio y el de Oriente para Honorio, ambos hijos de Teodosio.

El Senado, aunque teóricamente debía aprobar las leyes, había quedado reducido a cumplir simples formalidades, que constituían parte del ornato que poseían los actos del Emperador.

Capítulo 6

FRANJA MORADA

SUMARIO:

- I. La jurisprudencia clásica.
- II. Las dos escuelas: Proculyanos y Sabinianos.
- III. Las constituciones imperiales.
- IV. La jurisprudencia en el dominado.



LAS FUENTES DE DERECHO EN EL IMPERIO

La Jurisprudencia Clásica

El período que se inicia con Augusto va a significar una época de valiosa labor para los juristas romanos.

La gran mayoría de los Emperadores que gobernaron durante el principado se rodearon de reconocidos jurisconsultos, lo que aportó para la ciencia del derecho una profunda transformación y una amplia difusión.

En esta etapa adquiere gran importancia la labor de los juristas orientada hacia la resolución de casos, ante consultas formuladas por los interesados.

Estos juristas, al igual que los pontífices en su momento, efectuaban su tarea a través del *Agere* (acompañando a las partes ante el magistrado) el *Cavere* (redacción e instrumentación de los actos jurídicos; v. gr: fórmulas, contratos, testamentos, etc.) y el *Respondere* (dar respuesta a las consultas que le sometían los particulares, los magistrados o los jueces antes o durante la tramitación del pleito).

El juez (*Iudex*) era, por lo general, una persona que poseía escasos conocimientos jurídicos, y por ello, en sus sentencias no podía apartarse de la opinión de los juristas. En ocasiones las partes aportaban al juez opiniones contradictorias sobre un mismo caso, lo que se pretendió solucionar cuando, en épocas de Augusto se concedió a ciertos juristas el *Ius Publice Respondendi*, el derecho de emitir opinión como si fuese en nombre del Emperador. Estos dictámenes tenían fuerza vinculante, como si se tratase de leyes, ya que obligaban al juez a fallar conforme a los mismos. Las respuestas debían estar selladas como medio para asegurar su autenticidad.

Lo que quería Augusto, al inaugurar la modalidad del *Ius Publice Respondendi* era la de disciplinar la jurisprudencia y evitar múltiples soluciones para un mismo caso. En suma asegurar la seriedad de la disciplina y posibilitar al juez sentencias que estuviesen de acuerdo con la opinión de distinguidos juristas. Sólo cuando los dictámenes investidos con el *Ius Publice Respondendi* eran contradictorios, el juez podía decidir por sí mismo optando por el que entendiera más justo.

No se conoce, a ciencia cierta, la nómina de los que gozaron de tal derecho. Solo se tiene certeza de que quien primero lo recibió fue MASURIO SABINO (de él tomará el nombre la célebre escuela de los Sabinianos).

Sin perjuicio de la existencia del *Ius Publice Respondendi*, en algunas ocasiones, la labor de afamados jurisconsultos debió ser también reconocida, a pesar de no poseer tal autoridad. Prueba de ello es lo que refiere Pomponio (D. 1, 2, 2, 49) cuando Adriano, en un rescripto, expresa que no era necesario que le requiriesen, tal beneficio, pues todos aquellos que tuviesen confianza en sí mismos podían dar respuestas a las consultas que se le presentasen.

En la época de los clásicos la producción literaria fue muy copiosa. La mayoría de las obras solo son conocidas hoy por meras referencias ya que no puede contarse con ellas. En gran cantidad aparecen mencionadas en el Digesto de Justiniano, que constituye una de las fuentes fundamentales, junto a las Institutas de Gayo, las Reglas de Ulpiano y las Sentencias de Paulo, para su conocimiento. En general, los juristas desarrollaron su tarea realizando comentarios al Derecho Civil, los Edictos del Pretor y sobre todo la casuística, que constituye el análisis del caso concreto.

Se cree que en esta época hubo muy escasa producción en lo relativo a monografías, trabajos teóricos o manuales dedicados a estudiantes.

Es tan importante la labor de los juristas que, PAPINIANO (D. 1, 1, 7) la señala como una de las fuentes del Derecho Civil, junto a las leyes, los plebiscitos, los senadoconsultos y los decretos de los príncipes.

De los clásicos merecen mencionarse Ateio CAPITON, Masurio SABINO, Javoleno PRISCO, Antistio LABEON, PROCULO, Salvio JULIANO, Sexto POMPONIO, GAYO, Ulpio MARCELO, Cervidio ESCEVOLA, Julio PAULO, Domicio ULPIANO, Emelio PAPINIANO y Herenio MODESTINO.

La casi totalidad de los juristas desempeñaron importantes cargos públicos, a excepción de Pomponio y Gayo, quienes simplemente eran maestros de derecho. Por eso se dice que, tal vez, ni Pomponio ni Gayo tuvieron nunca el *Ius Publice Respondendi*.

De POMPONIO se conocen sus Comentarios al Edicto, a Q. MUCIUM, a SABINO y un manual de derecho (*Enchiridium*). A GAYO se le atribuyen Comentarios al Edicto Provincial; al Edicto del Pretor Urbano, a la ley de las Doce Tablas y sus conocidas Institutas.

Gayo es muy claro y simple en sus textos. Su modo de exponer los temas, hace suponer su condición de maestro.

En cuanto a las Institutas, a pesar de ser conocidas con anterioridad a 1816, recién en esa fecha puede comenzar a determinarse con precisión un texto orgánico de las mismas.

En ese año el historiador NIEBUHR descubre, en la Biblioteca de Verona, un manuscrito conteniendo gran parte de las Institutas y que estaba cubierto bajo un texto religioso (Las epístolas de San Jerónimo).

Dicho hallazgo, junto a otros posteriores, como el *Papirus Oxyrhynchus* (Egip-

to = 1933) posibilitan hoy disponer de aproximadamente un 85 % de la obra.

La importancia de estas Institutas reside, en primer lugar, en su lenguaje accesible, didáctico, que permite llegar fácilmente al conocimiento de las principales instituciones jurídicas. Y además en que, seguramente, tal estructuración sirvió de base para que los juristas designados por Justiniano elaborasen las suyas.

La obra responde a un plan que abarca los más trascendentes tópicos del Derecho Civil. A través de cuatro libros GAYO expone los temas fundamentales de la disciplina: personas, cosas y acciones.

Las Dos Escuelas Proculeyanos y Sabinianos

Se sabe, con certeza, que los juristas de la época clásica comenzaron a agruparse en escuelas. Escuelas donde no se impartía enseñanza, pero si se emitían opiniones sobre ciertos aspectos de la realidad jurídica.

Se conoce incluso a la mayoría de los que integraban cada una de ellas. Pero lo que no ha sido posible es hallar algún rasgo característico o la posición filosófica sobre las que basaban sus diferencias, existiendo varias ideas al respecto.

Lo cierto es que hubo en Roma dos grandes escuelas jurídicas. Una de ellas, la de los Proculeyanos, que se inicia con Labeon. Luego se incorporarán PROCULO (que le dará su nombre a la Escuela) PEGASUS, JUVENCIO CELSO, CELSO y Neracio PRISCO.

La de los Sabinianos tiene su origen en Capiton, al que le seguirán Masurio SABINO, GAYO, Javoleno PRISCO y Salvio JULIANO.

Algunos piensan que puede caracterizarse a los Proculeyanos como dentro de una orientación más progresista, abrazada a una tendencia que tiene en cuenta pautas económicas y sociales, y a los sabinianos como inclinados hacia una actitud algo conservadora, tradicional.

Pero, en verdad, estos caracteres no se reflejan en las posturas que cada Escuela adopta. Lo que si puede aseverarse es la diferente posición política de cada grupo. Así CAPITON, inspirador de los sabinianos, se presenta como incondicional de Augusto. En cambio su rival —LABEON— es acérrimo opositor a la política del Príncipe.

De todas maneras será conveniente mostrar algunas de las principales cuestiones que suscitaron controversias entre las dos escuelas.

TEMA	SABINIANOS	PROCULEYANOS
1) Comienzo de la PUBERTAD.	Inspectio corporis (inspección corporal).	Edad (14 años en el varón y 12 en la mujer)*.
2) Concepto de COMPRAVENTA.	Cambio de una cosa por otra o por un precio en moneda.	Cambio de una cosa por moneda*.
3) Sobre el NACIMIENTO CON VIDA.	Cualquier signo vital*.	Sólo el llanto.

*Opinión que prevaleció.

Las Constituciones Imperiales

Los amplios poderes otorgados a Augusto y a los Emperadores que le sucedieron hicieron que, gradualmente, las facultades legislativas se fueran concentrando en el Príncipe.

Ya el Edicto de Salvio Juliano había modificado, en gran medida, el accionar de los Pretores.

Adriano había encomendado a Salvio Juliano la tarea de unificar las fuentes, reordenando los Edictos de los Pretores. Así aparece, aproximadamente en el 130 d.C., conociéndose como el Edicto Perpetuo, a pesar de que no sólo compilaba las disposiciones del Pretor Urbano, sino también las que corresponden al Pretor Peregrino, al Edil Curul y a los Edictos Provinciales.

Con esta obra se limitará significativamente la creatividad del Pretor, lo que va a contribuir a la gradual desaparición del Derecho Honorario.

La intención de Adriano, al encomendar la tarea, seguramente buscó poner orden y lograr uniformidad en las dispersas y cambiantes disposiciones de los magistrados, centralizando la política legislativa.

Todo cuanto disponía el Emperador tenía valor de ley y sus disposiciones son conocidas como Constituciones Imperiales (*leges*). Estas constituciones aparecen convalidadas por la *Lex Regia de Imperium*, que justifica el poder que el pueblo le ha conferido al príncipe (G: I - 5 y Ulpiano D. 1, 4, 1).

El Emperador creaba derecho a través de tres formas:

a) *Los Edictos*: que eran disposiciones de alcance general por las que el Emperador se dirigía al pueblo en uso del *Ius Edicendi*, tal como lo hacían los Pretores en sus Edictos, con la diferencia que los que provenían de la autoridad Imperial eran de duración ilimitada.

Estos Edictos comprendían los más variados temas de derecho penal, administrativo y procesal.

Así, uno de los más conocidos resulta el Edicto de Caracalla (constitución Antoniniana) por el que, en el 212 d.C. se otorga la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio.

b) *Los Rescriptos*: eran las respuestas escritas a las consultas que se le formulaban al Emperador, que tenían valor vinculante, tal como si se tratase de leyes, por haber emanado de quien se encontraba a la cabeza del Estado.

Es posible distinguir dos tipos de rescriptos: la Epístola, forma de respuesta que el Emperador enviaba a funcionarios, personalidades o Corporaciones relevantes; y la Suscriptio, como contestación a la consulta de los particulares, que el príncipe colocaba al pie de la nota recibida, y que no remitía al interesado sino que la hacía pública.

En los rescriptos, el Emperador emitía opinión acerca de cuestiones jurídicas dudosas. No se trataba de sentencias, ya que el que debía decidir era el juez.

También los rescriptos, en algunos casos, tendían a solucionar cuestiones personales o a otorgar ciertas concesiones a particulares o asociaciones. Tal como en el caso de la legitimación de hijos naturales.

c) *Los Decreta*: son verdaderas sentencias, que el Emperador emite en relación a las cuestiones sometidas al más alto Tribunal (Tribunal del Príncipe). En algunos casos el Emperador tomaba la jurisdicción sobre determinados asuntos y, en otros, revisaba las sentencias de otros Tribunales.

Si bien el pronunciamiento tenía alcance particular, cuando se resolvía sobre cuestiones que no tenían establecida una solución en las leyes, lo dispuesto para ese pleito se aplicaba para casos análogos.

d) *Los Mandata*: Algunos autores agregan a estas tres clases de constituciones de las que habló Gayo, una cuarta: los *mandata*. Estas no resultan fáciles de admitir como fuentes de derecho, ya que se trata de órdenes que el Príncipe enviaba a sus gobernadores, lo que las convierte, más bien, en disposiciones internas, restándole al particular la posibilidad de invocarlas.

e) *Los Privilegia*: Eran disposiciones especiales con efectos totalmente particulares, por las que se concede una recompensa o se aplica una pena, en ambos casos extraordinaria.

En el Dominado, junto a las ya mencionadas, aparecen dos nuevas formas de constituciones imperiales: la *adnotatio* y la *pragmática*.

La *Adnotatio*, que era similar a la epístola (*rescripto*). Se diferenciaba de ésta por ser un documento más solemne, y era emitido por un funcionario llamado *MAGISTER MEMORIAE*.

La *Pragmática* se emite en relación a una provincia o a una determinada asociación o comunidad, y tiene por objeto resolver problemas de cierta urgencia. Es de hacer notar que una pragmática, por tratar temas que solo interesaban a un grupo de personas, o a una sola región o comunidad, no podía contradecir lo que dispusieran las leyes generales.

Asimismo, al existir razones de urgencia, las pragmáticas eran dictadas directamente por el Emperador, sin consulta al *Consistorium*.

Durante el Dominado, y como consecuencia de una fuerte tendencia hacia la concentración del poder en el Emperador, la jurisprudencia solo se dedica a elaborar una doctrina oficial, que se limita a interpretar las opiniones de los juristas del pasado.

Se trata de una etapa decadente, donde la creación jurídica parece haberse detenido. Tanto Diocleciano como Constantino obstaculizaron permanentemente la labor de los juristas, por temor a que estos contradijesen la versión oficial.

Sin embargo, fue este un período en el que surgieron importantes escuelas de derecho, sobre todo en Oriente, como las de Berito y Constantinopla.

Esta pobreza jurisprudencial, para algunos autores, constituye el punto de partida de lo que se ha dado en llamar el derecho romano vulgar.

El vulgarismo, en contraposición al clasicismo del principado, se ha entendido como interpretaciones jurisprudenciales buidas, basadas en lo práctico y en lo popular, apartadas de los cánones clásicos.

Este proceso de vulgarización, que aumenta el estancamiento de la cultura jurídica, se hace más evidente en Occidente y aparece bastante atenuado en Oriente.

Ello por la decisiva influencia de las ya nombradas escuelas de Berito y Constantinopla, que siguen las líneas rectoras de los clásicos.

Capítulo 7

SUMARIO:

- I. Ley de las citas. ✓
- II. Compilaciones Pre-justinianas.
- III. Otras recopilaciones.
- IV. Las leyes romano-barbaras. ✓
- V. La compilación justiniana. ✓



LA CODIFICACION

Al llegar al dominado se ha producido una decadencia de la jurisprudencia. Aquella amplitud de fuentes productoras de derecho del Principado, ha trocado en la aparición de las denominados Leges, es decir constituciones imperiales. Estas resultan la única creación organizada de derecho. A su lado se mantienen las otras fuentes de períodos anteriores, que no han sido derogadas. Es decir que en esta época, la legislación imperial y la literatura jurídica clásica, en gran multitud, son la base del derecho en vigencia.

Los juristas de este tiempo conocen generalmente esas normas de manera indirecta, especialmente por las obras de los juristas clásicos. Es de recordar además que, no obstante la división del imperio, se mantiene la unidad formal de la legislación para ambas partes del mismo; promulgándose, como ya se viera, las disposiciones de igual modo para Oriente que para Occidente.

Esta dualidad legislativa, junto a la multitud de obras de los juristas antiguos utilizadas, —de difícil penetración técnica, muchas veces contradictorias, pertenecientes a períodos históricos distintos, usadas a menudo, tanto en la enseñanza como ante los jueces, de manera capciosa y aún falsa— ponía en riesgo serio a la actividad jurisdiccional por la inseguridad resultante. Muchas veces, solo el azar permitía encontrar la normativa adecuada a un pleito, siendo difícil demostrar la autenticidad de las citas y constituciones, amén de alegaciones contrarias a los jurisconsultos.

Dicha situación exige remedios aptos para superar tal estado de cosas. Aparecen constituciones por las que los Emperadores buscan restringir la utilización de los IURA. Así una constitución imperial de Constantino reglamenta la eficacia de los escritos del período clásico ante los tribunales. Tal la dada en el año 312 (mencionada en el Código Teodosiano) que prohibía la cita de notas que Paulo y Ulpiano habían hecho a la obra de Papiniano, con el objeto de evitar las discusiones que permanentemente ellas provocaban. Por otra del año 328 confirmó la validez de los restantes escritos de Paulo, especialmente sus "Sentencias" (*Pauli Sententiarum Filium Lib. V*).

Con aparentemente la misma intención de ordenar los Iuras, Teodosio II y Valentiniano III van a dictar una disposición que modernamente se ha denominado Ley de las Citas, o Ley de citas (año 426) nombre que ha merecido críticas de diversos autores.

Por ella se asignaba valor legal a la opinión de cinco juristas: *Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gayo y Modestino*. Todos ellos desaparecidos al dictarse la ley, lo que le valiera despectivamente ser tenida como un Tribunal de muertos.

Establecía esta ley que solo se podría invocar en juicio —y siempre que así expresamente lo hicieran las partes— las opiniones de tales jurisconsultos y las de aquellos por ellos citados, a condición de poder confrontarse los originales.

Si hubiera divergencia en sus opiniones debía prevalecer la de la mayoría. A igualdad de pareceres, preponderaba la opinión de Papiniano; desconociéndose la de éste, el juez quedaba en libertad de decisión.

Algunos autores sostienen que el fin perseguido por los consejeros de Teodosio no se limitaba a normalizar las citas y establecer el Tribunal de los Muertos, sino que pretendían ordenar una compilación de *Iura*, dando fuerza a la opinión de aquellos jurisconsultos clásicos más en boga.

Resulta evidente, no obstante, que no podía ser ésta una solución total del problema.

Compilaciones Pre-Justinianas

El irresuelto problema planteado, con las señaladas dificultades, y el sucederse de numerosas constituciones imperiales sin poderse determinar a ciencia cierta cuales estaban en vigor provocó la necesidad de ordenar y clarificar cuales eran las normas aplicables en cada caso. Consecuencia de ello son los intentos compiladores. Debe resaltarse la importancia de estas compilaciones, que sin llegar a un grado de perfección, han devenido importantes como antecedente para la labor posterior. Indudablemente mucho debe a ellas la obra de Justiniano; seguramente inconcretable —por lo menos en el tiempo que demandara su realización— sin esta tarea previa.

Resalta, también, la significación que poseen para ilustrar a investigadores y estudiosos, que encuentran, en sus parciales y dispersas partes, una fuente imprescindible para el conocimiento y análisis de las instituciones y su evolución.

Suele clasificárselas en dos grupos: aquellas que solamente contienen *Leges* y las integradas por *Leges* y *Iura*.

Los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano pertenecen al primer grupo, es decir que son colecciones de constituciones exclusivamente. Los dos primeros —códigos Gregoriano y Hermogeniano— fueron efectuados por particulares.

El código Gregoriano reconoce precedentes limitados de la época clásica. Ejemplo de ello es una obra de Papirio Justo, de tiempos de Marco Aurelio. Fue hecho en Oriente en el reinado de Dioclesiano, llamándose posiblemente su autor Gregorio o Gregoriano.

Por lo que sabemos sistematizaba el derecho privado. Comprendía rescriptos, siendo el más antiguo conocido uno de tiempos de Septimio Severo (año 196). Se lo tiene por fuente principalísima del Código de Justiniano, en especial para las *Leges* más antiguas en él contenidas. Por esto se cree que el Código Gregoriano contenía *LEGES* que se retrotraían a Adriano.

Debió estar dividido, como mínimo, en quince libros, y dentro de ellos en títulos, en los que se ordenaban cronológicamente las constituciones.

El Código Hermogeniano

El Código Hermogeniano es obra atribuida a Hermogeniano, para algunos posiblemente el jurista autor de un *Epitome Iuris*. Contiene, en un solo libro, rescriptos dados por Dioclesiano y ordenados bajo iguales rúbricas que el Gregoriano.

Puede considerárselo una suerte de complemento del anterior. Otros juristas le adicionaron las constituciones de los últimos tiempos de Dioclesiano, y de otros emperadores, como Constantino, Licinio, Valentiniano y Valente.

Ni el Código Gregoriano ni el Hermogeniano han llegado hasta nosotros, pero varias de las constituciones allí contenidas aparecen referidas en otras obras con indicación de provenir de ellos.

El Código Teodosiano

El Código Teodosiano fue mandado a hacer por el Emperador Teodosio II, luego de fracasar un intento más ambicioso. Originariamente había designado una comisión de 9 miembros, que sobre la base de los Códigos Gregoriano y Hermogeniano, adicionando las constituciones edictales o generales postconstantinianas y las obras de diferentes juristas, tenía que elaborar un auténtico código general y práctico de todo el derecho vigente, destinado tanto a la enseñanza como a la ciencia jurídica. El plan consistía, como han señalado los estudiosos, en refundir las *LEGES* coleccionadas, con la compilación de *IURA* resultante de la aplicación de la ley de Citas. La obra seguiría los criterios de los Códigos Gregoriano y Hermogeniano, sin suprimir constituciones, aún las repetidas o anticuadas. La supervivencia y vigencia de ellas o su mero interés histórico resultaba de su ubicación cronológica.

Al fracasar este intento, luego de seis años (en el 435) el Emperador nombró una comisión nueva, de dieciseis miembros, con miras más limitadas. Debía redactarse un código práctico que tuviera en cuenta las *Leges* generales del período que va de Constantino al propio Teodosio, excluyendo la compilación de *IURA*.

RA. A esta comisión se le dio facultad para modificar e interpolar los textos, al menos, en cuanto a su redacción, pudiendo reacomodarlos para evitar contradicciones.

Las constituciones se agruparon en 16 libros, divididas en títulos y dentro de ellos ordenadas cronológicamente. Se debe destacar, en lo que hace a su contenido que se concedía en ellas importancia preponderante al derecho público sobre el privado; solamente cuatro de los libros se dedicaban a este último.

Teodosio II reconocía, además, validez a las constituciones contenidas en los Códigos Gregoriano y Hermogeniano que resultaban así indirectamente ratificados; y a la parte del derecho antiguo contenida en la jurisprudencia que no se opusiera a las constituciones. Son numerosos los manuscritos, aunque parciales, que se conservan de esta obra.

El Código Teodosiano fue aceptado en Occidente por Valentiniano III. Aunque efectuada en Oriente, esta compilación supervivió por más tiempo en Occidente. Incluso en Italia no cedió hasta la época de los glosadores al Código de Justiniano.

Fuera de Italia perduró a través de la *lex Romana Visigothorum*, en la que aparecen extractadas trescientas ochenta y seis constituciones del Código Teodosiano, sirviendo a posteriores legisladores y autores jurídicos.

Otras Recopilaciones

En cuanto a las recopilaciones de *Leges y Iura*, algunas particulares y otras oficiales, pueden mencionarse entre las primeras:

1. *El Libro de Derecho Siriorromano*, escrito en lengua siria, sobre un original griego, tuvo vigencia durante varios siglos de Armenia a Egipto. Se discute si se trataba de una obra didáctica o si también poseía fines prácticos. Del mismo, existen versiones árabe y aramea.

2. *Los Fragmenta Vaticana*: se conoce con este nombre a un manuscrito del siglo V, descubierto en la Biblioteca del Vaticano, en 1821, por el cardenal Angelo Mai. Comprende una vasta compilación de *LEGES* y *IURA*, con fragmentos de obras de Papiniano, Paulo y Ulpiano.

3. *La Lex Dei Sive Mosaicorum et Romanorum Legum Collatio*: comparación de las leyes romanas y mosaicas, de autor desconocido, posiblemente un romano-judío, ya que la falta de citas del Nuevo Testamento descartaría a un judeo-cristiano. Contiene una comparación del derecho romano con las leyes mosaicas, intentando demostrar que el primero derivaba de las segundas. Los textos romanos son breves y de carácter general, tomados de constituciones imperiales y obras más elementales de Papiniano, Gayo, Paulo, Ulpiano y Modestino.

4. *La Consultatio Veteris Cuiusdam Iurisconsulti* (repertorio de consultas dadas por un antiguo jurisconsulto). De autor desconocido, fue publicada por

el eximio romanista Cujas en 1577, sobre la base un manuscrito hoy desaparecido. Las respuestas a las cuestiones que le son sometidas son dadas apoyándose en los códigos Gregoriano, Teodosiano y Hermogeniano y en las *Sententiae* de Paulo.

Las Leyes Romano-Barbaras

Después de la caída del Imperio Romano de Occidente se va a plantear, como consecuencia del sistema de la personalidad de las leyes, la necesidad de clarificar el marco jurídico a aplicar a los ciudadanos de origen romano. El señalado principio será respetado por los bárbaros, permitiendo que los de nacionalidad romana siguiesen viviendo con arreglo al derecho romano, siempre que hicieran una declaración en tal sentido (*Professio*). Mientras, los conquistadores, seguían sus propias costumbres.

Edicto de Teodorico

Teodorico, rey Ostrogodo, se considera regidor de Italia por haberlo investido el Emperador Zenón y en consecuencia no impone en sus dominios el principio de la personalidad del derecho. Así va a dictar, alrededor del año 500, el edicto que se conoce con su nombre (*Edictum Theodorici Regis*) que hacía un resumen de importantes disposiciones de derecho romano para que fueran observadas tanto por los romanos como por los ostrogodos. Para aquello que él no hubiera reglamentado, cada pueblo aplicaba su ley (romana u ostrogoda).

Este Edicto de Teodorico está formado por 154 artículos tomados de los tres códigos, de las Novelas post-teodosianas y las Sentencias de Paulo.

La Lex Romana Visigothorum

La Ley Romana de los Visigodos o *Breviarum Alaricum* (breviario de Alarico) es una compilación oficial del año 506 dispuesta por el rey Alarico II, realizada por juristas romanos y aprobada por una reunión de obispos y notables.

Destinada a aplicarse a los súbditos romanos de España y Aquitania (parte occidental de Francia) tiene fuentes orientales y occidentales de textos escritos poco antes de tal compilación y otros muy antiguos, modernizados no del todo eficazmente.

Comprende extensos extractos del Código Teodosiano y de Novelas post-teodosianas; el epitome de las Instituciones de Gayo, una parte importante de las Sentencias de Paulo; constituciones sacadas de los Códigos Gregoriano y Hermogeniano y un trozo de las respuestas de Papiniano. Además contiene una *INTERPRETATIO* que acompaña los diversos textos.

Lex Romana Burgundionum

La ley Romana de los Borgoñones, también llamada por error de un copista PAPIANUS, fue promulgada en los primeros años del siglo VI, posiblemente en el 516 por Gundobado o Gondelbaldo, rey bárbaro de los burgundos o borgoñones, cuyo reino ocupaba gran parte de Francia Oriental.

Estaba destinada exclusivamente a los habitantes romanos.

Dividida en cuarenta y seis títulos, reproduce de manera incorrecta las fuentes entonces en boga, intercalando principios del derecho borgoñon (tal vez deliberadamente).

Lex Romana Utiensis

La *lex Romana Utiensis* o *Rhetica Curiensis*, de origen privado, efectuada de manera similar a la *lex Romana Visigothorum*, posiblemente en el siglo VIII o IX en Italia, que se aplicó en la provincia danubiana de Rhetia.

La Compilación Justiniana

"la majestad imperial conviene que no solo esté honrada con las armas sino también fortalecida por las leyes, para que en uno y otro tiempo, así el de guerras como el de paz, puedan ser bien gobernados, y el príncipe romano subsista vencedor no solamente en los combates con los enemigos, sino también rechazando por legítimos trámites las iniquidades de los calumniadores y llegue a ser tan religiosísimo observador del derecho, como triunfador de los enemigos vencidos. . . Y así después de los cincuenta libros del Digesto o de las Pandectas en que se recopiló todo el derecho antiguo y los cuales hicimos valiendonos del mismo Triboniano, varón excelso y de otros ilustres y elocuentísimos varones, mandamos que las mismas Instituciones se dividiesen en estos cuatro libros, para que constituyan los primeros elementos de toda la ciencia del derecho. . ." (Instituta de Justiniano; Proemio; "IMPERATORIAM MAIESTATEM". Cuerpo del Derecho Civil Romano; García del Corral; Tomo I, pág. 5 y sgts.).

Ha señalado Salvatore Riccobono que la codificación de Justiniano marca el punto medio en la vida del derecho romano.

Esta obra monumental fue realizada al inicio del reinado del Emperador, en Constantinopla (años 528 a 534) en lengua predominantemente latina y concluye la evolución jurídica del imperio romano.

Será sobre ella que se efectuarán los renacidos estudios romanísticos, a partir del siglo XI fundará la recepción del derecho romano en los países greco-latinos

Sin duda Justiniano, emperador de origen ilírico, asumió la idea de restaurar la antigua grandeza del Imperio, tanto en lo militar —especialmente por las campañas de sus generales Belisario y Narcés— como a través de la legislación.

En el plano jurídico concretará la reiterada aspiración de tantos intentos previos: reunir el derecho vigente en un cuerpo legal, esto es recoger las *Leges* y los *Iura*.

Colaborarán a la prosecución de tal emprendimiento las escuelas de Berito y Constantinopla, a través de juristas integrantes de ellas.

Código

Por la constitución *Haec Quae Necessario*, del 13 de febrero del 528, el Emperador nombra una comisión —presidida por el ex questor sacri palatii Juan e integrada por juristas como Triboniano (en esa época funcionario de menor jerarquía) y el profesor de la Escuela de Constantinopla, Teófilo— a la que le encarga realizar un código, utilizando los anteriores (Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano) como así también constituciones posteriores.

Tenían la facultad de modificar las constituciones reuniendo varias en una, o dividiéndolas conforme las materias, según que hubieren sido derogadas, o no respondieran a las necesidades actuales.

La tarea fue efectuada con celeridad publicándose el Código el 9 de abril del año 529 (constitución *Summa Reipublicae*) y entrando en vigencia siete días después.

No obstante, cuatro años más tarde fue modernizado, por haber quedado anticuada la primera recopilación de las LEGES.

El primitivo Código no nos es conocido, pero a juzgar por un índice de constituciones encontrado en un papiro (de *Oxyrinch*) debió tener una estructura diferente.

El código del 529 es conocido como *Codex Verus*. El nuevo código (*Codex Novis* o *Codex Iustinianus Repetitae Praelectionis*) tuvo en cuenta una serie de nuevas constituciones a las que se llamó QUINQUAGINTA DECISIONES (por ser 50 decisiones que sirvieron para dirimir controversias entre los juristas clásicos, especialmente entre sabinianos y proculeyanos) y fue efectuado por la comisión integrada por cuatro juristas (Triboniano, Doroteo y los abogados Constantino Menna y Juan).

El código está dividido en 12 libros, los que a su vez, se subdividen en títulos (normalmente cortos y multifacéticos). Algunas constituciones están redactadas en griego. La más antigua es del Emperador Adriano.

El primer libro trata de derecho eclesiástico y público en general; del segundo al octavo de derecho privado; el noveno de derecho penal y procedimiento correspondiente; los últimos de derecho administrativo.

Exceptuando las constituciones referidas al derecho público el Emperador había dispuesto que se siguiera el orden del Edicto Perpetuo. Las constituciones conservaban el nombre del emperador (inscripción) la fecha, nombre de los cónsules y lugar de emisión (suscripción); además debían ser colocadas cronológicamente.

Si bien la compilación contemplaba expresamente a las leyes generales, alcanzaba también a los rescriptos, los cuales adquirirían así vigencia general.

Ya al sancionarse el código del año 529, se dispuso la prohibición de recurrir a códigos y novelas anteriores. Así en la constitución *Codice confirmando*, Justiniano dispone:

"Prohibimos a los que pleitean y a los abogados bajo pena de hacerse culpables de falsedad, el que citen otras constituciones que las insertas en nuestro código, y que las citen de otra manera que en la que en él se encuentran; la invocación de esas constituciones, añadiendo a ellas las obras de los antiguos interpretes del derecho, deben bastar para resolver todos los pleitos, aunque carezcan de fecha, o no hayan sido en otro tiempo mas que rescriptos particulares".

Digesto o Pandectas

De las diferentes partes que componen el *Corpus Iuris Civilis*, el Digesto resultaría la única sin precedentes. Así lo señala el propio Justiniano para quien la Instituta reconoce dependencia con la de Gayo, en tanto el *Codex* tiene directa conexión con el realizado por Teodosio y los anteriores a éste; las Novelas siguen la manera de las post-teodosianas.

Además de tal dificultad, resulta palmariamente más difícil compilar el derecho contenido en los *Iura*, conservado a través de las obras de los juristas.

Intentos de ordenar los *Iura* ya habían resultado infructuosos. La ley de citas fue seguida por la sugerencia de Triboniano, que aconsejó a Justiniano a tomar partido en los casos de contradicción de opiniones entre los jurisprudentes. Entre los años 529 y 530 se dictarán las llamadas 50 decisiones (*Quinquaginta Decisiones*), encaminadas a dirimir viejas controversias despejando la inseguridad e incertidumbre para jueces y litigantes.

Si bien no es conocida en su conjunto es probable que esta obra estuviese reunida en una colección, que las posteriores publicaciones del Digesto, Institutas y el *CODEX NOVIS* dejaran de lado.

Una vez publicado el primer código, a través de una serie de constituciones, el Emperador ordenó el Digesto. El 15 de diciembre del 530, por la constitución *Deo Auctore* se autoriza al tuestor de palacio Triboniano para que organice una comisión que él presidiría y debía integrar con 16 miembros más.

Se convocó a 4 profesores de las escuelas de Berito y Constantinopla (Anatolio, Doroteo, Teofilo y Cratino). Además integraron el cuerpo el funcionario de Estado Constantino y 11 abogados del Foro de Constantinopla.

Esta comisión procuró cumplir el mandato del Emperador quien en la mencionada constitución dispuso que redactara un cuerpo legal que contuviera la obra de los jurisprudentes (*Iura*). Surgirá así el *Digesto* o *Pandectas*. *Digesto*, palabra latina, tiene el significado de lo que se haya ubicado metodicamente y *Pandectas*, de etimología griega, significa lo que comprende todo. Esta denominación había sido dada por los jurisprudentes a obras extensas y fue adoptada por Justiniano para la colección que refundía o coordinaba la jurisprudencia antigua.

La obra monumental fue terminada rapidamente y entró en vigencia mediante la constitución *Tanta* el 30 de diciembre del 533.

Los dos tercios de los fragmentos contenidos en el Digesto, pertenecen a los juristas de la ley de citas (Gayo, Ulpiano, Paulo, Papiniano y Modestino). De estos, la mayor parte pertenecen a Paulo. De otros siete juristas emanan casi una cuarta parte de los *IURA* (Cervidio Scaevola, Juliano, Marciano, Pomponio, Jaboleno, Africano y Marcelo). El resto de la obra se reparte en opiniones de otros veintisiete juristas (entre ellos Celso, Florentino, Labeón, Neracio, Próculo, Sabino).

La obra se integra con 50 libros; cada libro está dividido en títulos, salvo los libros 30, 31 y 32, que carecen de ellos; cada título comprende varios fragmentos; fragmentos que, a su vez, suelen dividirse en párrafos.

Fragmento (también por algunos llamados leyes) son extractos de los diferentes autores cuyo nombre y libro al que pertenecen se cita al comienzo de cada uno de ellos. (*Inscriptio*).

Parágrafo es la forma de dividir los fragmentos extensos, que proviene de la edad media. Así el primer parágrafo de cada fragmento se llama *Principium* y no tiene número; de allí que el parágrafo numerado como uno es en realidad el segundo de cada fragmento.

Así para citar un *IURA* del Digesto, por ejemplo el parágrafo ubicado en tercer término en el fragmento 11 del título 2 del libro tercero de las *Pandectas*, se citaría de la siguiente manera: D.: 3, 2, 11, 2. Si se tratase del parágrafo inicial, la notación sería: D. 3, 2, 11, pr.

La trascendencia del Digesto sobresale, indudablemente, aún con relación a las restantes partes del *CORPUS IURIS*. Es en esta compilación donde con mayor nitidez se nos muestra el espíritu de los juristas romanos, a través de la resolución práctica de las cuestiones jurídicas que les eran sometidas. No es extraño entonces que sobre esta obra hayan fijado preponderantemente su atención los estudiosos del derecho romano, ya desde la escuela de los glosadores. Es que a pesar de las modificaciones y alteraciones que sufrieron los textos originales, los párrafos de esta obra reflejan en gran medida la opinión de los juristas más notables de las diferentes etapas de la evolución del derecho en Roma.

El Problema del Método de Trabajo seguido en el Digesto

La enorme cantidad de material que debieron considerar los compiladores del Digesto, para la realización de la obra nos plantea, ante la rapidez con que fue concluido el trabajo, el problema de desentrañar cual fue el método empleado a tal fin. De lo improbable de la tarea, el propio Justiniano refiere en la constitución *Tanta*:

"Mas al proceder al examen de todo el material nos comunicó la mencionada excelencia (Triboniano) que los antiguos habían escrito casi dos mil libros, que abarcaban más de tres millones de líneas que era necesario leer y atentamente indagar por entero, para elegir lo mejor de todos ellos. . .".

El plazo previsto originariamente para la conclusión del Digesto era de diez años. Sin embargo, fue concluido en tres años a partir de la orden del Emperador.

Aun cuando el número de dos mil libros, señalado por Justiniano, pudiere resultar exagerado, indudablemente, la cantidad de obras y autores tenidos en cuenta resulta muy elevada para el escaso tiempo en que se concluyera la tarea.

Diferentes hipótesis han tratado de resolver el enigma.

En 1818, Federico Bluhme enuncia una teoría acerca del método que debieron seguir los compiladores. Antonio Agustín (1517-1586) ya había señalado que las obras de los jurisconsultos aparecían extractadas siguiendo un orden bastante regular.

Bluhme, advirtió que las obras consultadas podían distribuirse en cuatro grupos o masas, de cada una de las cuales se habría ocupado una subcomisión. A los grupos o masas se las denominó: sabiniana, edictal, papiniana y apéndice. Los títulos serían la suma del trabajo de cada grupo, si bien no siempre todas las masas estaban representadas en la totalidad de los títulos, y aún frecuentemente aparecen interferencias entre las mismas masas.

La masa sabiniana estaba compuesta por las obras de los autores clásicos tardíos, comentando el *Ius Civile*, los *Libri Ad Sabinum*, de Ulpiano y Paulo.

A la masa edictal la forman los comentarios al Edicto efectuados por los juristas clásicos. Las cuestiones y respuestas de Papiniano, Ulpiano y Paulo forman el tercer cuerpo denominado masa papiniana, por cuanto lo extractado de Papiniano normalmente se hallan al inicio.

Otros fragmentos tomados de escritos de diversos juristas y de variada índole forman un grupo reducido que conforma el apéndice. Para Bluhme la comisión del Digesto se subdividió en tres, cada una de estas subcomisiones se ocupó de uno de los tres grupos fundamentales, en tanto el apéndice procedería de una extractación posterior.

La idea que sostenía, siguiendo al propio Justiniano, que sólo las Pandectas eran obra exclusiva de la creatividad de sus autores, será controvertida al introducirse la tesis de la existencia de un modelo que habría servido de base al Digesto, denominada *pre-Digesto*.

Tal hipótesis fue introducida primeramente por Hoffmann (1900), seguida luego por Ehrenzweig (1901) y más tarde por Hans Peters (1913).

Hoffmann sostenía que los juristas de Justiniano no consultaron sino los comentarios *Ad Edictum* y *Ad Sabinum*, no habiendo recurrido a la obra directa de los textos que citan en el Digesto.

Ehrenzweig afirmaba que el Digesto, en realidad, es una obra del siglo V que fue tomada por Justiniano, quien la hizo propia previas modificaciones.

Peters, con una tesis con mayor documentación, habla de una compilación en cadena iniciada ya en el siglo V siendo el aporte justiniano exclusivamente el del apéndice. Esta última postura logró aceptación de importantes romanistas.

Peters al argumento de la ya señalada exiguidad de tiempo añade la existencia de unos fragmentos de un comentario al Digesto, recogido en las Basílicas, atribuido a los miembros de la comisión redactora. Junto a ellos otros fragmentos de autores de los siglos X a XII con comentarios no ya al Digesto sino a las Basílicas. Algunos de dichos fragmentos pertenecerían a una compilación anterior a la redacción del Digesto y similar a éste.

Otro argumento es el que se refiere a las *Partes Legum*, obras jurisprudenciales anteriores a las Pandectas, usadas en las escuelas de derecho. Justiniano al aparecer el Digesto dispuso reemplazar dichas *Partes Legum* por aquel; tal como ocurriera con las Institutas de Gayo, sustituidas por las del Emperador y las Constituciones imperiales por el *Codex*. Las *Partes Legum*, escritos anónimos debieron ser compilaciones de jurisprudencia clásica, como parte de un predigesto que habría utilizado Justiniano íntegramente para la redacción de las Pandectas.

En resumen, y como expresara Alvaro D' Ors resulta difícil arribar a una conclusión definitiva acerca de la existencia o no del predigesto. Puede pensarse que en las diversas partes de las Pandectas hay indicios de la existencia de bases fundamentales compiladas con anterioridad y que el Emperador adoptó compiló y completó con sus interpolaciones y otros aportes.

Institutas

Al mandar Justiniano, con la constitución *Deo Auctore* la compilación de los *Iura*, había manifestado su intención de realizar un tratado elemental de derecho destinado a la enseñanza.

Esta obra debía allanar las dificultades que por el volumen y complejidad del Digesto impedían el estudio de las instituciones jurídicas, directamente de las Pandectas.

Con este objetivo, el Emperador encomienda a Triboniano, Teofilo y Doroteo la realización de una obra, que había de sustituir a las utilizadas por entonces, especialmente a las Institutas de Gayo.

Antes de concluirse el Digesto, la comisión dio término a la tarea, que fue publicada el 21 de noviembre del 529, mediante la constitución *Imperatoriam Maiestatem*, donde explícitamente Justiniano dispone que la Instituta está dirigida a la juventud ávida de estudiar las leyes y debe reemplazar a otras obras similares que en esa época se utilizaban.

Por la constitución *Tanta*, junto al Digesto, se estableció la vigencia de las Institutas, a partir del 30 de diciembre del mismo año 529.

Para su redacción, los juristas se basaron en obras elementales de la literatura jurídica clásica y postclásica, entre ellas, de modo preponderante, las Institutas de Gayo, así como las de Marciano, Ulpiano y Florentino. Además recurrieron a la obra de Gayo, conocida como *Res Cotidianae*, especie de paráfrasis de tal autor. También con relación a las modificaciones justinianas se utilizó como fuente al Código publicado en el 529 y partes del Digesto, ya próximo a ser publicado.

Además del destino señalado como instrumento para la enseñanza del derecho, la obra tuvo verdadera fuerza legal, ya que el Emperador le dio tal carácter por la

constitución *Tanta*. Así su contenido resulta real fuente de derecho, y obligatoria para los ciudadanos romanos.

El plan de la obra sigue, en general, el esquema de Gayo. Están divididas en 4 libros, abordando los elementos esenciales del arte jurídico: las personas, las cosas y las acciones.

Se distingue la Instituta justiniana de la de Gayo en que estando ambas divididas en cuatro libros, las primeras los subdividen en títulos, de los que carecen las segundas.

Los fragmentos, al contrario que en el Digesto, y el Código, no indican su origen; dando la redacción en primera persona la sensación de que es el propio Emperador quien habla.

El libro I está dedicado a las personas, con algunas nociones generales sobre la justicia y el derecho.

En el segundo se tratan las cosas y lo relativo a su adquisición, herencias testamentarias, legados y fideicomisos.

El tercero se refiere a las herencias ab-intestato y las obligaciones que nacen de los contratos y de los cuasicontratos.

En el cuarto se incluyen las acciones y las obligaciones que surgen de los delitos, los cuasidelitos, el proceso civil, el oficio de juez y los juicios públicos.

Novelas

En la Edad Media se comenzó a incluir, como integrando el Corpus Iuris Civilis a un cuerpo legislativo comprensivo de una serie de constituciones dictadas con posterioridad a los Códigos (*Vetus y Novis*) las *Quinquaginta Decisiones*, el Digesto y las Institutas.

La obra legislativa de Justiniano, a partir del 534 hasta su muerte (565) no se vio interrumpida, habiéndose dictado numerosas constituciones, la mayoría de ellas en griego y solo por excepción en latín. Abarcaban diferentes materias, siendo escasas las referidas a derecho privado.

El dictado de estas *Leges* contradecía en los hechos al propio Justiniano, que al poner en vigencia el nuevo código (constitución *Cordi Novis*) ordenó que el mismo no fuera modificado por las disposiciones dictadas con posterioridad.

En vida del Emperador, no hubo recopilación oficial limitándose el Cuestor de Palacio a registrarlas para ser publicadas periódicamente.

Con carácter privado, algunos autores se dieron a compilarlas dándose a tales repertorios el nombre de Novelas o *Novellae Leges* (nuevas leyes).

Alrededor del año 555, aparece una colección conocida como Epítome Iuliani, por ser atribuida a Juliano, profesor de derecho de Constantinopla y dar a conocer las constituciones bajo la forma de resúmenes en latín. Se contabilizan, en esta colección, 124 constituciones, aunque en realidad, se reducen a 122 por la repetición de dos de ellas.

Al comienzo se respeta un orden aproximado por materias; pero a partir de la constitución 40 se adopta un orden cronológico.

El Epítome incluye las constituciones dictadas entre los años 535 y 555. Se ha considerado, en atención a su lengua latina, que tenían por destino al occidente reconquistado del imperio.

Una segunda colección que incluye 134 constituciones dictadas hasta el año 556, en idioma latino, es conocida como las Auténticas. Las constituciones reproducen a las latinas en su idioma original y las griegas, mediante una defectuosa traducción literal.

Su autor es desconocido creyéndose que debió serlo un jurista contemporáneo de Justiniano o de época escasamente posterior. Su redacción pudo ser durante la vida del Emperador, aunque se afirma también como posible que se realizaran en el siglo XI.

En los inicios de la escuela de Bolonia la colección fue tenida por falsa por el famoso profesor Irnerius quien posteriormente se retractó afirmando su autenticidad. De allí que a la misma se le adjudicara el nombre de *Liber Authenticorum* o *Authenticum* (auténticas).

Otra colección, a la que se conoce como Colección Griega, concentra en su idioma original Novelas tanto griegas como latinas. Habría sido realizada en el 578 y la integran 158 novelas de Justiniano y otras de Emperadores posteriores, como Justino II y Tiberio II.

Esta dualidad de lenguas, que hace que algunas Novelas se hayan redactado en latín, otras en griego, y a veces en ambos idiomas obedece —como dijera el mismo Justiniano— a que aquellas escritas en griego lo eran en utilidad de la multitud, en tanto las redactadas en latín lo eran en razón de que en esa lengua estaba la representación de la República.

Esta colección, fue conocida en Occidente por la llegada de juristas bizantinos y manuscritos griegos, una vez caído el Imperio Oriental. Los originales de esta colección reproducían las Novelas en lengua griega, ya que las latinas o habían sido suprimidas o se las había extractado en griego. Esto por resultar el latín poco conocido en Bizancio. Cuando estaba completa llegó a contar con 168 constituciones. Incluso algunas de ellas no serían tales por tratarse de decretos del prefecto del pretorio. El origen de la colección fue Constantinopla, y por su contenido debió finalizarse en época de Tiberio II, quien fue Emperador entre los 578 y 582.

Además de las nombradas, existe una colección de canones extraídos de las Sagradas Escrituras, de la Patrística, de los Concilios y Sínodos, realizada por Juan de Antioquía, (El Escolástico, patriarca de Constantinopla) quien luego de la muerte de Justiniano y antes del 578, se ocupó de correlacionar su obra con disposiciones de las Novelas de Justiniano, agregando a los Canones resúmenes de dichas constituciones.

Finalmente cabe destacar que en algunos manuscritos de la Colección Griega, aparecen un grupo de 13 Novelas de Justiniano incorporadas como apéndice. A dicha parte se la conoce como *Edicta Justiniani*.

"Tanta ha sido nuestra reverencia por lo antiguo, que no hemos consentido en modo alguno que los nombres de los prudentes cayeran en olvido, sino que aparecen en las inscripciones de nuestro Digesto el nombre de todos los que son autores de sus leyes, habiendo hecho nosotros tan solo que se añada o quite según sea necesario, y se ajuste a las reglas más justas todo lo que en las leyes de aquellos prudentes parezca superfluo, imperfecto o menos conveniente. . . así, respetando los nombres y los autores antiguos, hemos mantenido en nuestras enmiendas todo lo que era conveniente y necesario para la verdad de las leyes". (Const. Tanta, 10).

El conjunto de disposiciones contenidas en las numerosas constituciones imperiales, la multitud de opiniones de notables juristas y obras que componían la masa sobre la cual debían trabajar los compiladores, presentaba múltiples dificultades a la hora de compatibilizarlas y elegir aquellas que por adecuadas a la realidad debían incorporarse al cuerpo legislativo.

Para superar estas inconveniencias Justiniano había autorizado a los juristas a modificar, suprimir o adaptar los textos clásicos.

Tales alteraciones son conocidas con la denominación de Interpolaciones o *Emblema Triboniani*, que fueran motivo de arduas discusiones entre los romanistas, especialmente entre aquellos pertenecientes a la escuela culta del siglo XVI (humanistas), la escuela histórica del siglo XVIII y durante el presente siglo.

La actividad de quienes se dedicaron con énfasis al estudio y dilucidación del problema de la autenticidad de los textos o su posible interpolación, llegó a extremos de tal intensidad que merecieron que Riccobono hablara de "caza de interpolaciones". Es que el exceso llegó al punto de sostenerse que en toda la obra de Justiniano no habría un texto puro de los juristas clásicos.

Diversos métodos han sido utilizados, desde la época en que Faber y Cuicacio se avocaran a detectar estas alteraciones. Se ha pretendido hallarlas a través de criterios textuales, históricos, exegéticos, sistemáticos y logico-jurídicos; incluso se ha intentado siguiendo vías diplomáticas y filológicas.

No debe confundirse el problema ya expuesto con las denominadas interpolaciones pre-justinianas, también conocidas bajo la designación de glosemas. Estas alteraciones generalmente tienen por origen errores de escritura o notas marginales o interlineales debidas a quienes estudiaban las obras. A veces, las alteraciones derivan de una deficiente interpretación de abreviaturas o siglas usadas en los textos (*Notae Iuris*); de allí la prohibición de Justiniano a los compiladores de utilizar siglas en el *Corpus Iuris*.

Muchas son las críticas que en mérito a las interpolaciones ha merecido la tarea de los compiladores del *Corpus Iuris*.

Sin embargo, no debe perderse de vista que estamos frente a un cuerpo de juristas que a fin de lograr la unificación del Derecho, recibieron del Emperador la facultad de modificar, suprimir o adaptar los textos. Tal vez las más duras objeciones se hubieran subsanado de haberse omitido la mención del autor clásico a quien se afirma pertenece el párrafo. Es decir si fuera posible distinguir la ver-

dadera opinión del jurista originario de la metamorfosis sufrida por el texto, una crítica cabría a quienes estaban empeñados en una tarea legislativa.

Sin embargo, y aún así, la cita interpolada al nombrar al autor primigenio no perseguía otra cosa que el reconocimiento de los más caracterizados juristas clásicos.

• *Corpus Iuris Civilis*

Con la invención de la imprenta, en el siglo XV, aparecen las primeras ediciones impresas de la obra justiniana. Al comienzo, se publicaron las diversas partes separadamente.

Serán las Institutas las que merecerán las primeras ediciones. En Maguncia en 1468, es dirigida por Schoffer, a la que seguirá en 1503, en Francia, la edición de Chappuis.

Gregorio Meltzer, también conocido como Haloander, publicará en 1529 una edición destacada (*Lectura Haloandrina*).

En 1585, el célebre humanista Cuiacius, editará una de las más trascendentes.

En cuanto al Digesto, en la última parte del siglo XV, también será impreso, con la peculiaridad de que se lo hace dividido en tres partes: *Digestum Vetus*, *Infortiatum* y *Novum*.

En 1476, Clain realiza la del *Digestum Vetus*, en Perugia, en 1475 el *Infortiatum* es editado en Roma por Puecher, y en 1476 también por Puecher y en Roma el *Digestum Novum*.

Haloander lo publicó en Nürenberg en 1529 y Pothier en París en 1748.

El Código mereció diversas ediciones entre 1550 y 1573. Entre ellas Cuiacius (1563) realizó una edición de los tres últimos libros.

La primera edición completa de la compilación justiniana corresponde a fines del siglo XVI a Dionisio Godofredo, quien la publicó en Ginebra en 1583. A él se debe el nombre de *Corpus Iuris Civilis* con que se conoce hoy a la obra legislativa de Justiniano.

Indudablemente la más notable y completa edición ha sido la publicada por Mommsen y Krüger, con colaboración de especialistas como Schoell y Kroll, que data de los años 1866, 1870.

Una obra más moderna fue efectuada en Milán (1908/1931) bajo la dirección de Riccobono, Ferrini, Bonfante, Scialoja y Fadda.

Las Escuelas de Derecho en Oriente

"Y estos tres volúmenes que hemos compuesto (Código, Institutas y Digesto) queremos que se enseñen tan solo en las capitales (Roma y Constantinopla) así como en la muy hermosa ciudad de Berito, que se podría llamar con razón el alma mater del estudio de las leyes, como ya han dispuesto otros príncipes anteriores; pero no en otros lugares que no merecieron tal privilegio de nuestros antecesores. . ." (Constitución *Omnem Reipublicae*, 7).

No aparece durante el Dominado ningún gran jurisconsulto a la manera de la época clásica. Como señalara algún autor la mayoría de los juristas de ese período son desconocidos, tornándose anónima la jurisprudencia.

La jurisprudencia clásica provocaba profunda admiración y respeto, rindiéndosele culto traducido en los estudios que sobre la misma se efectuaban en las escuelas —en particular en las oficiales— que fueron numerosas en la etapa post-clásica.

Ya a inicios del siglo III, se nota la necesidad de la creación de tales escuelas. Poséese información que su tarea se extendió ininterrumpidamente por los juristas de los siglos IV y siguientes. De Occidente no se tienen mayores noticias, en tanto en Oriente, se conocen las escuelas de Berito y Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Cesarea. De ellas sobresalen las dos primeras, siendo mucho menor la significación de las tres últimas.

La escuela de Berito hizo que a esa ciudad de Siria se la considerara como “escuela de derecho” y “madre del derecho”, aumentando su fama. Resaltan durante el siglo V, profesores como Cirilo, Patricio, Doroteo, Eudasio, Leoncio y Demóstenes, renombrados durante siglos en la doctrina bizantina.

Teófilo y Cratino, según sabemos por la mención de las constituciones justinianas, pertenecieron a la escuela de Constantinopla.

Estos estudios, sin embargo, no poseían la fuerza creadora de los siglos anteriores; sus profesores se dedicaban generalmente a estudiar la obra de los juristas clásicos, reelaborándolas y adaptándolas a los cambios y necesidades de la época. Preferentemente se dedicaron, al parecer, a los juristas considerados en la ley de las citas.

Gracias a la labor desarrollada por estas escuelas debió encontrar Justiniano el material y los juristas que hicieron posible la elaboración del *Corpus Iuris Civilis*.

Capítulo 8

SUMARIO:

- I. Obras jurídicas de la época.
- II. Los glosadores.
- III. Los comentaristas.
- IV. La recepción del derecho romano en Alemania.
- V. El humanismo.
- VI. La escuela histórica : Savigny.
- VII. El derecho romano en la Argentina.

EL DERECHO ROMANO DESPUES DE JUSTINIANO

El Imperio de Oriente sobrevive 900 años a Justiniano, hasta que en 1453, Constantinopla es tomada por los turcos.

En Occidente, en el año 800, se inaugura el Sacro Imperio Romano Germánico al ungir el Papa León III a Carlomagno como Emperador. Por ello es considerado el primer rey de Europa, al rebasar sus dominios las costas mediterráneas del antiguo imperio.

Por entonces, el imperio queda reducido significativamente: los árabes conquistan el norte de África y Egipto, habiendo los Francos obtenido Sicilia, España e Italia.

En Occidente, el Derecho Romano deja de ser el derecho común a muchos pueblos.

Esto, unido al surgimiento y afianzamiento de las nacionalidades, va generando el nacimiento de derechos locales. Ello a pesar de que en el caso de Italia, Justiniano, después de derrotar a los ostrogodos, había puesto en vigencia su legislación mediante una constitución imperial (*Sanctio Pragmática Pro Petitione Vigili*). Después de Justiniano ya no hay expansión militar romana, pero sí hay influencia, penetración jurídica en la mayor parte de las naciones europeas.

Al derrumbarse el Imperio surgen nuevas naciones, en donde se retoman las libertades creadoras, que habían sido desconocidas durante el Dominado.

Sumado a ello, el Cristianismo introduce pautas de considerable importancia, que hacen nacer una nueva concepción ético-jurídica. Sin embargo, se hace difícil, para las nuevas naciones, abandonar las ideas romanas. En las nuevas naciones se agudiza el conflicto entre las nuevas experiencias espirituales y la herencia cultural extraña. Tantos siglos de dominación romana han dejado en los pueblos profundas huellas sobre las que todavía es difícil transitar. El idioma, la poesía, la arquitectura, las ideas de los filósofos griegos son difíciles de cambiar y olvidar.

A medida que los nuevos pueblos reflexionan acerca de lo realizado por los romanos, llegan a comprender en su exacta dimensión el inmenso valor del legado recibido.

Lo devenido durante, esta época post-justiniana, y lo acontecido en el Dominado, impide, que podamos adherir a la tesis relativa a la existencia de un derecho romano vulgar. Porque en el Dominado no se abandonaron los clásicos. Si bien

no hubo creación, se tuvo muy en especial, en cuenta su producción, siendo objeto permanente de estudio. Con la caída del Imperio lo que cambiaron fueron las formas políticas, pero no las formas jurídicas, pues se siguen las opiniones de los juristas de la época de oro de la jurisprudencia clásica.

X Obras Jurídicas de la Época

Aunque la mayor parte de la literatura jurídica post-justineana aparece expresada en idioma griego, las fuentes del Derecho Romano clásico perduran a través de ella.

Así, con las dificultades propias del idioma, los juristas traducen del latín al griego la obra de Justiniano y muchos de los principales textos clásicos.

Tal es el caso de la denominada Paráfrasis de Teófilo, traducción griega explicativa de las Institutas de Justiniano. La obra se conoce a través de diversos manuscritos, entre los que se destaca uno que reúne comentarios a la Paráfrasis debido a Doroteo y otro que pertenece a Esteban, ambos destacados juristas de la época.

Teófilo, junto a Triboniano, Doroteo, Anatolio y Cretino, es uno de los grandes jurisconsultos del siglo VI que realizaron la labor compiladora ordenada por Justiniano.

A la Paráfrasis sigue en período de real decadencia del derecho, ya que la Escuela de Derecho de Constantinopla estuvo cerrada durante 120 años (730 al 850).

A pesar de ello, en el 740 aparece la Ecloga Legum, también conocida como Ley Isaurica o Enchiridion. Es una selección de leyes, bajo la forma de un manual de derecho, donde también aparecen fragmentos de obras jurídicas del siglo VI. Su publicación fue ordenada por León III (el isaurico) emperador de Bizancio.

En el 870, otro emperador de Bizancio, Basilio el Macedonio, manda publicar otro manual de derecho, conocido como Constitución de Basilio o Prochiron. En el mismo se examinan y comentan algunas colecciones de leyes de Justiniano, las contenidas en la Ecloga Legum y algunas constituciones imperiales de la época.

El Prochiron será luego completado y revisado por la Epanagoge, que surge en el 880 por orden de Basilio, junto a sus hijos León el Filósofo y Alejandro.

A principios del siglo X, aparece una de las más importantes compilaciones posteriores a Justiniano: las Basílicas, llamada así por haber sido iniciativa de Basilio el Macedonio y que logra concretar su hijo, ya emperador, León VI, el Filósofo. Es tal su trascendencia que, algunos autores, llegan a reconocer que se trata del trabajo de compilación más importante del derecho romano, después del Corpus.

Las Basílicas tienen el valor indiscutible de reflejar la cultura jurídica de una época, en que afloran las connotaciones greco-orientales, pero sin desconocer las marcadas influencias del derecho romano clásico, que había inspirado a la obra de Justiniano. Los que elaboraron las Basílicas trabajaron sobre el Corpus, pero no en forma directa sino a través de traducciones en griego, como así también sobre comentarios de juristas del siglo VI (Antiguas) y notas explicativas de esa época (Scholias).

En 1453, Constantinopla quedará en manos de Mahometo II, desplazándose los juristas griegos hacia Grecia e Italia, y con ellos la influencia jurídica greco-latina.

Es allí, en Occidente, donde entre los siglos XI y XII, aparecen dos importantes trabajos jurídicos: a) el Brachylogus, compendio elemental de derecho que algunos atribuyen, sin certeza alguna, a Irnerio, y que sigue el esquema de las Institutas de Justiniano. b) y las Petri Exceptiones Legum Romanorum, surgido en Valencia, población del reino de Arles, y que también está realizada siguiendo los pasos de las Institutas de Justiniano. La denominación de la obra proviene de Petrus, sobre quien se ignora todo otro dato y de la naturaleza del libro (exceptiones = extractos).

Los Glosadores

A partir del siglo X, en las escuelas nórdicas italianas (Ravena, Pavia y Bolonia) va a gestarse un nuevo enfoque del Derecho Romano clásico. En estas escuelas, que después serán universidades, los estudios comienzan por la gramática y la retórica, llegando luego a profundizarse los temas jurídicos.

Así el caso de Pavia, que en el siglo X era la ciudad capital del Estado longobardo, ya que los lombardos habían ocupado esta región de Italia en el 568 d. C. En Pavia se estudia derecho lombardo con sentido filológico, y se quiere adaptar el derecho romano a las instituciones longobardas. En esta época aparece la Lombarda, compilación de leyes lombardas, que siguen la estructura, el orden y la sistemática del Corpus.

La de Bolonia nace como escuela de arte, y será más tarde la más famosa escuela de derecho, componiendo la ilustre trilogía de excelencia universitaria, junto a la de Salerno en medicina y la de París en teología.

Aunque posterior a Pavia, la labor desarrollada en Bolonia es más fecunda. Iban a ella alumnos de todas las comarcas, en especial italianos y alemanes. Se estima que llegó a tener más de 10.000 alumnos y que algunas clases eran dictadas en las calles.

Es allí donde nace la denominada escuela de los glosadores, iniciada por Irnerio.

Su nombre proviene de las notas o comentarios que realizaban y que se denominan glosas (Glossa: palabra oscura que necesita explicación).

Producen así glosas interlineales, colocando sinónimos encima de las palabras confusas. Y glosas más extensas, como las marginales, que son verdaderos comentarios de una idea que surge del texto. Su interpretación es en general gramatical, pero como trabajan sobre manuscritos de leyes de Justiniano (*Corpus*) forzosamente se transforma, en muchos casos, en un análisis jurídico.

Además de glosas, Bolonia elabora otras tareas jurídicas: Summas (resúmenes de textos jurídicos de los que se intenta extraer reglas generales) Cassus (creación de casos imaginarios para explicar textos jurídicos) Distinctiones (exposición de distinciones conceptuales) y Dissensiones Dominorum (colecciones de controversias).

Para lograr las glosas, examinaban el *Corpus*, la *Lombarda* y los *Libri Feudorum* (derecho feudal lombardo compilado).

Son los principales integrantes de esta escuela, Irnerio, Azón, Odofredus, Placentino y Accursio, como así también algunos notables discípulos de Irnerio, y que fueran denominados los 4 Doctores (Búlgaro, Martino, Jacobo y Hugo).

Los glosadores respetaban el *Corpus* como si se tratase de las Sagradas Escrituras, y en esto adoptaban una posición política: eran gibelinos, pues defendían el derecho del emperador, el poder terrenal, frente a los güelfos, que sostenían que la preeminencia en el poder pertenecía al Papado.

Pero indudablemente la seriedad de sus estudios, hará que Bolonia trascienda las fronteras italianas, llegando las glosas a estudiarse en las principales universidades europeas (Valencia, Salamanca, Lérida, Orleans, Oxford) y en muchas escuelas científicas alemanas. Las glosas eran producto de utilizar el método *exegético*, que consiste en interpretar la ley a través de su texto, analizando estrictamente su significado gramatical. Esta tarea era lograda mediante ocho operaciones: *Promitto* (enunciación del problema en conjunto); *Scindo* (separar lógicamente el problema del párrafo); *Summo* (recapitulación con referencia a autoridades y decisiones); *Casumque Figuro* (ejemplificación); *Prolego* (crítica de textos); *Do Causas* (las cuatro causas aristotélicas); *Connoto* (analogía); y *Obliicio* (objeciones y controversias).

La tarea de los glosadores se concentraba, exclusivamente, en el análisis exhaustivo de los textos, hasta la aparición, en el siglo XIII de un discípulo de Azón y de Odofredus, Accursio, quien va a compilar las obras de sus maestros, bajo el título de Gran Glosa o Glosa Ordinaria. Algunos han intentado compararla, por su importancia, con el Digesto, paralelismo éste que no parece acertado ya que las Pandectas formaron parte de una compilación oficial, no teniendo la obra de Accursio un valor vinculante.

Lo que intenta Accursio, con su Gran Glosa, es llevar a la práctica los comentarios obtenidos por los glosadores. Es la pretensión de trasladar a los Tribunales la obra de Irnerio y sus continuadores. Y esta va a ser la tarea de quienes sucederán a los glosadores, los comentaristas.

A los comentaristas, también se los conoce como post-glosadores, denominación no demasiado feliz, ya que no pueden ser así denominados habida cuenta de que no es posible que se los considere como meros epígonos de aquellos, sino una escuela con caracteres propios. Y porque su tarea apunta hacia la resolución de los casos concretos, Wieacker los llama Consiliares (dictaminadores) porque elaboran dictámenes para resolver casos jurídicos prácticos.

Esta escuela, surgida en el siglo XIV, logra insertar las glosas dentro del derecho estatutario y consuetudinario italiano, las costumbres y estatutos de Francia y los derechos de los territorios y ciudades de Alemania.

Realizan extensos comentarios jurídicos y producen una copiosa literatura, a través de las obras de BARTOLO DE SASOFERRATO y de BALDO DE UBALDIS.

A diferencia de los glosadores, no solo estudiaron el *Corpus*, sino además el derecho estatutario de los municipios italianos, el derecho canónico y la costumbre.

Emplean el método dialéctico aristotélico, influenciados por la escolástica, pues es este el sistema propio de los canonistas. Pero lo más trascendente de su labor reside en el hecho de haber sido los iniciadores y divulgadores de la corriente metodológica conocida como el *Mos Italicus*, (el derecho visto a la manera de los glosadores y comentaristas). Ello significa el respeto por las verdaderas fuentes del Derecho Romano, que no son otras que el *Corpus* y la necesidad de trasladar a la práctica los principios allí contenidos.

La Recepción del Derecho Romano en Alemania

Los comentaristas posibilitaron que el Derecho Romano fuese conocido y aplicado en casi toda Europa. Tal como el caso de Alemania, donde se produce el fenómeno que se conoce como la recepción del Derecho Romano, acaecido entre los siglos XV y XVI.

Ello como consecuencia de la falta de unidad política de esta nación. Al existir en ella innumerables derechos locales, se impide la resistencia a la recepción de un derecho extraño.

De esta forma el Derecho Romano estará allí vigente por más de cuatro siglos.

Ello se debe a los estudiantes alemanes que se formaron en las escuelas italianas, como Bolonia. De regreso, en su patria, no hicieron más que aplicar las doctrinas que los defensores del *Mos Italicus* les habían inculcado.

En Alemania, la casi totalidad de los profesores de derecho eran italianos y franceses egresados de las universidades italianas.

El Tribunal Cameral del Imperio, reorganizado en 1495, está constituido en su mitad, por jueces formados en el derecho romano. A partir de esta época surgen también tribunales letrados que aplican el derecho romano en sus sentencias,

demonstrando su superioridad frente a las resoluciones de jueces legos, que aplican el derecho local.

Recién el reinado del derecho romano puede considerarse acabado cuando, en 1900, se sanciona el Código Civil Alemán.

El Humanismo

También conocida como escuela francesa del siglo XVI, reúne a los juristas que se rebelan ante los métodos característicos de los canonistas.

Desechan el método de la escolástica, propio del derecho canónico, y llegan al derecho romano por la filología, la historia, la religión, la literatura y la filosofía.

Aunque la escuela nace en Italia, donde puede mencionarse entre sus iniciadores a Alciato, es en Francia donde esta tendencia obtiene su más amplio desarrollo. Entre sus principales representantes puede mencionarse a Cujacius, Budeo, Zasius y Donadeu.

Los juristas partícipes del humanismo propugnan volver a las fuentes; no intentan resolver casos prácticos sino preservar el verdadero Derecho Romano. Usan el latín clásico ciceroniano, desechando el latín medieval y vulgar, inaugurando así, la etapa denominada como la de la "jurisprudencia elegante". Desarrollan sus estudios a partir del Corpus. Quienes actúan en Francia, lo hacen, principalmente, en la escuela de Bourges. Allí es donde nace la corriente conocida como el *Mos Gallicus*. Sus propulsores sostenían la idea de que el derecho romano debía examinarse a la luz de fuentes históricas, filológicas y literarias. Siguiendo esta línea rechazan y hasta ignoran la labor de los glosadores y los comentaristas. Teorizan sobre el derecho romano, hasta tal punto que, en algunas ocasiones, llegan a cuestionar la ordenación del Corpus, formulando su propio esquema, mediante nuevas interpretaciones basadas en disciplinas extrajurídicas.

Cuando se inicia el movimiento de la reforma se enrolan en ella. Esta decisión les acarreará severas persecuciones, debiendo muchos de ellos emigrar para salvar sus vidas.

Sus exilios permiten la difusión del humanismo fuera de Francia y el nacimiento de nuevas escuelas. Tal como la del Derecho Natural, fundada por Grocio y la Escuela Estatutaria Holandesa de Vinnius. Ambas escuelas sostienen la existencia de un derecho común a todos los pueblos, nacido de la razón humana.

La Escuela Histórica: Savigny

Esta escuela aparece en Alemania, en el siglo XIX, constituyendo un movimiento jurídico trascendental en lo que hace a su especial enfoque respecto del derecho romano.

Su principal exponente ha sido Federico Carlos Von Savigny quien apartándose del racionalismo ahistórico propiciado por el humanismo, propone apoyarse en los valores espirituales clásicos humanos.

Savigny decía: "El derecho responde, en su evolución, al espíritu del pueblo, que es el que va a forjar los caracteres de la nación".

Esta postura, más que a la obra de un hombre, se debe a una época. El siglo XIX marca el tiempo del romanticismo, movimiento que surge en la Europa del siglo XVIII y que trasciende hacia Alemania hacia el siglo XIX.

El romanticismo se instala en la poesía, en la música, en la literatura, en la filosofía y también en las ciencias jurídicas.

Savigny descubre el derecho como manifestación histórica, superando la concepción de Grocio. Su avasallante capacidad intelectual le permite, a los 24 años, elaborar su famoso Tratado sobre la posesión y luego su "Sistema de derecho romano actual".

Hay que admitir que Savigny, al menos en Alemania, cambia el curso de la historia del Derecho Romano. Tras un largo período de estancamiento, que abarca buena parte del siglo XVIII, renacen los estudios romanísticos gracias al impulso de la escuela histórica.

Aunque algunos autores, como Koschaker, insisten en calificar al gran maestro alemán como jefe de una escuela de derecho profesoral y no de juristas, lo cierto es que los cargos desempeñados por Savigny, exceden muchas veces el ámbito universitario. Así fue designado como miembro de la Corte renana de revisión y casación (1819) y durante 6 años (1842-48) fue ministro prusiano de legislación.

De este modo la escuela va a transmitir su posición romanista a través de los proyectos de ley cambiaria, de prensa y penal, el Código Civil sajón de 1863 y el Código de Comercio Alemán de 1861.

Los principios sostenidos por la escuela posibilitarán la elaboración y sanción de Código Civil alemán, sobre todo en los que hace a su sistematización y ordenamiento, propios de la Pandectística.

El Derecho Romano en la Argentina

Ya en el período hispano, al igual que en la mayoría de las naciones europeas y americanas de origen español se denota la influencia romanística.

No obstante que los monarcas visigodos, al sancionarse el Fuero Juzgo (siglo V d.C.) habían quitado la vigencia a las leyes romanas en España, ello no impidió que los jurisconsultos mantuvieran las doctrinas de los juristas romanos y medievales como criterio para las soluciones jurídicas.

Las Leyes de Partida (siglo XIII d.C.) hacen referencia permanente a los *SABIOS* (romanistas) y a los *SANTOS* (canonistas). Las Partidas reconocen la mayor influencia romana de toda la legislación española; dada su aplicación perma-

nente en el Virreinato, podría afirmarse que el derecho romano era usado en la colonia.

Además quienes aplicaban la ley habían estudiado en las universidades, primero de Chuquisaca y luego de Córdoba, donde se estudiaban las instituciones romanas.

La recepción del derecho romano, en nuestro país, a partir de la organización nacional, debe observarse a la luz de los principios que inspiraron a Velez Sarsfield en la elaboración del Código Civil argentino.

La influencia romanística, en el Código sancionado en 1869, es evidente, tanto en el texto legal como en sus notas.

Se destaca el origen romanístico con mayor nitidez en materia de derechos creditorios (obligaciones y contratos); también en lo que hace a derechos reales es considerable la influencia.

Podemos afirmar que el Código Civil argentino resulta incluso más sujeto a la tradición romanística que el Código Civil francés.

En las notas existe una presencia permanente de las fuentes romanas, ya sea por cita de textos romanos, ya de otras fuentes legales que reconocen ese origen o de autores como Savigny, Pothier, Maynz, Molitor y otros romanistas.

Ello como consecuencia de la formación jurídica que fue adquiriendo Velez Sarsfield a través del tiempo.

Comenzando por sus estudios universitarios, que desarrolló en Córdoba entre los años 1812 y 1819.

En esa escuela de derecho, ya en 1791 se había creado una cátedra dedicada al estudio de la Instituta. Allí se analizaba la Instituta de Justiniano a través de la Paráfrasis de Teófilo.

En la universidad serrana el codificador llega al derecho romano leyendo a los grandes maestros: Cujas, Heineccius, Vinnius y Pothier.

Luego vendrá la etapa de la redacción del Código, iniciada en 1865. Hasta esa fecha, el Derecho Civil argentino solo reconocía como fuentes una buena cantidad de leyes dispersas, que provenían de la legislación española, y algunas disposiciones de los gobiernos patrios, dictadas a partir de 1810.

Pese a ello, en su mensaje de elevación al Poder Ejecutivo, donde presenta el primero de los cuatro libros que componen el Código, Velez Sarsfield se aparta de la legislación vigente, mencionando como fuentes de su obra los códigos civiles elaborados en Europa y América, entre ellos el de Chile, el de Luisiana y el de Francia; la legislación comparada de Seoane, el proyecto de García Goyena para el Código Civil español; el de Freitas para el Código brasileño, y las obras de Savigny, de Zachariae y de Story.

Sin embargo, a pesar de lo taxativo de esta mención, es marcada la influencia de la Recopilación y las Partidas en nuestro Código. Como ya se dijo, estas fuentes hispanas evidencian, a su vez, la recepción de los principios del viejo derecho civil romano. No debe olvidarse la dominación que por casi 7 siglos ejerció Roma sobre la península ibérica.

Así también merece señalarse la permanente referencia de Velez al derecho canónico. En esta materia existe prueba irrefutable de su versación en ella: en 1854

había publicado su estudio acerca del derecho público eclesiástico.

En definitiva, nuestro Código Civil y con él todo el derecho privado argentino, reconoce como fuentes directas e indirectas a las instituciones romanas.

En las universidades argentinas, salvo breves períodos en que razones ajenas a lo académico la excluyeron de algunos planes de estudio, el derecho romano ha sido materia común en nuestras facultades.

En las diferentes casas de estudios, la enseñanza del derecho romano ha contado y cuenta con destacados estudiosos y personalidades que han tenido a su cargo el dictado de la materia.

En la Universidad de Buenos Aires, desde el primer docente (Dr. Exequiel Pereyra, 1862) se han sucedido profesores como Vicente Fidel López, Pedro Goyena, Carlos Ibarguren, Ernesto Weigel Muñoz, Eduardo R. Elguera, Santiago de Estrada y José M. Carames Ferro.

En la Universidad de Córdoba, Victoriano Rodríguez, Dámaso Gigena, y más recientemente, Agustín Díaz Bialek y Luis Garzón Funes.

En la Universidad Nacional de La Plata, la cátedra de derecho romano se ha visto prestigiada por eximios profesores como los Dres. Gastón Federico Tobal, Carlos Ernesto Ambrosioni y Alfredo Di Pietro.

81089



BIBLIOGRAFIA

I.— FUENTES

- Corpus Iuris Civilis - Cuerpo de Derecho Civil Romano. Hnos. Kriegel, Hermann y Osenbrugen, Trad. I. L. García del Corral. Jaime Molinas Editor, Barcelona, 1889/1898.
- El Digesto de Justiniano. Trad. A. D' Ors, F. Hernandez Tejero, P. Fuenteseca, M. García Garrido y J. Burillo. Ed. Aranzadi, Pamplona, 1968/1975.
- Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano. M. Ortolan. Trad. F. Pérez de Anaya y M. Pérez Rivas. L. López Editor, Madrid, 1884.
- Instituciones de Justiniano. (Ed. Bilingüe) M. O. Ortolán. Trad. F. Pérez Anaya y M. Pérez Rivas. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1960.
- Instituciones - Gayo. (Ed. Bilingüe) Trad. F. Hernandez Tejero y otros. Ed. Civitas S. A., Madrid, 1985.
- Institutas - Gaius. Texto trad., notas e introducción A. Di Pietro. Ed. Librería Jurídica, La Plata, 1975.
- Institutas - Gayo. Texto trad., introducción y notas A. Di Pietro. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1987 (3a. ed.).
- Reglas de Ulpiano. Trad. y notas N. Ponssa de la Vega de Miguens. Ed. Lerner, Buenos Aires, 1970.

II.— TEXTOS Y AUTORES CLASICOS

- Ammiano Marcelino. Historia del Imperio Romano. Trad. F. Norberto Castilla. Lib. de la Vda. de Hernando, Madrid, 1895.
- Anneo Floro. Gestas Romanas. Trad. J. E. Díaz Jimenez. Espasa Calpe Argentina S. A., Buenos Aires, 1952.
- Aulo Gelio. Noches Aticas. Trad. Francisco Navarro y Calvo. Lib. de la Vda. de Hernando, Madrid, 1893.
- Ciceron. Discursos - Diálogos sobre la República - De las Leyes - Cuestiones Academicas. Trad. Martinez Herranz, Gayo Arias y Aldo Berti. Edae, Madrid, 1977.
- Ciceron. Los Oficios o los Deberes; De la Vejez; De la Amistad. Ed. Porrúa. México. 1978.
- Julio Cesar. La Guerra de las Galias. Trad. V. Lopez Soto. Ed. Juventud S. A., Barcelona, 1971.
- Marco Aurelio. Soliloquios o reflexiones morales. Trad. J. Diaz de Miranda Ed. Espasa Calpe Argentina S. A., Buenos Aires, 1947.
- Platon. República. Trad. A. Camarero. Eudeba, Buenos Aires, 1985.
- Plutarco. Vidas Paralelas. Trad. A. Rauz Romanillos. Ed. Iberia, Barcelona, 1979.

- Polibio. Historia Universal durante la República Romana. Trad. J. Diaz Casamada. Ed. Ibería, Barcelona, 1968.
- Suetonio. Vida de los Doce Césares. Trad. V. Lopez Soto. Ed. Juventud S. A., Barcelona, 1978.
- Tacito. Los Anales. Trad. C. Coloma. Ed. Espasa Calpe Argentina S. A., Buenos Aires, 1952.
- Virgilio. Eneída - Georgicas - Bucólicas. Ed. Porrúa S. A., Méjico, 1980.

III.— TRATADOS Y MANUALES

- Altheim, Franz. Historia de Roma. Trad. C. Gerhard. Uteha, Méjico, 1961/1964.
- Ambrosioni, Carlos E. Lecciones de Derecho Romano. Ed. Librería Jurídica, La Plata, 1965.
- Alvarez Suarez, Ursicino. Curso de Derecho Romano. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955.
- Arangio Ruiz, V. Historia del Derecho Romano. Inst. Ed. Reus, Madrid, 1943.
- Arias Ramos, J. Compendio de Derecho Público Romano e Historia de las fuentes. Valladolid, 1961.
- Bonfante, Pietro. Historia del Derecho Romano. Trad. J. Santa Cruz Teijeiro. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944.
- Carames Ferro, José M. Curso de Derecho Romano. Ed. Perrot, Buenos Aires, 1976.
- Carames Ferro, José M. Instituciones de Derecho Privado Romano. Ed. Perrot, Buenos Aires, 1975.
- Carames Ferro, José M. y Louzan de Solimano. Derecho e Historia en Roma. Ed. Perrot, Buenos Aires, 1976.
- De Francisci, Pietro. Síntesis histórica del Derecho Romano. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954.
- Di Pietro, Alfredo y Lapieza Elli Angel E. Manual de Derecho Romano, Buenos Aires, 1976.
- Heineccio, J. G. Recitaciones del Derecho Civil según el orden de la Instituta. Trad. L. de Collantes. Lib. de Garrier Hnos., París, 1888.
- Iglesias, Juan. Derecho Romano, Instituciones de Derecho Privado. Ed. Ariel S. A., Barcelona, 1983.
- Jors, Paul y Kunkel Wolfgang. Derecho Privado Romano. Trad. L. Prieto Castro. Ed. Labor S. A., Barcelona, 1937.
- Kaser, Max. Derecho Romano Privado. Trad. J. Santa Cruz Teijeiro. Reus S. A., Madrid, 1968.
- Kruger, P. Historia, Fuentes y literatura del Derecho Romano. Editorial La España Moderna, Madrid.
- Kunkel, Wolfgang. Historia del Derecho Romano. Trad. J. Miquel. Ed. Ariel S. A., Barcelona, 1982.

- Lapieza Elli, Angel E. Historia del Derecho Romano. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1981.
- Moreira Alves, José C. Direito Romano. Forense, Río de Janeiro, 1983.
- Namur, P. Curso de Instituciones y de Historia del Derecho. Trad. L. M. Boerr y A. P. Escamilla. Ed. Teodomiro Real y Prado, Buenos Aires, 1943.
- Ortolan M. Historia de la Legislación Romana. Trad. D. F. Perez de Anaya y D. M. Perez Rivas. Lib. D. L. López, Madrid, 1879.
- Petit, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. Trad. J. Ferrandez Gonzalez. Ed. Albatros, Buenos Aires, 1977.
- Piganiol, A. Historia de Roma. Trad. R. Anaya. Eudeba, Buenos Aires, 1961.
- Rostovtzeff, M. Roma, de los orígenes a la última crisis. Trad. T. Nuñez de la Torre. Eudeba, Buenos Aires, 1980.
- Vogel, Carlos. Historia del Derecho Romano. (Clases del Dr. José M. Carames Ferro. Ed. Perrot, Buenos Aires, 1985.
- Volterra, Eduardo. Instituciones de Derecho Privado Romano. Trad. J. Daza Martínez. Ed. Civitas S. A., Madrid, 1986.
- Wieacker, Franz. Historia del derecho privado en la Edad Moderna. Ed. Aguilar, Madrid, 1957.

IV.— OTRAS OBRAS DE CONSULTA

- Allende, G. Los glosadores. Rev. La Ley, Tomo 134, Buenos Aires, 1969.
- Altheim, Franz. "El Dios invicto - Paganismo y Cristianismo. Trad. J. J. Thomas. Eudeba, Buenos Aires, 1966.
- Barrow, R. H. Los romanos. Trad. M. Villegas de Robles. Uteha, Méjico, 1950.
- Belloc, Hilaire, Europa y la fe. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1967.
- Bloch, Raymond. Los prodigios en la antigüedad clásica. Trad. E. J. Prieto. Ed. Paidós SAICF. Buenos Aires, 1975.
- Brunt, P. A. Conflictos sociales en la República Romana. Trad. R. Masera. Eudeba, Buenos Aires, 1973.
- Carcopino, J. Las etapas del imperialismo romano. Trad. E. J. Prieto. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1968.
- Carcopino, Jerome. La vida cotidiana en Roma. Librería Hachette S. A., Buenos Aires, 1942.
- Carpintero, F. Mos Italicus, Mos Gallicus. Rev. Prudentia Iuris, N° 8, Buenos Aires, 1982.
- Catalano, Pierangelo. Un concepto olvidado: poder negativo. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo LXXX, N° 3, 1980.
- Corrente Spano, Dante D. Fuentes del Derecho Romano. Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1971.
- Crifo, Giuliano. La legge delle XII tavole. Osservazioni e problemi. Roma, 1972.
- Declareuil, J. Roma y la organización del derecho. Trad. J. Lopez Perez. Uteha, Méjico, 1950.

Romero, José Luis. La crisis de la República Romana. Ed. Losada S. A., Buenos Aires. 1942.
 Villey, Michel. El Derecho Romano. Trad. M. Lafitte de Juncal y J. A. Juncal. Eudeba, Buenos Aires, 1963.

- Díaz Biale, Agustín. La recepción del Derecho Romano en la Argentina. Imprenta de la Universidad, Córdoba, 1951.
 Di Pietro, Alfredo. Ius Fasque est. Rev. Prudentia Iuris, Buenos Aires, 1980.
 Di Pietro, Alfredo. El concepto de la ley en Cicerón. Rev. Moenia, Buenos Aires, 1987.
 Di Pietro, Alfredo. Verbum Iuris. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires., 1968.
 Di Pietro, Alfredo. Iustissima Tellus. Rev. Iustitia, Buenos Aires, 1965.
 Durant, Will. César y Cristo. Trad. L. Tobío. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1959.
 Ferrero, Guglielmo. Las mujeres de los Césares. Trad. M. Albano. Ed. Emecé, Buenos Aires, 1945.
 Festugiere, A. J. Libertad y civilización entre los griegos. Trad. M. E. Ferreyra. Eudeba, Buenos Aires, 1972.
 Fustel de Coulanges, Numa D. La ciudad antigua. Trad. G. Rodríguez Suarez. Editora Selene, Buenos Aires, 1985.
 Grimal, Pierre. El siglo de Augusto. Trad. R. Anaya. Eudeba, Buenos Aires, 1972.
 Guillemin, M. A. Virgilio, poeta, artista y pensador, Trad. E. J. Prieto. Ed. Paidós SAICF, Buenos Aires, 1968.
 Haecker, Theodor. Virgilio, padre de Occidente. Trad. V. García Yerba. Ediciones Ghersi, Buenos Aires, 1979.
 Homo, León. Nueva Historia de Roma. Trad. J. Farran y Mayoral. Ed. Iberia, Madrid, 1982.
 Hus, Alain. Los etruscos. Trad. J. Gutierrez Heras. Fondo de Cultura Económica, México, 1975.
 Ihering, Rudolf von. El espíritu del Derecho Romano en las diversas formas de su desarrollo. Trad. E. Príncipe y Satorres. Ed. Bailly-Baillière, Madrid, 1909.
 Jones, A. H. M. Augusto. Trad. A. L. Bixio. Eudeba, Buenos Aires, 1974.
 Koschaker, P. Europa y el Derecho Romano. Trad. J. Santa Cruz Teijeiro. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955.
 Levi, Adolfo. Historia de la filosofía romana. Trad. Héctor Pozzi, Eudeba, Buenos Aires, 1969.
 Madaule, Jacques. César. Trad. A. Horovitz. Eudeba, Buenos Aires, 1966.
 Miquel, Juan. Reflexiones en torno a una palingenesia de las Basílicas. Anales de la Universidad de La Laguna, La Laguna de Tenerife, Islas Canarias, 1965/1966.
 Mommsen, Teodoro. Derecho Penal Romano. Trad. P. Dorado. Ed. Temis, Bogotá, 1976.
 Mommsen, Teodoro. Historia de Roma. Trad. A. García Moreno. Aguilar, Madrid, 1987.
 Oppermann, Hans. Julio César. Trad. R. P. Blanco. Salvat Editores S. A., Barcelona, 1985.
 Riccobono, Salvatore. Roma, madre de las leyes. Trad. J. J. Santa - Pinter. Depalma, Buenos Aires, 1975.



INDICE ALFABETICO

(Las referencias numéricas corresponden a las páginas)

"A"

Acción noxal, 78.
accusatio suspecti tutoris, 76.
actio aquae pluviae arcendae, 73.
- arboribus succisis, 75.
- de pastu pecoris, 74.
- de pauperies, 74.
- de tigno iunctio, 72.
- familiae erciscundae, 71.
- finium regondorum, 73.
- rationibus distrahendi, 76.
ACCURSIO, 130.
adnotatio, 105.
adoptio, 70, 72.
addictio, 73.
ADRIANO, 93, 102, 104, 115.
adrogación, 37.
aequitas, 21 ss.
aes et libram, 72.
AFRICANO, 117.
agere, 83, 101.
ager publicus, 46, 56.
agnados, 71.
ALARICO II, 113.
ALCIATO, 132.
ALEJANDRO SEVERO, 23, 24, 93.
alterum non laedere, 18.
ambitus, 73.
AMBROSIONI, C. E., 33, 135.
ANATOLIO, 116, 128.
ANCO MARCIO, 35.
AGUSTIN (Antonio), 118.
antiguas, 129.
APPIO CLAUDIO, 39, 54, 61, 67.
applicatio, 34.
ARCADIO, 97.
ARISTOTELES, 18, 20.
arvales, 38.
auctoritas patrum., 36, 59 ss., 79, 80.
augures, 37, 38.
AULO GELIO, 34, 38, 60, 63, 70, 74
ss., 78.
auspicia, 49.
AZON, 130.
auténticas, 121.

"B"

Bajo Imperio, 92 ss.
BALDO DE UBALDIS, 131.
BARTOLO, 131.
Basilicas, 22, 118, 119, 128.
BASILIO (Macedonio), 128.
BLUHME, 118.
BONFANTE, 23, 24, 33, 123.
Brachylogus, 129.
Breviario de Alarico, 113.
BRUNS, 68.
BUDEO, 132.
BULGARO, 130.

"C"

CALIGULA³, 93.
capitis deminutio, 70.
CAPITON, 34, 78, 102, 103.
CARACALLA (Antonino), 23, 92.
CARLOMAGNO, 127.
CARO, 93.
cassus, 130.
casuística, 102.
cavere, 83, 101.
CARAMES FERRO, José M., 135.
CELSE, 103, 117.
censo, 39, 51.
censor plebeyo, 52.
censura, 48, 51 ss.
CERVIDIO ESCEVOLA, 102, 117.
CHAPPUIS, 123.
CICERON, 21, 24, 67, 73, 74, 76, 77.
CIRILO, 124.
civitas, 19, 28, 32, 33.
CLAIN, 123.
CNEO FLAVIO, 68, 82.
Codex novis, 115, 120.
- vetus, 115 ss., 120.
codificación, 109 ss.
Código civil alemán, 133.
- argentino, 134.
- francés, 134.
Código gregoriano, 24, 110 ss., 113,
115.

- hermogeniano, 24, 110 ss., 113, 115.
- teodosiano, 24, 110 ss., 113, 115.
- coemptio, 72.
- cofrades, 76.
- colección de Canones, 121.
 - Griega, 121.
- colega minor, 49, 50.
- colegios sacerdotales, 34, 36 ss., 41.
- colonias, 89.
- comentaristas, 130, 131.
- comicios, 35, 36, 63, 92.
 - centuriados, 48, 51, 61.
 - curiados, 61.
 - tribados, 48, 53, 56, 61.
- compilación justiniana, 114 ss.
- compilaciones pre - justinianas, 110 ss.
- compraventa, 21, 104.
- concilia plebis, 47, 53, 57, 58, 62, 80.
- concio, 33.
- conflicto patricio - plebeyo, 46 ss.
- connubium, 47, 77, 88.
- conscripti, 58.
- consilium principis, 93.
 - propinquorum, 70.
- consistorium, 96.
- CONSTANCIO CLORO, 94.
- CONSTANTINO, 95 ss., 106, 109, 111.
- CONSTANTINO MENNA, 115.
- constituciones imperiales, 19, 24, 96, 104 ss.
- constitución Antoniniana, 23, 92, 104.
 - codice confirmando, 116.
 - Deo auctores, 116.
 - haec quae necessario, 115.
 - imperatoriam maiestatem, 119.
 - omnem reipublicae, 123.
 - sanctio pragmatica pro petitione vigili, 127.
 - summa reipublicae, 115.
 - Tanta, 117, 119, 120, 122.
- consulado, 48, 49 ss., 51, 92, 96.
- consul suffectus, 50.
- consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, 112.
- contiones, 79.
- concretatio, 75.
- contubernium, 21.
- cooptatio, 57.
- Corpus iuris civilis, 23, 24, 116, 117, 120, 123, 124, 129, 130.
- CRASO, 90.
- CRATINO, 116, 124, 128.
- crimina, 73.
- cuestores parricidii, 52, 77.
- cuestores plebeyos, 52.
- cuestura, 48, 52, 96.

- CUJAS, 113, 122, 123, 132, 134.
- culto, 37 ss.
- curador, 71.
- curias, 32, 36.
- cura annonae, 53.
 - et tutela rei publicae. universa, 92.
- legum et morum, 92.
- ludorum, 53.
- mores, 17, 52.
- urbis, 53.
- cursus honorum, 54.

"D"

- Dammum iniura datum, 74.
- decemviri legibus scribundis, 48, 54, 67.
- decemviro, 54.
- decreta, 105.
- decreta gentis, 33.
- decurias, 32.
- deditio, 34.
- de ESTRADA, S., 135.
- DE FRANCISCI, P., 19, 91.
- delicta, 73.
- delitos privados, 73, 74.
- delitos públicos, 73.
- DEMOSTENES, 124.
- denegationes, 81.
- Derecho Civil, 18, 19 ss., 51.
 - de gentes, 18, 19 ss., 22.
 - natural, 18, 19 ss.
 - privado, 18 ss.
 - público, 18 ss.
 - quiritario, 20, 22, 23, 40, 81.
 - romano helénico, 23.
- Diarquía, 92.
- DIAZ VIALET, A., 135.
- dictador plebeyo, 54.
- dictadura, 48, 53 ss.
- dies fasti, 82.
 - nefasti, 82.
- Digesto, 116 ss., 120, 130.
 - infortium, 123.
 - novum, 123.
 - vetus, 123.
- diócesis, 94.
- DIOCLECIANO, 93, 94, 106, 111.
- DION CASSIO, 91.
- DIONISIO, 57.
- DI PIETRO, A., 11, 87, 135.
- DIRKSEN, 68.
- distinciones, 130.
- dissensiones dominiorum, 130.
- dolo malo, 75.
- DOMICIANO, 96.

- dominado, 22, 24, 92 ss., 124, 127.
- dominium ex iure quiritium, 14, 72.
- DONADEU, 132.
- DOROTEO, 115, 116, 119, 124, 128.
- D'ORS, A., 13, 119.
- duoviri perduellonis, 35.

"E"

- Ecloga, 128.
- edicere, 81.
- edicta, 104.
- edicta Justiniani, 121.
- edicto de los ediles, 53, 104.
 - del pretor, 51, 80 ss., 102, 104.
 - de Milán, 95, 96.
 - de Salvio Juliano, 104, 115.
 - de Teodorico, 113.
 - perpetuo, 81.
 - provincial, 104.
 - repentino, 81.
 - traslaticio, 81.
- edilato, 48, 52 ss.
- edil curul, 49, 52 ss.
 - plebeyo, 49, 52 ss., 58.
- EHRENZWEIG, 118.
- ELGUERA, E.R., 135.
- emancipación, 70.
- emblema Triboniani, 122.
- Enchiridium, 128.
- ENEAS, 27, 31.
- Epanagoge, 128.
- epistola, 104.
- epitome iuliani, 120 ss.
- equidad, 21, 22, 51.
- equites, 40.
- ESCIPIÓN (Emiliano), 89.
- escolias, 21, 129.
- escuela de Alejandría, 124.
 - de Antioquía, 124.
 - de Berito, 24, 106, 115, 123 ss.
 - de Bolonia, 129, 131.
 - de Cesarea, 124.
 - Constantinopla, 24, 106, 115, 123 ss., 128.
 - Estatutaria Holandesa, 132.
 - del Derecho Natural, 132.
 - de los glosadores, 129 ss.
 - de Pavia, 129.
 - histórica, 122, 132 ss.
 - humanista, 122, 132.
- Estado, 31 ss.
- ESTEBAN, 128.
- estirpe, 31 ss.
- estoicos, 16.

EUDOSIO, 124.

- EUSEBIO, 95.
- ex iure quiritium, 15.

"F"

- FABER, 122.
- FADDA, 123.
- fas, 13 ss.
- fatum, 29.
- feciales, 38.
- FERRINI, 123.
- FESTUS, 76.
- flamen dialis, 37.
- flamines maiores, 34, 37.
- FLAVIO LICINIO, 95.
- FLORENTINO, 21, 117, 119.
- foedera, 89.
- fragmenta vaticana, 112.
- FREITAS, 134.
- Fuero Juzgo, 133.
- furtum, 69, 75 ss., 78.
 - conceptum, 75, 76.
 - manifestum, 75.
 - nec manifestum, 76.
 - oblatum, 75, 76.

"G"

- GALERIO, 94.
- GARZON FUNES, L., 135.
- GAYO, 20, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 102, 103, 104, 110, 112, 113.
- gens, 31, 32, 33, 36, 71.
- gentiles, 71.
- GIGENA, D., 135.
- GIRARD, 68.
- Glosa Ordinaria, 130.
- glosemas, 122.
- glossa, 129 ss.
- gobernador, 88, 94.
- GODOFREDO, 68, 123.
- GOMEZ FLEYTAS, J. G., 12.
- GOYENA, P., 135.
- GRACIANO, 96.
- GRACO (Tiberio Sempronio), 89.
- GRACO (Cayo), 89.
- GRANIO FLACCO, 41.
- Gran Glosa, 130.
- GREGORIO, 111.
- GROCIO, 132, 133.
- guerra de los aliados, 89.
 - italiana, 89.
- guerras púnicas, 23, 24, 54.

"H"

HEINECCIUS, 134.
HERMOGENIANO, 111.
HOFFMANN, 118.
honestae vivere, 17.
HONORIO, 97.
HORACIO, 29, 30.
hostes, 72.
HUGO, 24, 130.
humanismo, 132.
humanitas, 88.

"I"

IBARGUREN, C., 135.
in causa mancipi, 72.
index, 79.
infamia censoria, 52.
in rege cessio, 73.
iniuria, 74.
in ius vocatio, 15, 68.
Institutas, 119 ss.
- de Gayo, 102 ss.
instruere, 83.
intercessio, 49, 51, 54.
interdictos, 81.
interpolaciones, 122 ss.
interpretatio, prudentium, 83.
interregnum, 60.
interrex, 35, 36, 50, 55.
invasio, 75.
imperator, 87, 92.
Imperio, 22, 29, 90 ss.
- occidental, 23, 24.
- oriental, 23, 24.
imperium, 16, 32, 35, 48, 49, 50, 80, 81, 87 ss.
- proconsulare, 92.
- militiae, 50.
IRNERIUS, 121, 129, 130.
iudex, 16, 101.
iura, 78, 109, 110, 111, 115, 116.
iurisprudencia, 16 ss.
iurisprudentes, 16, 17, 82.
ius, 13 ss., 82.
- aelianum, 82.
- agendi cum patribus, 50, 59.
- agendi cum populo, 50.
- commercii, 88.
- dicere, 15.
- edicendi, 50, 80, 104.
- flavianum, 82.
- gentium, 21.
- honorarium, 23, 80, 81, 104.

- honorum, 52.
- migrandi, 88, 89.
- naturale, 21.
ius papirianum, 41.
- pretorium, 80.
- privatum, 19.
- publice respondendi, 101 ss.
- publicum, 19.
- sufragii, 52.
iustae nuptiae, 21, 77.
iustitia, 16, 21.
iustum bellum, 38.

"J"

JACOBO, 130.
JAVOLENO PRISCO, 102, 103, 117.
JOVIANO, 96.
JUAN, 115.
JUAN DE ANTIOQUIA, 121.
JUAN DE CAPADOCIA, 24.
JULIANO, 96, 117, 120.
JULIO CESAR, 50, 52, 54, 90 ss.
jurisdicción, 49, 50, 51.
juniores, 39.
jurisprudencia clásica, 101 ss.
JUSTINIANO, 12, 22, 24, 102, 103, 114 ss., 116, 121, 122, 127, 128, 129.
JUSTINO II, 121.
JUVENCIO CELSO, 103.

"K"

KASER, M., 24.
KOSCHAKER, P., 133.
KROLL, 123.
KRUGER, 123.

"L"

LABEON, 102, 103, 117.
lectio senatus, 52.
lectura haloandrina, 123.
leges, 78, 109, 110, 111, 115.
legis actionis, 21.
LEON VI (el Filósofo), 128.
LEON III (el Isaúrico), 128.
LEON III (Papa), 127.
LEONCIO, 124.
LEPIDO, 91.
lex, 78 ss.
- Aebutia, 81.
- Aemilia, 51.
- Aeterna Tarpeya, 62.

- Aquilia, 74, 80.
- Canuleia, 77.
- Curiata de Imperio, 61.
- data, 78.
- de Bello Indicendo, 62.
- de Censoria Potestate, 62.
- Dei Sive Mosaicorum et Romano-rum Legum Collatio, 112.
- Hortensia, 59, 62, 63, 80.
- Iulia Papiria, 62.
- Licinia, 50.
- Licinia Mucia, 89.
- Menenia Sextia, 62.
- Ovinia, 58.
- Poetelia Papiria, 71, 80.
- Publilia, 57, 63, 80.
- Publilia Philonis, 59.
- Regia de Imperium, 104.
- rogata, 78 ss.
lex Romana Burgundiorum, 114.
- Romana Uthinensis, 114.
- Romana Visigothorum, 112, 113.
- Sacrata, 46, 56.
- Valeriae de Provocationem, 61.
- Valeriae Horatiae, 57, 63, 80.
Ley de citas, 24, 110, 111, 116.
- de las XII Tablas, 19, 22, 23, 24, 34, 40, 47, 54, 67 ss.
- Isaúrica, 128.
Leyes comiciales, 19.
- de Partida, 133.
- imperfectae, 79.
- minus quam perfectae, 79.
- perfectae, 79.
- regias, 41.
- romano bárbaras, 113 ss.
liber actionum, 82.
liberto, 71.
Libri Feodorum, 130.
Libro de Derecho Sirio Romano, 112.
LICINIO, 111.
liga hénica, 88.
liga latina, 88.
litis, 16.
Lombarda (la), 129, 130.
LOPEZ, V. F., 135.
LUCIO ANNEO FLORO, 45, 46, 55.
LUCIO BRUTO, 45.
LUCIO VALERIO, 67.
LUCUMEN, 36.

"M"

magister equitum, 54.
- gentis, 33.

- memoriae, 105.
- populi, 53.
magistrados Populi Romani, 30.
magistraturas cum imperium, 48.
- curules, 49.
- extraordinarias, 48, 53 ss.
- mayores, 48.
- menores, 48.
- no curules, 49.
- ordinarias, 48, 49 ss.
- patricias, 49.
- plebeyas, 49, 55 ss.
- republicanas, 47 ss.
- sine imperium, 48.
MAJENCIO, 95.
MAHOMETO II, 129.
maiestatem populi romani, 30.
maleficium, 73.
malum carmen, 74.
mancipatio, 21, 72.
mancipium, 71.
mandata, 105.
mando militar, 49.
manum consortum, 72.
manus, 72.
manus inieccio, 69, 78.
MARCELO, 117.
MARCIANO, 117, 119.
MARCIO RUTILO, 54.
MARCO ANTONIO, 91.
MARCO AURELIO, 111.
MARCO HORACIO, 67.
MARIO, 90.
MARTINO, 130.
MASURIO SABINO, 102, 103.
MAXIMIANO, 94.
MAXIMINO, 93.
MAXIMINO DAZA, 95.
MAYNZ, 134.
MELTZER, 123.
membrum ruptum, 74.
MENENIO AGRIPA, 56.
método dialéctico aristotélico, 131.
método exegetico, 130.
MEYER, 33.
missiones in possessionem, 81.
MODESTINO, 102, 110, 112, 117.
MOLITOR, 134.
MOMMSEN, 33, 35, 92, 123.
monarquía, 22, 27 ss., 34.
mores maiorum, 15, 17, 40, 70.
mos, 15.
- gallicus, 132.
- italicus, 131.

"N"

nacimiento con vida, 104.
 naturalis ratio, 20.
 NERACIO PRISCO, 103, 117.
 NERON, 93.
 nexum, 46, 47, 56, 71, 72, 80.
 NIEBUHR, 102.
 nomen gentilicium, 33.
 Novelas, 120 ss.
 noxa, 69.
 NUMA POMPILIO, 35, 38.
 numen, 29, 31.

"O"

occenatio, 74.
 occupatio, 21.
 OCTAVIO AUGUSTO, 90, 91 ss., 101, 104.
 ODOFREDUS, 130.
 oratores, 83.
 os fractum, 74.

"P"

pacto Cassianum, 88.
 pagus, 33, 39.
 Pandectas, 116 ss., 130.
 Pandectística alemana, 133.
 PAPINIANO, 19, 102, 109, 110, 112, 117, 118.
 PAPIRIO JUSTO, 111.
 papyrus Oxyrhynchus, 102.
 Paráfrasis de Teófilo, 128.
 parricidio, 73.
 partes legum, 118.
 pater familiae, 33, 70.
 - gentium, 33.
 patres, 58, 60.
 patria potestas, 70.
 patricios, 33, 39, 80, 124.
 patrono, 71.
 PAULO, 15, 75, 102, 109, 110, 112, 117, 118.
 pax, 31, 87.
 pedari, 58.
 PEGASUS, 103.
 perduellio, 35, 49, 73.
 PEREYRA, E., 135.
 permuta, 21.
 persecutio lance et licio, 75.
 PETERS, 118.
 Petri Exceptiones Legum Romanorum, 129.
 pietas, 30, 88.

pignoris capio, 77.
 PLACENTINO, 130.
 PLATON, 18.
 plebeyos, 33, 39, 51, 80.
 plebiscitos, 62, 80.
 plebiscito: Atinio, 58.
 - Trebonio, 57.
 PLINIUS, 76.
 POMPEYO, 90.
 POMPONIO, 41, 102, 117.
 pontifex maximus, 92.
 pontífices, 13, 14, 37, 41, 81, 82.
 populus, 19, 80.
 - romanus, 34.

postglosadores, 131.
 potestad tribunicia, 91.
 POTHIER, 123, 134.
 praefectura morum, 91.
 praefectus urbis, 35, 54.
 praerogatio, 79.
 praescriptio, 79.
 pragnática, 105.
 preceptos fundamentales de Ulpiano, 17 ss.
 predigesto, 118.
 prefecturas, 94, 96.
 pretor, 15, 21, 22, 49, 50 ss., 104.
 - maximus, 49, 53.
 - peregrino, 19, 24, 50, 51, 80, 104.
 - urbano, 50, 51, 80, 104.
 pretura, 48, 54, 92, 96.
 principado, 22, 24, 91 ss.
 principis senatus, 59, 92.
 privilegia, 105.
 procedimiento formulario, 81.
 proconsul, 88.

proculeyanos, 103 ss., 115.
 PROCULO, 102, 103, 117.
 Prochiron, 128.
 proletarii, 40.
 promulgatio, 79.
 propretor, 88.
 proprietates, 31.
 provincias, 88, 92, 93, 94.
 provocatio ad populum, 54, 61, 77.
 prudentia, 17.
 prudentia iuris, 13.
 pubertad, 104.
 PUBLIO VALERIO, 46.
 PUECHER, 123.

"Q"

quaestores parricidii, 35.
 quaestor sacra palatii, 96.

Quinquaginta decisiones, 115, 116, 120.

"R"

rapina, 75.
 recepción del D. Romano en Alemania, 131.
 regula, 16.
 reivindicatio, 72.
 religio, 29 ss.
 REMO, 27.
 república, 22, 88.
 Res Cotidianae, 119.
 res mancipi, 71, 72.
 rescripta, 105, 116.
 respondere, 82, 101.
 respuesta de los prudentes, 81.
 respuestas de Papiniano, 113.
 RHEA SILVIA, 27.
 RICCOBONO, 12, 68, 114, 122, 123.
 ritus, 14 ss.
 RODRIGUEZ, V., 135.
 reforma de Servio Tulio, 39.
 rogatio, 79.
 romanticismo, 133.
 ROMULO, 27 ss., 35, 36.
 renuntiatio, 63.
 rex, 13, 14, 32, 34, 35, 36.
 rex sacrorum, 34, 37, 45, 49.

"S"

sabinianos, 102, 103 ss., 115.
 SABINO, 117, 118.
 sacramentum, 69.
 sacrilegio, 49, 73.
 Sacro Imperio Romano Germánico, 127.
 Salios, 38.
 SALVIO JULIANO, 102, 103, 104.
 sanctio, 79.
 SAVIGNY, 132 ss., 134.
 SCHOELL, 68, 123.
 SCHOFFER, 123.
 SCIALOJA, 123.
 secessio plebis, 56.
 sella curulis, 49, 53, 58 ss.
 senadoconsultos, 19, 59.
 - institium, 60.
 - ultimu, 60.
 Senado imperial, 92, 93, 97.
 - monárquico, 35 ss.
 - republicano, 50.
 seniores, 39.
 Sentencias de Paulo, 109, 113.
 sententiae receptae, 83.
 SEPTIMIO SEVERO, 93, 111.
 SERVIO TULLIO, 32, 35, 36, 39, 51.
 SEXTO AELIO PETUS CATUS, 68, 82.
 SEXTO PAPIRIO, 41.
 SILA, 50, 54, 90.
 sodales, 76.
 sponsio, 21.
 stipulationes, 81.
 STORY, 134.
 sucesión ab - intestato, 71.
 sui heredes, 71.
 sum cuique tribuere, 18.
 summa coercens potestas, 57.
 summas, 130.
 SUMMER MAINE, 32.
 subscriptio, 104.

"T"

talión, 74.
 TARQUINO COLATINO, 45.
 - (el Soberbio), 35, 45.
 - PRISCO (el Antiguo), 35, 39.
 TEODORICO, 113.
 TEODOSIO, 96.
 TEODOSIO II, 79, 110, 111, 112.
 TEOFILO, 115, 116, 119, 124, 128.
 TERENTILLO ARSA, 67.
 testamento per aes et libram, 72.
 tetraquía, 94.
 TIBERIO, 93.
 - CORUNCANIO, 47, 82.
 TIBERIO II, 121.
 TITO LIVIO, 34, 38, 49, 57, 67.
 - TACIO, 28, 36.
 TOBAL, G. F., 135.
 TOMAS (Santo), 18.
 traditio, 21.
 TRAJANO, 93.
 TRIBONIANO, 115, 116, 119, 128.
 tribunado, 47, 55, 96.
 - militum consulare potestate, 48, 53, 54 ss.
 Tribunal del Príncipe, 105.
 Tribuno celerum, 35.
 tribunos, 47, 49, 52.
 tribus, 32, 36, 39.
 tri nocti usurpatio, 72.
 trinundinum, 63.
 Triperita, 82.
 Triunvirato Rei Publica Constintundae, 48.
 TULLIO HOSTILIO, 35.
 tumultus, 60.
 tutela mulierum, 70.
 tutor, 71.

ULPIANO, 14, 17, 18, 21, 22, 79, 102,
104, 109, 110, 112, 117, 118, 119.
ULPIO MARCELO, 102.
usucapio, 71, 72.
usus, 72.

"V"

admonium, 69.
VALENTE, 111.
VALENTINIANO, 96, 111.
VALENTINIANO III, 79, 110, 112.
VALERIO MAXIMO, 81.
VELEZ SANSFIELD, D., 12, 134.
vestales, 37, 38.
via, 73.
vicario, 94.
VICO, 32.
VILLEY, M., 18.
vindex, 33, 69.
vindictae, 72.
VINNIUS, 132, 134.

vir, 16.
VIRGILIO, 27.
virus, 16, 22, 30.
vitae necisque potestas, 70.
vulgarismo, 106.

"W"

WEIGEL MUÑOZ, E., 135.
WIEACKER, 131.

"Y"

yaus, 14.

"Z"

ZACHARIAE, 134.
ZASIO, 132.
ZENON, 113.

INDICE TEMATICO

CAPITULO 1

NOCIONES FUNDAMENTALES

El Derecho Romano. Su trascendencia. Utilidad de su estudio.	2.
Estado actual de la cuestión	
Ius y Fas	
Iustitia	
Iurisprudentia	
Los preceptos fundamentales de Ulpiano	
a) <i>Honestae vivere</i>	
b) <i>Alterum non laedere</i>	
c) <i>Suum cuique tribuere</i>	
Derecho público y Derecho privado	
Del Derecho natural, del Derecho de Gentes, del Derecho Civil	
Aequitas	
División de los periodos del Derecho Romano	

CAPITULO 2

LOS ORIGENES. LA MONARQUIA

Historia y leyenda	
El espíritu religioso	
El romano, la tierra, las armas	
Estirpe y Estado	
La organización social: la gens	
Patricios, plebeyos, clientes	

	Pág.
La estructura política de la monarquía	34
El Rey (<i>Rex</i>)	34
El Senado	35
El Pueblo: los Comicios	36
Los Colegios Sacerdotales	36
Colegio de los Pontífices	37
Colegios de las vestales	37
Colegios de los augures	38
Colegio de los Feciales	38
Colegio de los Salios	38
Colegios de los aruales	38
Reformas de Servio Tulio	39
Las fuentes de derecho	40
Las Mores Maiorum	40
Las Leyes Regias	41

CAPITULO 3

EL FIN DE LA MONARQUÍA. "RES PUBLICAE"

Un Estado dentro del Estado. Conflicto patricio - plebeyo	46
Las Magistraturas	47
Sus caracteres	47
Clasificación de las magistraturas	48
Magistraturas Ordinarias	49
Los Cónsules	49
Los Pretores	50
Los Censores	51
Los Cuestores	52
Los Ediles	52
Magistraturas Extraordinarias	53
a) El Dictador	53
b) El Prefecto Urbano	54
c) Los Decemviratos Legislativos	54
d) El Tribunado Militar con Potestad Consular	54
e) El Interrex	55
Magistraturas Plebeyas	55
a) El Tribunado de la Plebe	55
b) Los Ediles Plebeyos	58
El Senado republicano	58
Facultades del Senado	59
a) Auctoritas Patrum	59
b) Interregnum	60
c) Función consultiva	60

	Pág.
Los Comicios	60
a) Comicios Curiados	61
b) Comicios Centuriados	61
c) Comicios Tribados	61
d) Concilia Plebis	62
e) Convocatoria y desarrollo de las Asambleas Populares	63

CAPITULO 4

LAS FUENTES DE DERECHO

La Ley de las Doce Tablas	67
Contenido de las Tablas	68
Las fuentes republicanas	78
a) La lex	78
b) Plebiscito	80
c) Edicto	80
Clases de Edictos	81
d) Respuesta de los prudentes	81

CAPITULO 5

EL IMPERIO

La concepción romana de Imperium	87
El fin de la República	88
Una nueva etapa: el Imperio	90
Características del Principado	91
La decadencia: el Bajo Imperio	92
Características del Dominado	96

CAPITULO 6

LAS FUENTES DE DERECHO EN EL IMPERIO

La jurisprudencia clásica	101
Las dos escuelas: Proculyanos y Sabinianos	103
Las Constituciones Imperiales	104
a) Los Edictos	104
b) Los Rescriptos	105
c) Los Decreta	105
d) Los Mandata	105
e) Los Privilegia	105

La Adnotatio	105
La Pragmática	105
La jurisprudencia en el Dominado	106

CAPITULO 7

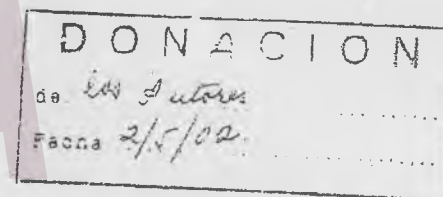
LA CODIFICACION

Ley de las citas	110
Compilaciones pre-justinianas	110
Código Gregoriano	111
Código Hermogeniano	111
Código Teodosiano	111
Otras recopilaciones	112
Las leyes Romano Bárbaras	113
Edicto de Teodorico	113
Lex Romana Visigothorum	113
Lex Romana Burgundionum	114
Lex Romana Utiensis	114
La Compilación Justiniana	114
Código	115
Digesto	116
El problema del método de trabajo seguido en el Digesto	117
Institutas	119
Novelas	120
Las interpolaciones	122
Corpus Iuris Civilis	123
Las escuelas de Derecho en Oriente	123

CAPITULO 8

EL DERECHO ROMANO DESPUES DE JUSTINIANO

Obras jurídicas de la época	128
Los Glosadores	129
Los Comentaristas	131
La Recepción del Derecho Romano en Alemania	131
El Humanismo	132
El Derecho Romano en la Argentina	133



Este libro se terminó de imprimir el día 20 de febrero de 1993 en
los talleres gráficos de Editorial Lex.
La Plata, Prov. de Buenos Aires